

제10장 배당등 절차

제10장 배당등 절차

제1절 서설

채권배당절차란, 대체로 채권집행사건(채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행 및 그에 대한 담보권의 실행 등 사건)에 있어서 제3채무자의 공탁 등으로 인해 형성된 배당재단을 압류명령 등을 신청한 채권자에게 배분하는 절차를 말한다.

부동산집행이든, 채권집행이든, 채무자의 재산을 압류하고 집행기관이 재산을 매각하거나 압류를 한 채권자가 직접청구를 함으로써 변제에 충당할 수 있는 금전으로 현금화한 다음 압류 등을 한 채권자에게 지급된다는 「압류 → 현금화 → 만족」의 과정을 밟아나가게 되어 있는 것은 같다.

그러나 부동산집행의 경우에 만족을 얻기 위해서는 그 최후에 배당등의 절차가 거의 필연적으로 예정되어 있지만, 채권집행에서는 다른 경합하는 채권자가 없을 경우 청구된 금전은 집행법원에 의한 절차를 거침이 없이 지급을 청구한 채권자의 채권에 충당되어질 수가 있기 때문에 반드시 배당등의 절차를 거쳐야만 그 절차가 종료된다고 말할 수는 없다. 그리고 바로 이것이 부동산배당절차와 채권배당절차의 가장 기본적인 중요한 차이점이라고 할 수 있다.¹⁾

이하에서는 위와 같은 채권배당절차가 가지는 특징과 그 절차의 진행 등에 관한 모든 것을 천천히 살펴보기로 하되, 먼저 이러한 채권배당절차와 이미 본대로 강제집행절차의 중심에 서있는 부동산배당절차와의 차이점을 비교·분석해보는 데에서 이와 같은 논의를 시작해보기로 한다.²⁾

1) 우리 민사집행법(2002. 1. 26. 법률 제6627호로 제정된 것)도 부동산배당절차에 관해서는 민사집행법 제2편 제2장 제2절 제2관의 강제경매(및 이를 준용하는 담보권실행경매)의 조문 중에서 이를 한꺼번에 규정하고 있지만, 채권배당절차에 관해서는 민사집행법 제2편 제2장 제4절 제3관에서 규정하는 채권집행절차와는 다르게 같은 절 제4관에서 따로이 그 배당절차를 규정하고 있다.

2) 제10장의 타이틀을 「배당등 절차」로 한 것은 배당절차와 변제금교부절차에 관한 설명을 이에 모두 포함시키기 위함이다.

☐ 변제금교부절차에 대하여

1. 개설

현행법상 채권집행에 있어서 집행법원에 의한 환가대금의 배분절차로는, (변제금) 교부절차와 배당절차가 있다.^{3) 4)} 그 중 전자는 채권자가 1인인 때, 또는 채권자가 2인 이상이어도 배당재단이 각 채권자의 채권과 집행비용의 전부를 변제할 수 있는 때 [즉 이는 채권자들 사이에 이해관계의 대립이 없거나 또는 환가대금이 각 채권자의 채권과 집행비용을 만족시키기에 충분한 때를 말하는데, 여기에는 압류가 1개인 경우, 압류집행이 경합하고 있으나 채무액이 채권자들의 채권을 만족시키기에 충분한 경우(이른바, 부진정경합의 경우) 등이 포함된다]에 행해지는 절차로서, 후자가 배당재단으로써 2인 이상인 각 채권자의 채권과 집행비용을 만족시키기에 부족한 경우(민집 제235조, 압류가 경합되는 경우)에 행해지는 것과 대비된다. 그리고 이 양자를 한

3) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 494-495.

4) 아래에서 다시 보겠지만, 변제금교부절차와 달리, 배당절차는 그 절차가 상당히 엄격하다. 이는 피압류채권이 당사자들의 채권액을 모두 만족시키지 못하므로 당사자들 사이에 이해관계가 첨예하게 대립되어 있기 때문인바, 그 절차를 약간 개관만 하여 보면 배당절차의 경우 배당기일을 지정하고 그것을 채권자들 모두에게 통지해야 하는데, 그 방법은 기일통지서를 송달하는 방법으로 하고(민집 제23조 제1항, 민소 제167조 제1항), 또 배당기일 3일 전까지는 배당표 원안을 작성하여 법원에 비치함으로써 채권자들이 배당표를 열람할 수 있도록 해야 한다(민집 제256조, 제149조 제1항). 그리고 채권자들 및 채무자는 배당기일에서 진술할 수 있고 배당표에 대해 이의를 할 수 있으며, 집행법원은 이에 대해 배당기일조서를 작성하여야 한다.

그런데 이와 같은 모든 절차를 단순히 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 1인의 채권자만 압류한 후 제3채무자가 공탁하였기 때문에 배당등을 받을 채권자가 혼자인 상황에서도(또는 부진정 경합이어서 당사자 사이에 이해관계 대립이 없는 상황에서도) 그대로 적용하여 한 2-3월가량 내지 많게는 5-7월 가량 간격을 두고 진행되는 다른 배당절차사건(배당절차의 경우에는 이해관계가 대립하는 당사자들의 수가 많고 그들에 대한 기일통지 송달의 문제가 있어서 그 진행에 시간이 걸리는 것은 이미 예정되어 있는 것이다)과 동일하게 취급한다면 신속한 채권회수를 바라고 있는 채권자들의 권리구제에 결함을 나타낼 수 있을 것이고, 그 채권자들은 법원의 이러한 처리를 이해하기 어려울 것이다.

또한 앞서 본 바대로 부동산집행과 달리 채권집행은 당연히 배당등 절차를 예정하고 있지 아니하므로 압류가 경합되지 않은 상태에서 제3채무자가 공탁하지 않고 압류채권자에게 지급하였다면 이해관계가 대립하고 있지 않기 때문에 당연히 신속하게 채권의 만족을 받을 수 있었을 터인데 우연히 제3채무자의 공탁으로 인해 그 만족이 늦어졌을 뿐만 아니라 나아가 그 절차마저 엄격한 배당절차로써 진행되는 이유로 다른 이해관계의 대립이 있는 사건들과 동일하게 취급된다면 위 채권자의 불이익이 상당히 될 것임은 쉽게 짐작가능한 일이라 할 것이다(일본의 경우에는, 부동산배당절차에 있어서도 이해관계의 대립이 없는 때를 염두에 두고 변제금교부절차를 따로이 설정하고 있으나, 특별한 사정이 없는 한 당연히 배당절차가 예정되어 있는 부동산집행에 있어서 그와 같은 고려를 반드시 할 필요는 없다고 본다).

이러한 이유들로 인해서, 위 배당절차 중 일정 부분을 간략화시킨 변제금교부절차란 개념이 등장하게 된 것이고, 채권집행의 경우 그와 같은 절차의 정립은 필요하다고 본다.

꺼번에 배당등 절차라고 하거나 혹은 광의의 배당절차 속에 교부절차와 협의의 배당절차가 있다고도 설명하고 있는바, 여기서는 이를 함께 지칭할 때 「배당등 절차」라고 부르기로 한다.

제3채무자의 공탁등에 의해 배당재단이 일단 형성되면 집행법원은 그 공탁금 등을 각 채권자에게 분배하기 위해서 배당등 절차를 실시해야 하는데(민집 제252조, 제273조 제3항), 배당재단 중에서 분배를 받을 액에 대하여 채권자 상호간에 이해의 대립이 생길 여지가 있는지 여부에 의해 이와 같이 절차에 차이가 생긴다. 게다가, 교부절차의 경우에는 채권자가 1인이거나 또는 2인 이상이어도 각 채권자가 채권 전액을 변제받는 것이 가능하고 다툼이 생길 여지가 없기 때문에 간이한 절차가 허용된다. 이에 대해 배당절차는 채권자가 2인이상이고 그 속의 1인 이상은 반드시 채권 전액의 변제를 받을 수 없기 때문에 채권자 상호간의 이해의 조정을 도모할 필요가 생기며, 그에 따라 엄격한 절차가 요구된다.

우리의 실무는 앞서 보았듯이, 배당절차와 다른 교부절차 개념을 도입하고는 있지만, 그에 대한 구체적인 절차를 아직 마련하지 않은 탓에 실제에 있어서 상당한 어려움을 겪고 있는 상황이다. 그러므로 아래에서는 우리와 거의 유사한 채권집행구조를 취하고 있는 일본 민사집행법이 변제금교부절차를 어떻게 규정하고 또한 그것을 어떤 방법으로 실시하고 있는가에 대하여 살펴보기 위해 다소의 지면을 할애하기로 한다.

2. 변제금교부일의 지정

가. 기일 등의 지정

배당등을 실시해야 하는 것으로 된 때(日民執規 제145조)에는, 집행재판소는 배당절차의 경우에는 배당기일을, 교부절차의 경우에는 변제금교부일(이하, 양자를 통틀어 말할 때는 배당등 기일이라고 한다)을 정해야 한다(日民執規 제59조 제1항).

배당등을 실시해야 하는 때란, 예컨대 제3채무자가 피압류채권을 공탁하고(日民執 제156조 제1항, 제2항), 공탁서를 첨부하여 집행재판소에 사유신고를 제출한 때이다(日民執 제156조 제3항, 日民執規 제138조). 배당등 기일은 이때로부터 특별한 사정이 없는 한 1개월 이내의 날로 되어야 한다(日民執規 제59조 제2항).

그러나 이 규정은 일반적으로 훈시규정으로 해석되고 있으므로⁵⁾ 사건 수가 매우

5) 吉野 衛・三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(4), きんぎ, 平成 7年(1995), 243.; 鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 注釋民事執行法(3), 第一法規出版株式會社(昭和60), 349.

많은 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 1개월을 초과한 날을 지정하는 것도 허용된다. 또, 급료채권과 같이 매월 지급되는 계속적 급부에 관계된 경우의 배당등에 있어서는 수개월분을 함께 모아서 배당등 기일을 지정할 수 있다.

나. 집행재판소에 의한 지정

전술한 바와 같이 채권자가 1인인 경우 또는 2인 이상이어도 배당재단으로 각 채권자의 채권 및 집행비용의 전액을 만족시킬 수 있는 경우에는 변제금교부일을 지정한다(日民執 제84조 제2항, 日民執規 제59조 제2항). 그 외의 경우에는 배당기일을 지정해야 한다(日民執 제84조 제1항, 日民執規 제59조 제2항).

위 기일 중 어느 것을 지정할 것인가는 집행재판소가 배당등 기일의 지정 전에 판단해야 해야 하고(日民執規 제59조 제1항 참조), 이때 각 채권자의 채권액을 인정하는 자료는 (가)압류명령, 배당요구신청서, 교부청구서 등이 된다.

실무상 이 경우 채권액은 개략적 숫자에 의해 인정되는 것이어서, 만일 어느 것을 지정할지 미묘한 경우에는 배당기일을 지정하는 것이 통례이다.⁶⁾

다. 지정의 효과

변제금교부일이 지정되면 교부계산서를 작성하여 변제금을 채권자에게 교부하고, 잉여금이 있으면 이를 채무자에게 교부하게 된다(日民執 제84조 제2항).

이 경우는 채권자들이 모두 만족을 받고 그 사이에 이해관계의 대립이 없으므로 배당이의에 준하는 이의가 인정되지 않으며, 반대설은 있으나, 채무자 또한 교부계산서의 기재내용에 대해 실체상의 사유에 기초한 불복신청이 인정되지 않는다는 것이 통설의 입장이다.^{7) 8)} 그 반면, 배당기일이 지정된 경우에는 배당표를 작성하여 배당을 실시하고(日民執 제85조 제1항, 제89조 제2항), 채권자 및 채무자는 배당표의 기

6) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(4), 242.; 鈴木忠一 外, 위 注釋民事執行法(3), 348.

7) 田中康久, 新民事執行法の解説(増補改正版), 社團法人 金融財政事情研究會, 234.; 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(4), 252.; 鈴木忠一 外, 위 注釋民事執行法(3), 354.

8) 다만 여기서 채무자의 실체상 사유에 의한 이의가 인정되지 않는다는 것은, 변제금교부일을 「기일」이라는 의미로 정하여 그때에 채무자의 이의를 인정하지 않는다는 의미일 뿐이다. 즉 다음에 보듯이 채무자는 변제금교부일 이전에 청구이의의 소 등을 제기한 후 잠정처분을 얻어 이를 변제금교부일까지 제출하면 배당이 유보되는바(배당금이 공탁된다), 이에 비추어 보면 이는 실질적으로 채무자의 이의를 인정하는 것이며, 그러한 채무자의 이의가 없을 때에 이를 근거로 하여 채권자의 권리를 형식적으로 확정시킨다는 의미에서는 일반 배당기일의 절차와 다름이 없는 것이다(다시 말해, 양자의 차이는 「배당등 기일」에 채무자가 이의할 수 있는가 아닌가 여부에만 있는 것이고, 변제금교부절차 역시 채무자의 이의 없음을 근거로 권리를 확정시키는 점에서는 같다는 것이다).

재내용에 대한 불복신청이 인정된다(日民執 제89조 제1항).

3. 기일 등의 소환

가. 배당기일의 경우

배당기일이 지정된 때에는 배당을 받아야 하는 채권자 및 채무자를 소환하여야 한다(日民執 제85조 제2항). 배당등을 받을 지위에 있는 채권자이면 배당등의 교부를 받는 것이 없어도 소환되어야 한다. 그러나 채권집행에 있어서 제3채무자는 공탁등에 의해 면책을 받는 것이므로 소환할 필요가 없다.

배당기일의 소환은 배당기일소환장을 송달하는 방법에 의해 행한다(日民執 제20조, 日民訴 제154조 제1항). 이 소환은 배당기일에 있어서 배당표에 기재된 각 채권자의 채권 및 배당액에 대하여 이의의 신청을 할 기회를 보장하는 의미를 가지며, 배당절차 가운데에서 가장 중요한 절차 중 하나이므로 이해관계인 전원에 대하여 송달의 효력이 생기지 않으면 배당기일을 개시하는 것은 불가능하다고 해석되고 있다.⁹⁾

나. 변제금교부일의 통지

변제금교부일이 정해진 때에는 변제금의 교부를 받을 채권자 및 채무자에 대하여 그 일시 및 장소를 통지한다(日民執規 제59조 제3항).

통지의 방법은 적당한 방법에 의하는 것이 가능하므로(日民執規 제3조 제1항), 보통우편, 구두, 전화 등으로 해도 무방하다. 다만 민사집행에 있어서 일반적인 통지는 이것을 받을 자의 소재가 명확하지 않은 때 또는 그 자가 외국에 있는 때는 이를 하지 않을 수 있지만(日民執規 제3조 제5항), 변제금교부일의 통지는 집행의 최종절차이므로 이것을 생략할 수 없다(日民執規 제3조 제6항).

실무상으로는, 변제금교부일의 통지 역시 송달의 방법으로 행하고 있다.

4. 채권계산서의 제출

가. 채권계산서 제출의 최고

배당등 기일이 정해진 때에는, 재판소서기관은 각 채권자에 대하여 채권의 원본, 배당등 기일까지의 이자, 손해금 및 집행비용의 액을 기재한 계산서를 1주일 이내에 제출하도록 최고해야 한다(日民執規 제60조).

9) 田中康久(주7), 229.

이 계산서에 의해 배당등 기일에 근접한 시점에서의 채권자의 채권액 및 집행비용액을 확인하고 이에 근거하여 배당표 또는 변제금교부계산서를 작성하게 된다.

위 최고도 적당한 방법으로 하는 것이 가능하지만(日民執規 제3조 제1항), 이를 받을 자의 소재가 명확하지 않은 때 또는 그 자가 외국에 있을 때라도 생략할 수 없다. 이 경우는 최고해야 할 사항을 공고(日民執規 제4조 제1항)하면 족하다(日民執規 제3조 제3항). 재판소서기관은 최고한 취지 및 그 방법을 기록상 명확하게 해두어야 한다(日民執規 제4조 제2항). 실무상, 위 최고는 배당기일의 소환장 또는 변제금교부일통지서의 송달 혹은 그 송부와 함께 하고 있다.

나. 채권계산서 불제출의 효과

채권계산서를 제출하지 않아도 채권자는 배당등을 받을 지위를 박탈당하지 않고, ¹⁰⁾ 1주년을 경과한 후에 제출한 채권계산서도 무효로 되지 않으며, 이 또한 배당표 또는 변제금교부계산서 작성의 자료가 된다.

5. 배당기일과 변제금교부일의 변경

가. 배당기일을 지정하였는데, 교부절차에 의해야 되는 것으로 판명된 경우

배당기일을 지정하였는데, 후에 제출한 채권계산서등에 의해 채권액이 감소하였음이 확인되어 변제금교부일을 지정해야 할 사건으로 판단이 된 경우, 채무자의 배당이의의 신청권과의 관계에서, 집행법원으로서는 이를 어떻게 처리해야 하는가가 문제로 된다. ¹¹⁾

이 점에 대하여는 다음과 같이 견해가 대립하고 있다. ¹²⁾

즉 ① 이미 지정한 배당기일을 변제금교부일로 변경하지 않고 배당기일을 실시해야 한다고 보는 견해(따라서 채무자는 배당이의의 신청을 할 수 있다), ② 배당기일을 취소하고 새로 변제금교부일을 지정해야 한다는 견해, ③ 배당기일을 변제금교부일로 변경해야 한다는 견해 등이 나오고 있다.

동경지방법재판소의 실무는 위 ①설에 의하고 있는 것으로 보인다. 위 실무는 그 근거로서 본래 위 ②설과 같이 하여 교부절차에 의하는 것이 적절한 조치라고 생각되지만, 이 견해에 의하면 절차가 지연되거나 再度通知를 요하는 등 소송경제에 반하는

10) 田中康久(주7), 222, 230.

11) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(4), 242.

12) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例クイズ社, 309.

점, 또 위 ③설에 의할 경우에는 배당기일의 소환을 받고 그 기일에 배당이의를 제출하면 되리라 생각하고 있던 채무자로부터 이의의 기회를 박탈하게 되어 채무자의 보호에 흠결이 생기는 점 등을 들고 있다.¹³⁾ 그래서, 위 동경지방법재판소에서는 위 ①설에 기초하여 이러한 경우에도 배당기일을 취소하거나 혹은 변제금교부일로 변경하지 않은 채 배당기일을 그대로 개시하여 배당표를 작성한 다음 배당이의의 신청을 인정하고 있으며, 이와 같은 실무례는 배당이의소송에 있어서도 그대로 인정된다.

다만 요즈음 배당기일을 지정한 후에 변제금교부일을 지정해야 할 것으로 판명되었지만 이를 교부일로 변경하지 않고 교부계산서를 작성한 그대로 배당기일을 실시한 경우에, 채무자는 교부계산서의 내용에 대해 배당이의의 신청 또는 배당이의소송의 제기가 가능하지 않다라는 취지의 판결¹⁴⁾도 등장하고 있다.

나. 변제금교부일을 지정하였는데, 배당절차에 의해야 하는 것으로 판명된 경우

위와 반대로 변제금교부일을 지정하였는데, 채권 전액의 만족을 받을 수 없는 채권자가 생겼음이 판명된 경우의 문제가 있다.

이 경우는 변제금교부일이 지정되었으므로 각 채권자는 자기의 채권은 전액만족을 받는 것으로 기대하고 있었는데, 당일에 이르러 만족을 받지 않는 것으로 되면, 실질적으로 배당이의신청의 기회가 박탈될 개연성이 높다.

따라서 채권 전액의 만족을 받을 수 없는 채권자가 생긴 것이 확인된 경우에는 이미 지정한 변제금교부일을 취소하고, 이를 변경하여 상당기간의 여유를 두고 배당기일을 지정한 다음 이해관계인에 대하여 배당기일소환장을 송달하는 것으로 하고 있다.¹⁵⁾

다. 배당절차와 교부절차가 혼재된 경우

복수의 피압류채권액에 상당하는 금전이 일괄공탁되고 그 공탁금 전액(배당재단)을 일괄하여 배당등을 실시하는 경우에 있어서, 그 가운데 일부의 피압류채권액에 상당하는 공탁금에 대하여는 잉여가 생기지만, 다른 피압류채권액에 상당하는 공탁금으로부터는 잉여가 생기지 않는 경우에, 잉여가 생기는 공탁금에 대하여는 교부절차를 행하고 잉여가 생기지 않는 공탁금에 대하여는 배당절차를 행해야 하는가, 아니면 전

13) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(4), 348.

14) 東京 高平判 3·2·13(判例時報 1386号, 103.)

15) 東京地裁債權執行等手續研究會(주12), 311.

체로서 1개의 배당절차를 행해야 하는가라는 문제가 발생할 수 있다.

1개의 배당등의 절차에 있어서, 어느 부분을 교부절차로 하고, 어느 부분을 배당절차로 하는 것은 이론적으로는 불가능하지 않지만, 일체로 된 배당재단을 둘러싸고 그와 같이 절차를 나누는 것은 실무상 반드시 바람직하지는 않으므로 전체로서 1개의 배당절차를 허용하고 있다.¹⁶⁾

6. 변제금교부계산서의 작성

가. 변제금교부계산서의 성격

집행재판소는 교부절차에 있어서는 변제금교부계산서를, 배당절차에 있어서는 배당기일에 배당표를 각 작성해야 한다(日民執 제84조 제2항, 제85조 제1항).

배당표 또는 교부계산서의 작성 자체는 재판이라고 말할 수 없다. 즉 배당표는 신고된 채권을 법규에 따른 순위등을 붙여, 또 나아가 그 채권에 대해 변제될 액을 계산한 후 이러한 사항을 기록한 문서에 불과하다.

배당표에는 진실로 그와 같은 채권이 존재하는가라는 점에 대한 판단은 포함되어 있지 않으며, 다만 배당표는 채권자 사이에서 배당을 받아야 하는 액을 협의하기 위한 일종의 제안적 성질을 가진 문서이다. 이와 같이 일종의 제안문서이지만, 이것 역시 집행처분의 일종이므로 작성연월일 및 재판소의 표시를 하고, 집행재판소를 구성하는 재판관이 기명날인한다.¹⁷⁾ 그리고 변제금교부계산서의 성격도 위 배당표에 준한다.

나. 변제금교부계산서의 작성시기

배당표의 작성시기에 대하여 일본 민사집행법 제85조 제1항은 “배당기일”이라고 규정하고 있지만, 변제금교부계산서를 작성하는 시기에 대하여는 명문의 규정이 없다.

그러나 변제금교부절차를 원활히 하기 위해서는 변제금교부일까지 작성해두는 것이 바람직하다. 또 배당표에 대하여도 배당기일에 닥쳐서 그것을 작성하는 것은 노력과 시간적 제한 때문에 불가능하므로 실무상 배당기일의 수일 전에 배당표의 원안이 작성되어 있는 것이 통례이다.

16) 東京地裁債權執行等手續研究會(주12), 312.

17) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(3), 366.

다. 변제금교부계산서의 내용

배당표 원안은, 채권계산서나 압류명령 등을 자료로 하여, 민법, 상법 그 밖의 법률이 정한 바에 따라 배당의 순위 및 액을 결정하여 작성된다(日民執 제85조 제5항 후단).

교부계산서에 대하여는 특별한 정함이 없지만, 위 배당표에 준하여 작성된다. 다만 배당절차에 있어서는 배당기일에 전체 채권자가 출두하고 전 채권자 사이에 합의가 성립한 경우에는 그 합의에 따라 배당의 순위 및 배당액이 기재되는 경우(日民執 제85조 제5항 전단, 소위 합의배당표가 작성되는 경우)가 있지만, 변제금교부절차에 있어서는 채권자들 사이에 이해관계의 대립이 없음이 그 전제이므로 이에 상당하는 것이 존재하지 않는다.

7. 변제금교부일의 절차

배당기일은 「기일」이므로 사건의 呼唱에 의해 개시되어짐에(日民執 제20조, 日民訴 제155조) 반해, 변제금교부일은 그 기일이 없으므로¹⁸⁾ 그 필요가 없고 정한 일시의 도래와 함께 바로 변제금 또는 잉여금을 교부함으로써 족하다.

재판소서기관은 배당기일에 있어서 그 조서를 작성해야 하지만(日民執規 제12조), 변제금교부일에는 그 필요도 없다.

배당표가 작성되면, 집행재판소는 배당등을 받을 채권자의 채권에 대하여 배당이의의 신청이나 배당의 실시를 유보해야 하는 사유가 없는 한 배당기일등에 배당금 또는 변제금의 교부를 실시한다(日民執 제84조 제2항, 제89조 제2항, 日民執規 제61조). 그 구체적인 절차로는 배당재단이 공탁된 경우에 재판소서기관은 공탁금의 지급위탁서를 공탁소에 송부하고, 배당등을 받을 수 있는 채권자에게는 배당등의 액을 기재한 증명서를 교부한다. 채권자는 이 증명서를 공탁소에 제출함으로써 현실로 배당등을 받는 것이 가능하다. 또, 배당재단이 집행재판소에 보관금으로서 확보되어 있는 경우에는 재판소서기관은 보관금청구서에 지급인을 압납하고 이것을 보관표와 함께 세입세출외현금출납공무원에게 송부되며, 채권자는 출납공무원으로부터 수표로서 현실적인 배당등을 받게 된다.

18) 변제금교부절차가 「기일」로 되어 있지 않은 것은, 채권자 사이에 다툼이 생길 여지가 없고, 채무자가 배당이의의 신청을 하는 것도 인정되지 않으므로 이해관계인을 한꺼번에 모이게 하는 기일을 열 필요성이 없다고 본 때문이다. 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(4), 241-242.

이러한 배당금등의 교부가 정당화되는 것은 그 기일 또는 날짜에(배당)이의등의 신청이 없었기 때문에 위 배당표의 기재내용이 일응의 정당성을 가지는 것으로 간주되는 것이며, 재판소가 배당표를 작성하였다는 이유로 그 내용이 정당하다고 취급되는 것은 아니다. 위 배당표등은 앞서 보았듯이 이의 있는 자가 신청하여 그 내용을 시정할 것을 예정하고 있는 일종의 제안문서로서의 성질을 가지고 있을 뿐이다.

일본 민사집행법 제91조에 해당하는 사유가 있는 경우에는 재판소서기관은 당해 채권자의 배당등의 액에 상당하는 금전을 공탁해야 하지만, 배당재단이 공탁금인 경우에는 그대로 공탁을 유지한 채 그 공탁금은 배당유보공탁으로 전화(轉化)된다고 본다. 또 집행재판소는 후일 그 공탁금에 대하여 공탁사유가 소멸한 경우 다시 배당등을 실시하게 된다(日民執 제92조).

8. 절차에 대한 불복신청

가. 절차상의 사유에 기한 집행이의

절차상의 위법(형식적 하자)을 이유로 하는 경우는 배당절차와 변제금교부절차를 불문하고 불이익을 받을 채권자 또는 채무자에 의한 집행이의 신청이 가능하다(日民執 제11조 제1항).

예컨대, 배당기일을 지정해야 함에도 변제금교부일이 지정되었다든가 또는 배당표 또는 변제금교부계산서의 채권액이나 배당등의 액이 다르게 기재되어 있다든가 혹은 집행비용액의 산정이 부당하다는 것 등이 이에 해당한다.

집행재판소는 집행이의 신청에 대해, 그 이유가 없다고 판단한 때는 결정으로 이를 각하하고, 그 각하결정에 대하여는 집행항고가 허용되지 않는다(日民執 제10조 제1항). 반대로, 집행재판소가 집행이의를 정당하다고 인정한 때에는 이미 된 집행처분을 취소하든가 또는 그것을 변경하는 등의 방법으로 그 절차를 바로잡으면 된다.

또 집행이의 신청은 배당등이 실시될 때까지 하지 않으면 그 집행절차가 종료되어 버리므로 이의신청의 이익이 없게 된다. 그리고 집행이의 신청이 있었어도 집행절차정지의 재판을 얻지 않는 한(日民執 제11조 제2항, 제10조 제6항), 집행이이는 당연히 집행정지의 효력은 없기 때문에 배당등의 실시를 저지할 수 없다.

나. 실체상의 사유에 기한 불복신청

배당절차와 변제금교부절차가 가장 다른 점은, 배당절차에서는 배당이의 신청이

가능한 반면, 변제금교부절차에서는 그것이 허용되지 않는다는 점이다(이에 대한 반대설이 있기는 함).

배당이의 신청이란, 채권자 또는 채무자가 배당기일에 있어서 집행법원이 작성한 배당표에 기재된 각 채권자의 채권 또는 배당액에 대하여 실체상의 사유를 가지고 불복을 진술하는 것이다(日民執 제89조 제1항).

이의의 이유를 진술할 필요는 없지만, 어느 채권이 부존재하는가 또는 배당액이 어느 쪽이 감소되어야 하는가 등으로 이를 구체적으로 진술할 필요가 있다.¹⁹⁾

배당이의 신청을 한 후에는 더 나아가 그에 대한 소송을 제기한 다음 집행재판소에 대해 1주일 이내(초일불산입)에 일정한 증명을 하지 않으면 배당이의의 신청을 취하한 것으로 간주되고, 당초의 배당표대로 배당이 실시되어버린다(日民執 제90조 제6항, 제89조 제2항). 따라서 배당의 실시를 저지하기 위해서는, 채권자 및 채무명의를 가지지 않은 채권자에 대하여 이의를 신청한 채무자는, 배당이의의 소를 제기해야 한다(日民執 제90조 제1항). 또한 채무명의를 가지는 채권자에 대하여 이의를 신청한 채무자는 청구이의의 소를 제기해야 한다. 그리고 위 각각의 소제기 증명을 배당기일로부터 1주일 이내에 집행재판소에 제출해야 한다. 나아가 청구이의의 소(日民執 제35조 제1항)에 있어서 채무명의를 집행력을 저지하기 위해서는 이 소에 관계된 집행정지 재판의 정보도 위 기간 내에 집행재판소에 제출해야 한다(日民執 제90조 제6항).

변제금교부절차에 있어서는 전술한 대로 배당이의 신청을 할 수 없으므로 채무자(채권자의 경우에는 집행재판소의 집행채권등 인정액에 불복이 있는 경우를 제외하고는 불복신청을 할 이익이 없다)가 교부금액을 다투기 위해서는 변제금교부일까지 다음과 같은 절차를 취해둘 필요가 있다. 즉 채무명의를 가진 채권자에 대하여는 청구이의의 소 혹은 채무명의를 가집행선고부판결인 경우에는 상소등을 각 제기한 후 이에 수반한 집행정지 또는 정지와 함께 집행취소의 재판(日民執 제36조 제1항, 日民訴 제511조, 제512조 제1항, 제512조의 제2의 제1항, 제2항)을 얻어, 이러한 정본을 변제금교부일까지 집행재판소에 제출해야 한다. 또한 채무명의를 집행증서인 경우에는 채무변제협정등의 조정을 신청하여, 이에 수반한 집행정지재판(日民調規 제6조 제1항)을 얻어, 위와 동일하게 그 정본을 제출해야 한다. 또 채무명의를 갖지 않은 채권자에 대하여는 담보권실행금지가처분정본(日民執 제193조 제2항, 제183조 제1

19) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(3), 383.

항)을 제출해야 한다.

배당이의소송의 제기증명이 있었던 경우나 집행정지재판정본의 제출이 있었던 경우에는 본안소송의 귀추가 정해질 때까지 집행재판소는 불복에 관계된 부분에 상당하는 금전을 공탁(배당재단이 공탁금인 경우에는 그대로 공탁을 유지함)하지만(日民執 제91조 제1항 각호), 그 공탁금에 대해 공탁사유가 소멸하면 다시 배당등을 실시하게 된다(日民執 제92조 제1항, 제2항).

9. 변제금교부절차와 배당절차 사이의 다른 점에 대한 도표

이상 설명한 변제금교부절차와 배당절차 사이의 주된 차이점을 표로써 그려 이를 나타내 보면 다음과 같다.

절 차	성 격	통지방법	집행재판소가 작성하는 것	배당이의 신청의 가부(可否)
배 당 절 차	절차가 엄격함	소환 (송달에 의함)	① 배당표 ② 배당기일조서	가능함
변제금교부절차	절차가 간략함	통지(상당하다고 인정되는 방법에 의함)	변제금 교부계산서	할 수 없음

제2절 채권배당과 부동산배당의 차이점에 관하여

I. 서

이하에서 채권배당과 부동산배당의 차이점에 대해 간략히 살펴보기로 하되, 이를 배당절차 실시 전의 단계, 배당절차 실시의 단계, 배당절차 실시 후의 단계로 나누어 그 특성상 주된 것들만 들추어내어 이를 부각시키는 방법으로 접근해 보기로 한다.

이러한 고찰은 채권집행절차를 이용하는 경우에 부동산집행(특히, 배당절차)과 다른 특징을 곧바로 염두에 두고 행할 수 있도록 하는 데에 도움을 줄 수 있으리라고 본다.

II. 배당절차 실시 전의 단계에서

1. 배당절차사건의 사건번호

현재 부동산집행사건의 경우, 강제경매와 담보권실행경매를 불문하고 그 사건번호는 「타경」으로 기록번호가 부여되고, 이후 그 사건이 종료할 때까지 변하지 않으므로 배당절차에서도 그 번호 그대로 절차가 진행된다.

하지만 채권집행사건에서는 앞서 본 바대로 그 절차가 반드시 배당등으로 종료되는 것은 아니며, 압류절차와 배당등의 절차가 서로 분리되어 있으므로 압류절차사건에 부여된 사건번호로 배당등의 절차가 진행되는 것은 아니다. 그리하여 압류절차사건의 경우 그 사건번호는 「타채」로 붙여지지만, 배당절차의 경우는 공탁사유신고 등이 있을 때에 사건번호가 부여되고, 그 번호 또한 독립한 채권배당사건으로 「타배」라고 붙여져서(사건명은 ‘배당절차’라고 한다) 이에 의해 배당절차가 행해지는 것으로 된다.

2. 배당실시의 가능 여부에 대한 판단

가. 대금납부 및 공탁 장소의 차이(사유신고의 필요성)

부동산배당절차에서는 대금납부절차를 집행법원이 행하고, 대금을 납부하는 곳도 집행법원이기 때문에 집행법원으로서 매수인이 대금을 납부하였는지 아닌지를 곧바

로 인식할 수가 있고, 그에 따라 대금 납부 후 신속하게 배당절차를 진행하는 것이 가능하다.

그러나 채권배당절차에서는 제3채무자가 압류에 관련된 금액을 공탁하더라도 그 공탁금의 보관과 관리는 공탁관이 하고 있으므로 그 공탁 여부를 집행법원 측에서 곧 파악하기란 어렵다. 집행법원이 그것을 알기 위해서는 제3채무자로부터 사유신고서의 제출이 필요하다. 그것에 의해서 집행법원은 비로소 공탁금의 존재를 알고 배당등의 절차를 진행하는 것이 가능하게 되는 것이다.

나. 공탁금이 압류의 대상인가 여부의 판단

부동산배당절차에서는 대금이 납부되면 바로 배당등의 절차로 진행하는 것이 원칙이다. 따라서 집행법원으로부터 배당기일 등에 대한 통지가 올 때까지 압류채권자 측에서 어떠한 액션을 취할 필요는 없는 것이다.

그런데 채권배당절차에서는 제3채무자의 공탁금이 채권압류명령에서 압류의 대상으로 되어 있는지 어떤지에 대한 판단을 할 필요성이 있다. 왜냐하면 채권은 관념적인 것으로서 그 공시성도 충분하지 않기 때문에 채권자가 압류의 대상으로 들고 있는 채권의 특정도 완벽한 것은 아니고, 이에 따라 제3채무자측에서도 착각 등으로 인해 압류된 채권과 다른 채권에 대하여 발생한 금전을 공탁해버리는 사례가 나타날 수 있기 때문이다. 가령 압류된 채권과 다른 채권이 공탁된 경우에는 그것을 배당재단으로 하여 배당등의 절차를 실시할 수 없기 때문에 불수리조치로써 그 공탁금을 제3채무자에게 환부하는 절차로 이행할 수밖에 없다. 그리고 혼합공탁의 경우에는 이른바 혼합해소문서가 제출되지 않으면 배당등의 절차를 실시할 수가 없다. 그러므로 이와 같은 경우에는 부동산배당절차와 달리 압류채권자로부터 그에 맞는 어떠한 행위가 없는 한 절차를 진행할 수가 없게 되는 것이다.

다. 무잉여 집행금지제도와 관련하여

부동산집행절차에서는 압류채권에 우선하는 채권 및 절차비용 등을 합한 금액을 변제하는데 부족하지 않는 경우가 아닌 한 원칙적으로 집행절차는 진행되지 않게 된다(민집 제91조 제1항).

이에 반해, 채권집행절차에서는 집행비용 외에 남을 것이 없는 경우에만 절차를 진행할 수 없을 뿐(민집 제188조 제3항), 압류채권자의 채권에 우선하는 다른 채권의 존재 여부는 무잉여 판단에서 고려되지 아니한다는 점에서 그 차이가 있다.

3. 배당재단에 관하여

가. 배당재단의 형성

부동산배당절차에 있어서는 부동산의 매각대금이 배당재단의 중심을 이루고 법원에 납부된 그 매각대금 전부(이는 법원보관금이 됨)가 배당재단으로 된다.²⁰⁾

이에 대해 채권배당절차에서는 공탁금이 배당재단의 중심을 이루는데, 다만 권리 공탁(민집 제248조 제1항)과 같은 경우에는 채권의 일부가 압류된 때에도 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁할 수 있으므로 그 공탁금 전액이 배당의 범위가 된다고 단정할 수는 없다.²¹⁾

나. 배당재단의 확정

부동산배당절차의 배당재단은 주로 보관금으로서 이는 집행법원이 직접 별단에 금으로 예탁하여 보관·관리하므로 그에 대하여 예탁한 날부터 이자가 발생하는데(법원보관금취급규칙 제7조 참조), 그 이자 중 배당기일까지의 이자에서 이자소득세를

20) 다만 배당재단을 구성하는 금원이 본래 법원보관금이었다고 하더라도 민사집행법 제160조에 의하여 공탁된 후에는 그 배당액의 성격도 공탁금으로 변경되므로 공탁금의 출급절차에 따라야 한다.

21) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결【판결요지】[1] 공탁은 공탁자가 자기의 책임과 판단하에 하는 것으로서 공탁자는 나름대로 누구에게 변제하여야 할 것인지를 판단하여 그에 따라 변제공탁이나 집행공탁 또는 혼합공탁을 선택하여 할 수 있고, 제3채무자가 변제공탁을 한 것인지, 집행공탁을 한 것인지 아니면 혼합공탁을 한 것인지는 피공탁자의 지정 여부, 공탁의 근거 조문, 공탁사유, 공탁사유신고 등을 종합적·합리적으로 고려하여 판단하는 수밖에 없다. [2] 민사집행법 제248조 제1항은 “제3채무자는 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁할 수 있다”고 규정하여 채권자의 공탁청구, 추심청구, 경합 여부 등을 따질 필요 없이 당해 압류에 관련된 채권 전액을 공탁할 수 있도록 규정하고 있는바, 이에 따라 금전채권의 일부만이 압류되었음에도 그 채권 전액을 공탁한 경우에는 그 공탁금 중 압류의 효력이 미치는 금전채권액은 그 성질상 당연히 집행공탁으로 보아야 하나, 압류금액을 초과하는 부분은 압류의 효력이 미치지 않으므로 집행공탁이 아니라 변제공탁으로 보아야 한다. [3] 집행공탁은 공탁 이후 행해질 배당절차의 진행을 전제로 한 것인데, 처분금지가처분은 그것이 실행 금전채권을 목적으로 하더라도 이러한 배당절차와는 관계가 없으므로 제3채무자로서는 이를 이유로 집행공탁을 할 수는 없고, 다만 채권자불확지에 의한 변제공탁을 할 수 있다. [4] 민사집행법 제247조 제1항 제1호가 압류채권자 이외의 채권자가 배당요구의 방법으로 채권에 대한 강제집행절차에 참가하여 압류채권자와 평등하게 자신의 채권의 변제를 받는 것을 허용하면서도, 다른 한편으로 그 배당요구의 종기를 제3채무자의 공탁사유 신고시까지로 제한하고 있는 이유는 제3채무자가 채무액을 공탁하고 그 사유 신고를 마치면 배당할 금액이 판명되어 배당절차를 개시할 수 있는 만큼 늦어도 그 때까지는 배당요구가 마쳐져야 배당절차의 혼란과 지연을 막을 수 있다고 본 때문이다. 따라서 민사집행법 제247조 제1항에 의한 배당가입차단효는 배당을 전제로 한 집행공탁에 대하여만 발생하므로, 집행공탁과 변제공탁이 혼합된 소위 혼합공탁의 경우 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여는 제3채무자의 공탁사유신고에 의한 배당가입차단효가 발생할 여지가 없다.

원천징수한 잔액은 당연히 배당할 금액에 포함된다(법원보관금취급규칙 제7조 단서).

채권배당절차에서 배당재단의 중심을 이루는 공탁금도 공탁관이 관리하기는 하지만 위와 마찬가지로 별단예금 형식으로 예탁하여 보관하므로 공탁일로부터 배당기 일까지의 이자(공탁법 제6조, 공탁금의 이자에 관한 규칙 제2조에 따라 금융통화위원회가 정하는 별단예금의 최고이자율로서 현재는 연 1천분의 5)가 나중에 덧붙여지게 되어 있다. 다만 채권집행에서는 급료채권 또는 임료채권과 같이 계속적인 급부를 목적으로 하는 채권을 압류한 경우 제3채무자는 월 급여를 매월마다 각각 공탁할 수도 있고, 수개월분의 급여를 한꺼번에 공탁할 수도 있는데,²²⁾ 전자와 같이 월급여를 매월마다 공탁할 경우 집행법원은 어느 정도 회수를 통합하여 배당절차를 실시하여야 하는바, 그렇게 한다면 통상 1회의 대금납부에 의해 배당재단액이 확정되는 부동산배당절차와 달리 채권집행에 있어서의 배당재단액은 그때까지 확정되지 않는 것으로 되는 차이점을 가져올 수도 있다.

4. 배당을 받을 채권자

가. 채권자의 확정가능성

부동산배당의 대상인 부동산은 등기기록에 의해 공시가 되고, 사건기록도 접수시부터 배당시까지 1개의 기록만이 제조되어 진행되는 것이기 때문에 우선 부동산 등기기록으로부터 담보권자 등을 들추어내고, 다음으로 사건기록을 검토하여 배당요구채권자 및 교부청구채권자 등을 가려내는 작업에 의해서 비교적 용이하게 배당을 받아야 하는 채권자의 범위를 확정할 수가 있다. 좀 더 나아가면, 집행법원만으로도 배당

22) 그러나 제3채무자가 일정한 기간 동안 압류된 급여채권을 한꺼번에 공탁하는 경우 매 급여일 이후부터 공탁할 때까지의 이행지체책임에 따른 지연손해금의 공탁 여부가 문제되고(원칙상 그 지연손해금을 함께 공탁해야 하는데도 실무에서는 이를 고려하지 않고 있는 듯하다), 또 이러한 경우 일정부분의 급여에 대하여는 변제공탁을, 다른 부분의 급여에 대하여는 집행공탁을 하여야 하는 등 급여에 따라 공탁의 성질이 다르다거나(예컨대, 종업원의 급여에 대해 甲은 2018년 4월분부터 가압류를 하고, 2018년 6월분부터는 을과 병이 다시 위 급여에 대해 각 압류를 한 경우 구 민소법 제581조 제1항의 취지에 따르면, 제3채무자인 고용주는 2018년 4월분과 5월분의 급여에 대해서는 변제공탁을 하여야 하고, 2018년 6월분부터는 집행공탁을 해야 하는 것이 원칙임), 급여마다 가압류채권자나 압류채권자 등의 이해관계인이 서로 다른 경우 이를 하나의 공탁으로 묶어서 하는 것은 공탁절차가 복잡하고 채권자들간의 권리관계를 파악하는데 어려움이 있는 등 문제점이 발생할 가능성이 크므로 위와 같은 경우에는 하나의 공탁으로 하는 것은 부적절함에도 불구하고 실무는 그 편의성을 중시하여 후자의 방법을 더 선호하고 있다(권리공탁이 인정되는 현행 집행법하에서는 위 지연손해금에 관한 점을 제외하고 다른 문제점은 해결되었다고 볼 수 있을 것이다).

을 받아야 하는 채권자를 확정할 수 있는 경우도 많다.

그러나 채권집행에 있어서는 등기기록에 상당하는 것이 없고 사건기록도 압류사건등의 모습으로 뿔뿔이 흩어져 있어서 제3채무자로부터 사유신고가 있을 때까지는 집행법원의 수중에 배당을 위해 필요한 것이 아무것도 없는 상태이므로 결국 그때까지 집행법원만으로는 배당을 받아야 하는 채권자의 범위를 확정할 수가 없는 것이다.

나. 배당요구채권자의 범위

부동산집행에서는 집행력 있는 정보를 가진 채권자, 경매개시결정이 등기된 뒤에 가압류를 한 채권자, 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자 등이 배당요구를 할 수 있지만(민집 제88조 제1항), 채권집행의 경우는 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자와 집행력 있는 정보를 가진 채권자만이 배당요구를 할 수 있다(민집 제247조 제1항).

다. 배당가입이 가능한 시기(배당가입차단호)

1) 부동산배당의 경우

배당에 가입하는 것이 가능한 시기에 관하여, 부동산집행절차에서는 집행법원에 서 압류의 효력이 생긴 때로부터 1주일 이내에 배당요구의 종기를 결정하고 이를 공고하도록 되어 있으며(민집 제84조 제1항, 제2항, 제3항), 한번 결정된 배당요구의 종기는 특별한 사정이 없는 한 변하지 않는다. 따라서 1회의 배당절차 중 배당요구의 종기는 1개뿐이다.

2) 채권배당의 경우

채권자가 제3채무자에 대한 채무자의 채권(피압류채권)을 압류한 데에 대하여 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 채무액을 공탁한 경우에는 민사집행법이 1개의 압류에 대하여도 집행공탁이 가능하도록 규정한 것(민집 제248조)과 배당절차의 개시시기를 규정하는 민사집행법 제252조의 취지에 따라 그 공탁시까지 압류 또는 가압류집행을 하지 않은 채권자는 당해 배당절차에서 배당을 받을 채권자로서의 지위를 취득할 수 없다고 보아야 한다.²³⁾

그러나 가압류집행을 원인으로 하는 제3채무자의 공탁은 그 실질상 가압류채무

23) 다만 공탁 이전에 압류명령을 얻었으나 공탁 이후 그리고 배당요구의 종기 이전에 그 명령이 제3채무자에게 송달된 채권자의 압류명령에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 것인가에 대해서는 견해가 나뉘어지고 있다.

자를 피공탁자로 하는 일종의 변제공탁이고, 그 가압류채무자가 가지는 공탁금출급청구권 위에 위 가압류집행의 효력이 이행하는 것으로 되어 있으므로(민집 제297조, 대법원 1994. 12. 13. 선고 93다951 판결), 이 경우 공탁은 그 공탁금으로부터 배당을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하는 효과를 가지지 않고, 그에 의해서 배당가입의 차단효과 발생하지도 않는다. 그리하여 이때에는 다른 채권자도 채무자가 가지는 공탁금출급청구권에 대하여 압류 또는 가압류집행을 할 수 있고, 또한 당해 가압류채권자도 본집행으로서의 압류를 하는 것이 가능하다.

그리고 이 경우에 있어서 배당가입차단효는 가압류집행을 원인으로 하여 제3채무자가 공탁한 후에 가압류채권자 또는 다른 채권자가 공탁소(공탁관)를 제3채무자로 하여 채무자가 가지는 출급청구권에 대하여 압류의 집행을 한때에 발생한다. 이는 채무자가 가지는 출급청구권에 대한 압류(그것이 가압류채권의 본집행으로서의 압류인가 혹은 다른 채권자에 의한 압류인가를 불문하고)에 의해 최초 압류명령이 제3채무자인 공탁소에 송달된 시점에 위 공탁이 민사집행법 제248조에 따른 집행공탁으로 전화(轉化)되는 것이라고 해석될 수 있기 때문이다. 이와 같이 최초 압류명령의 송달시에 배당가입의 차단효과 발생하므로 그 후의 압류 또는 가압류집행채권자는 배당을 받을 채권자가 될 수 없다.

또한 배당요구채권자는 민사집행법 제247조 제1항에 따라 ① 제3채무자가 제248조 제4항에 따른 공탁의 신고를 한 때 ② 채권자가 제236조에 따른 추심의 신고를 한 때 ③ 집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출한 때까지 배당요구를 하여야만 배당절차에서 배당을 받을 수 있고, 위의 각 시기가 바로 배당요구의 종기가 된다. 채권집행의 경우 이와 같이 배당요구채권자에 대한 배당요구의 종기가 명문으로 규정되어 있으므로 부동산집행과 달리 이에 관하여 집행법원에 의한 별도의 결정은 필요하지 않다.

나아가 급여채권등과 같은 계속적 수입채권에 있어서 만일 제3채무자가 매월마다 월 급여를 각각 공탁하고 사유신고하는 방법을 사용할 경우 그 공탁 때마다 배당요구의 종기가 정해지고, 집행법원으로서의 그 중 몇 회분의 공탁을 통합하여 배당을 실시하게 되므로 1회의 배당절차(이는 실제 수개의 배당절차가 병합되어 있는 것임) 속에는 1개가 아닌 수개의 배당요구 종기가 존재할 수도 있다는 점에서 부동산배당절차와 다른 특징을 찾아볼 수 있다.

라. 일반채권자에 대한 배당가능성

부동산집행에 있어서는 담보권실행이 중심이 되는 경우가 많고, 이러한 경우에

일반채권자에게까지 배당이 이루어지는 사례가 그리 많지 않다. 그리고 집행권원에 기초하여 강제경매를 신청한다 하더라도 무잉여로 되어 매각절차까지 진행하지 못하는 경우도 많다.

하지만 채권집행에서는 담보권자의 물상대위에 의한 압류도 있기는 하지만, 그 중심이 되는 것은 집행권원을 가진 일반채권자에 의한 집행이고, 배당도 일반채권자들 사이에서 청구채권액에 따라 안분배당되는 경우가 더 많아서 부동산집행의 경우보다 일반채권자들이 배당받을 수 있는 가능성이 상대적으로 더 높다.

III. 배당절차 실시 단계에서

1. 배당액의 지급

부동산배당절차의 배당재단은 보관금이 주된 것으로서 집행법원이 관리한다. 이 경우 채권자가 집행법원에 청구하면 법원사무관등은 소정 양식의 법원보관금 출금명령서를 출금청구자에게 교부하고, 출금청구자는 교부받은 출금명령서를 출납공무원에게 제출한다(법원보관금취급규칙 제13조 제1항, 제2항). 사건담임자는 위 출금명령서 사본을 기록에 편철한다. 위 출금명령서를 제출받은 출납공무원은 사건번호, 출금금액, 출금금의 종류 및 출금의 구분, 출금청구자 및 대리인, 출금명령일 등과 같은 법원보관금취급규칙 제13조 제3항 각 호 소정의 출급지시사항을 취급점에 전송하고 출금청구자에게 소정 양식의 출급지시서를 교부하여 이를 취급점에 제출하게 하여야 한다. 다만 동시에 수건의 출금청구가 있는 경우에는 일정한 양식의 법원보관금 출금명세서를 함께 교부한다(위 규칙 제13조 제3항). 배당수령채권자는 보관금취급점에 위 출급지시서를 제출하고 보관금을 수령하는 방법으로 배당액을 지급받게 된다. 취급점이 배당수령채권자에게 법원보관금을 배당액으로 지급한 때에는 그 지급내역을 즉시 법원사무관등(사건담임자) 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(법원보관금취급규칙 제16조).

그리고 위 부동산집행절차의 배당재단이 공탁금인 경우는 아래 채권배당의 경우와 마찬가지로의 절차를 밟으면 될 것이다.

이에 대해, 공탁금이 주된 배당재단을 이루는 채권배당절차에서는 그 보관과 관리를 공탁관이 하고 있으므로 법원사무관등은 지급할 배당금액(배당액과 집행비용의 합계액)을 적은 지급위탁서를 공탁관에게 송부하고(공탁서를 붙일 필요 없음), 지급받

을 사람에게는 지급받을 자격을 증명하는 배당액지급증(증명서)을 교부하여야 한다(민집 제256조, 제159조 제2항, 제3항, 민집규 제82조, 공탁규칙 제43조 제1항). 그 후 배당수령채권자는 공탁물출급청구서 3통(전산화가 된 곳은 2통)을 작성하고 거기에 법원사무관등으로부터 받은 증명서를 붙여 공탁관에게 제출하여 공탁금을 출급받으면 되는 것이다(공탁규칙 제43조 제2항, 제32조).

2. 배당순위의 중요성

부동산배당에 있어서는 배당을 받아야 하는 채권자가 동순위인 사례보다는 서로 다른 순위에 따라 배당되는 경우가 많기 때문에 배당의 순위는 절차에 있어서 중심적인 문제로 떠오르게 된다.

채권배당에 있어서도 배당순위라는 것은 중요한 테마의 하나이지만 앞서 본대로 일반채권자의 가담이 많은 형편이어서 부동산배당에 비해 배당순위가 문제되는 경우는 상대적으로 많지 않다.

그리고 그것 때문에 부동산배당의 경우에는 현실적으로 배당을 받을 수 있는 채권자가 상위의 배당순위에 있는 자에 한정되는 경우가 많고 그에 따라 실무상 배당을 받지 못하는 채권자를 배당표에서 생략해 버리기도 하는데 반해,²⁴⁾ 채권배당의 경우에는 그렇게 생략되는 경우가 많지 않게 된다.

3. 배당유보공탁의 문제

부동산배당에서는 이미 본대로 일반채권자에게까지 배당되어지는 경우가 채권배당보다 상대적으로 적고, 그에 따라 나중에 집행권원의 제출이 필요한 가압류채권자에게까지 배당되는 사례도 많지 않게 되어, 배당금의 지급을 할 수 없어서 배당유보공탁을 하는 사례의 대부분은 배당이의 때문이거나 또는 주택임차인 등이 목적물을 명도하지 않은 경우 등이다.

하지만 채권배당에서는 일반채권자에게까지 배당되는 것이 오히려 통례이므로 배당이 유보되어지는 것은 배당이의에 의한 경우 또는 집행권원의 미제출에 의한 경우가 그 중심을 이루고 있다.

24) 원칙은 후순위여서 배당을 받지 못하는 채권자라도 배당기일통지를 하고 또 배당표에 그 청구금액을 적은 후 배당액을 "0"으로 하여 기재하여야 하나, 실무에서는 대부분 배당기일통지는 하되, 배당표상에 그 기재는 하지 않고 있다. 이에 따라 가끔씩 추가배당이 필요하지만, 기록보존기간이 지나서 기록도 없는 경우에 그 누락된 채권자들을 찾지 못하는 사태가 발생하기도 한다.

Ⅳ. 배당절차 실시 후의 단계에서

1. 배당절차의 반복

부동산집행에 있어서는 경매신청된 여러 개의 부동산 중 일부만 매각한 다음 특히 그에 관해서만 배당절차를 진행하지 않는 한 대부분 한 개의 경매사건에 대하여 배당절차도 1회로 종료하게 된다.

이에 반해, 급여채권 등 계속적 급부를 목적으로 하는 채권을 압류의 대상으로 하는 경우가 많은 채권집행에 있어서는, 제3채무자가 월 급여를 매월마다 각각 공탁하는 방법을 이용할 경우 법원이 그 중 몇 회를 통합하여 압류채권자들의 채권이 만족될 때까지 배당절차를 실시하게 되므로 그때마다 매번 배당절차가 반복되게 되고, 이는 지금의 실무처럼 제3채무자가 일정기간 동안의 압류액을 통합하여 공탁하는 경우라도 마찬가지이다.

2. 채무자 파산의 경우

부동산집행 중에서 많은 경우를 차지하는 담보권실행경매에서는 별채권이 인정되므로 채무자의 파산으로 인해 영향을 받지 않는다.

채권집행의 경우에는 일반채권에 기해 채권압류를 신청하였는데 채무자가 파산선고를 받으면 채권압류명령이 실효되는 영향을 받게 된다. 그리고 저당권등에 기해 물상대위에 의한 채권압류를 한 경우 채무자의 파산으로 영향을 받지 않지만, 만약 동시에 부동산집행절차가 진행된 때에는 대금납부에 의해 저당권이 말소되기 때문에 그 이후 채권집행절차에서 채권회수를 도모하기가 어렵게 되기도 한다.

제3절 배당기일의 지정·통지

I. 배당법원

배당등 절차는 집행법원의 전속관할에 속하게 된다.

유체동산집행의 경우에는 압류한 곳 또는 압류물을 매각한 곳의 법원(민집 제 222조 제3항, 제3조), 즉 집행을 한 집행관의 소속법원이 배당법원이 되고, 채권 그 밖의 재산권에 대한 집행에 있어서는 압류명령을 한 법원(민집 제248조 제4항, 제 224조)이 배당법원이 된다. 다만 압류명령을 한 법원이 수개 있으면 그 중 사유신고서가 제출된 법원(민집규 제172조 제3항)²⁵⁾이 배당법원이 된다.

특별현금화명령에 의하여 현금화한 경우에는 그 현금화명령을 한 법원에 현금화된 대금이 제출되어야 하므로 그 법원이 배당법원이 되는 것이지만, 이는 결국 압류명령을 한 법원과 같다.

II. 배당기일의 지정

배당법원은 제3채무자로부터 사유신고가 제출되어지는 등으로, ① 당해 사유신고의 수리, 불수리 ② 배당등이 실시가능한가 아닌가 ③ 배당재단으로 되는 범위 ④ 배당등을 받을 채권자 등을 확인한 결과) 배당등을 실시할 수 있게 된 때에는 배당표에 대한 진술 및 배당을 실시할 기일(배당기일)을 지정해야 한다.

배당기일은 배당표에 관한 진술 특히 배당표에 대한 이의의 신청과 그 이의의 상대방이 될 채권자의 이의의 정당 여부에 대한 반대진술을 하게 하여 배당표의 당부에 대한 의견을 듣고 또 이의신청이 없거나 이의신청이 있더라도 그것이 완결된 때에는 배당표에 따라 배당을 실시하기 위한 기일을 말한다.

III. 배당기일의 통지

1. 기일통지방법 등

가. 배당법원이 위와 같이 배당을 실시할 기일을 지정한 때에는 그 기일을 이해

25) 이 경우 민사집행규칙 제172조 제3항에 따르면, 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고서를 제출하게 되어 있으므로, 결국 배당법원은 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원이 될 것이다.

관계인 및 배당을 요구한 채권자와 채무자(담보권실행에 의한 물상대위사건에 있어서는 그 소유자도 통지대상이 된다고 볼 수 있다)에게 통지하여야 한다. 다만 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지하지 아니한다(민집 제255조).

나. 배당기일의 통지는 기일통지서를 송달하는 방법으로 한다(민집 제23조 제1항, 민소 제167조 제1항). 위와 같이 배당기일을 통지하는 목적은 배당표에 기재된 각 채권자의 채권 또는 배당액에 대하여 배당이의의 신청을 할 권리(민집 제256조, 제151조 제1항, 제2항)를 보장하기 위해서이고, 그 때문에 송달이라는 엄격한 방법을 사용하고 있는 것이다. 따라서 채권자 등 전원에 대하여 송달의 효력이 생기지 않으면 배당기일을 개시할 수 없다.²⁶⁾

다. 배당기일을 통지받을 채권자에는 압류채권자, 배당요구채권자, 가압류채권자가 모두 포함되며, 청구이의의 소, 제3자 이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소의 피고로서 집행의 일시정지명령을 받은 채권자, 나아가 배당액이 없는 채권자에게도 통지하여야 한다. 그 반면, 당해 배당절차에서 배당재단으로 되어 있는 압류대상물이 아닌 다른 채권을 압류한 채권자나 배당가입차단효가 생긴 후의 압류채권자 또는 배당요구채권자 등 배당을 받을 채권자로 인정되지 않는 자에 대하여는 이러한 통지를 할 필요가 없으며, 통지 전에 채권압류명령신청을 취하한 채권자 역시 동일하다.

라. 또한 기일통지서는 채권자와 채무자의 쌍방에 대하여 늦어도 배당기일의 3일 전에 도달할 수 있도록 발송하여야 한다. 왜냐하면 배당기일 3일 전에 배당표원안을 작성하여 비치하고 채권자, 채무자가 열람할 수 있도록 하여야 하므로 배당기일로부터 3일 이내에 기일통지서가 송달되면 3일간의 배당표 열람기간이 부족하게 되기 때문이다.

마. 채권자 중 있는 곳이 분명하지 않아 기일통지서를 송달할 수 없는 경우에는 직권으로 공시송달을 하여야 한다. 그러나 앞서 보았듯이 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지하지 아니한다(민집 제255조 단서).

2. 기일통지비용 등

배당기일통지에 소요되는 우편요금 등 필요비용에 대하여는 선행 압류채권자로부터 예납을 받아 집행하고 뒤에 집행비용(절차비용)에 산입하여야 할 것이나, 다른

26) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 518.

한편 집행채권자로부터 예납을 받지 않고 배당법원의 법원사무관등이 필요한 집행비용을 미리 지급하도록 공탁관에게 그 지급을 위탁하거나 출납공무원으로부터 보관금을 출급받아 비용을 지출할 수도 있는데, 현재 실무는 대부분 후자의 방법에 의하여 처리하고 있다.²⁷⁾ ²⁸⁾

3. 기일통지와 함께 하는 최고 등

위 배당기일통지서에는 배당기일이 언제 있고, 당일 어디에 출석하면 되는가가 기재된다. 또한 채권자·채무자 등의 당사자 표시, 배당절차사건 번호 외에 배당금을 지급받기 위해 갖추어야 할 도장, 신분증, 서류(집행권원 등) 등의 지참 요망사항, 배당이의에 관한 사항 등이 표시되는 것이 통례이다.

그리고 법원은 배당등 기일이 정해진 때에는 채권자들에게 1주 이내에 원금, 이자, 비용, 그 밖의 부대채권의 계산서를 제출하도록 최고하여야 하고(민집 제253조, 채권계산서는 집행법원이 배당등의 전제로 되는 채권자의 현존 채권액을 파악하기 위한 자료로서 그 제출을 구하는 것이다), 위 최고는 적당한 방법으로 하면 되고 반드시 송달하여야 하는 것은 아니지만, 실무에서는 대부분 배당기일통지서와 함께 위 최고서를 채권자들에게 송달하고 있다.

나아가 채무자에 대한 배당기일통지서에는 그 통지 시점에서 채무자에 대한 잉여금이 생길 것이 집행법원에 명확한 경우에는 그러한 잉여금이 생길 예정인 점, 그 잉여금을 수령하기 위해서 필요로 하는 서류나 수취의 방법 등을 기재하여 송달하는

27) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 504.

28) 재판예규 제866-26호, “배당절차 사건의 집행비용과 관련된 업무처리에 관한 지침(재민 99-9)”

1. 배당절차사건의 진행을 위하여 최고서, 배당기일통지서, 사실조회서 또는 사유신고의 각하 결정 등을 송달하는 등으로 비용을 지출할 필요가 있음에도 예납된 집행비용이 없는 때에는 배당법원은 담당 법원사무관 등에게 필요한 집행비용을 미리 지급하도록 공탁공무원에게 그 지급을 위탁하거나 출납공무원에게 보관금의 출급명령을 할 수 있다.
2. 법원사무관 등은 최고서, 배당기일통지서 등 송달할 서류의 수량을 미리 확인하여 필요한 비용만을 출급함으로써 잔여액이 남는 경우가 없도록 하여야 하고, 만일 잔여액이 남게 된 경우에는 배당할 금액에 포함하여야 한다.
3. 집행비용을 출급한 후에 사유신고를 각하한 경우 등에는 이미 사용한 집행비용을 제외한 나머지 금액을 공탁자 또는 제출자에게 환급한다.
4. 공탁소가 원격지에 있어 비용출급이 곤란한 경우에는 집행채권자로부터 비용을 예납 받아 집행하고 후에 집행비용으로 산입한다.

부 칙(2002. 6. 26. 제866호)

이 예규는 2002. 7. 1.부터 시행한다. 다만 2002. 7. 1. 전에 접수된 사건에 대하여는 이 예규를 적용하지 아니한다.

것이 바람직하다고 본다.

4. 기일통지가 송달불능으로 된 경우

채권자 또는 채무자에 대하여 배당기일통지서를 송달하였는데, 채권압류명령송달 후에 주소 등을 변경한 것 때문에 “이사불명” 또는 “수취인불명” 등의 사유로 반송되어지는 경우가 있다.

민사집행법에 있어서도 민사소송법의 규정이 일반적으로 준용되어 있지만(민집 제23조), 집행절차에 있어서는 민사집행법 제14조, 민사집행규칙 제9조 등의 특별규정이 있어서, 집행에 관하여 법원에 신청이나 신고를 한 사람 또는 법원으로부터 서류(채권압류명령 등)를 송달받은 사람이 송달받을 장소를 바꾼 때에는 그 취지를 법원에 바로 신고해야 하는 것으로 되어 있고, 위 신고를 하지 아니한 사람에 대한 송달은 달리 송달할 장소를 알 수 없는 경우에는 법원에 신고된 장소 또는 종전에 송달을 받던 장소에 대법원규칙이 정하는 방법(등기우편)으로 발송할 수 있으며, 위 규정에 따라 서류를 발송한 경우에는 발송한 때에 송달된 것으로 본다고 규정되어 있다. 따라서 이러한 경우에는 위 규정에 의해 등기우편을 발송할 때에 송달이 있었던 것으로 간주되므로 현실적으로 우편물을 수령하였는가 아닌가에 구애됨이 없이 배당절차 상으로는 수령한 것으로 간주되어 그 이후의 절차가 진행된다.

제4절 채권계산서의 제출

I. 서

배당등 기일이 정해지면, 법원사무관등은 배당표 작성을 위한 준비로서 채권자들에게 1주 이내에 원금·이자·비용, 그 밖의 부채채권의 계산서를 제출하도록 최고하여야 한다(민집 제253조, 민집규 제185조 제2항).²⁹⁾

집행법원이 이와 같이 채권자에 대하여 채권계산서 제출을 최고하는 것은, 채권자는 집행관에게 유체동산의 집행을 신청할 때나 집행법원에 압류명령을 신청할 때 또는 배당요구를 할 때 그 청구채권의 내용과 액수를 그 신청서에 적어 기록상 나타나게 되나, 그 후 배당을 실시하기 전에 변제 등으로 그 채권의 전부 또는 일부가 소멸될 수도 있고, 이자 그 밖의 부채채권이나 집행비용과 같이 기록상 분명하지 않은 부분도 있으며 당초에 적은 채권의 내용에 오기가 있을 수 있으므로 배당을 실시하기에 앞서 채권자들에게 다시 계산서를 제출하도록 하여 그 결과를 배당표등에 반영시키기 위함이다.

다음에 보듯이, 제출기한 경과 후에 제출된 채권계산서도 무효는 아니고 그 내용은 배당표등에 반영하게 되지만, 제출이 늦어지면 그만큼 배당표원안의 작성이 늦어지거나 경우에 따라서는 배당기일에 맞추지 못하는 경우도 있을 수 있기 때문에 그런 의미에서 위 제출기한을 엄수할 필요가 있다.

II. 최고의 상대방 및 최고 방법 등

1. 최고의 상대방

법원사무관등이 최고를 하여야 할 상대방은 배당에 참가할 수 있는 채권자 전원이다. 즉 압류채권자, 가압류채권자, 배당요구채권자, 교부채권자 그 밖에 법률상 배당요구와 동일한 효력을 가진 신청을 한 채권자 등이 이에 해당한다.

또한 집행정지를 받은 채권자도 이해관계인에 포함되므로 위 최고를 하여야 한

29) 위 민사집행법 제253조는 부동산에 대한 강제집행에서 법원사무관등이 계산서 제출을 최고하는 것과 다르게 규정(민집규 제81조)되어 있으나, 민사집행규칙 제185조 제2항은 이 계산서제출의 최고는 집행절차에 관한 것에 불과하므로 계산서제출의 최고를 법원사무관등이 할 수 있도록 위임하고 있다.

다.³⁰⁾ 법원은 사유신고서, 공탁서, 사실조회회답, 배당요구신청서 그 밖에 집행기록에 의하여 위와 같이 배당에 참가할 수 있는 채권자를 조사한 다음 이들 모두에게 최고를 하여야 한다.

그리고 배당에 참가할 수 있는 채권자는 위 최고를 기다리지 않고 스스로 계산서를 제출할 수도 있다.

2. 최고의 방법

최고는 적당한 방법으로 하면 되고 반드시 송달해야 하는 것은 아니나, 실무에서는 배당기일통지서와 함께 또는 그 통지 전에 최고서를 채권자들에게 송달하고 있다.

위 최고서에는 최고서를 송달받은 날로부터 1주 이내에 채권의 원금·이자·집행비용, 그 밖의 부대채권에 관한 요구액을 적은 계산서를 제출할 것을 최고하는 취지를 적고 법원사무관등이 기명날인한다(민집규 제185조 제2항 참조).³¹⁾ 여기에서, 1주일의 기간은 특수한 최고기간으로 법원은 그 기간을 늘일 수는 있으나 줄일 수는 없고, 또 이 기간은 불변기간이 아니므로 추후보완이 인정되지 않는다.³²⁾ 그러나 뒤에 보듯이 위 1주일의 기간이 지났다는 사실만으로 채권자에게 실권의 효과가 생기는 것은 아니므로³³⁾ 배당표 작성시까지 계산서를 제출할 수 있고 또 제출한 계산서에 적은 채권액을 보완할 수 있게 된다.

최고서 송달비용 등 위 최고에 필요한 비용은 선행 압류채권자로부터 예납을 받아 집행하고 뒤에 집행비용에 산입하여야 할 것이나, 대부분의 실무는 위와 같은 방법 보다는 배당법원의 법원사무관등이 필요한 집행비용을 미리 지급하도록 공탁관에게 그 지급을 위탁하거나 출납공무원으로부터 보관금을 출급받아 비용을 지출하는 방법을 사용하고 있다.³⁴⁾

Ⅲ. 채권계산서로 인정될 수 있는 채권의 범위

채권자가 채권계산서에 기재한 금액이 배당표에 기재되는 청구채권액으로서 어

30) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 504.

31) 별지서식 [10-1] 배당절차 계산서제출의 최고서 참조(제10장 말미 수록)

32) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 504.

33) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 504.

34) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 504.; 앞서 본 재판예규 제866-26호, “배당절차 사건의 집행비용과 관련된 업무처리에 관한 지침(재민 99-9)” 참조

는 범위까지 인정되는가라는 문제는, 채권배당의 경우 청구채권액을 기초로 안분하는 사례가 대부분이고, 위 청구채권액이 배당기준액으로 반영되게 되므로 채권자에게는 관심이 높은 사항이 될 수 있다.

1. 원금의 경우

원금에 대하여는 채권압류명령에 청구채권으로서 기재된 것에 한정하고, 채권계산서로써 이를 확장할 수 없다.³⁵⁾

따라서 일부청구의 경우에는 이를 기초로 원금을 적어야 하고 채권계산서의 단계에서 확장할 수 없으며, 잔여의 채권부분에 대하여도 배당을 받으려고 한다면 공탁되기 전에 새로이 압류를 하거나 혹은 배당요구를 해둘 필요가 있다.

또한 채권압류명령에서 원본밖에 청구하지 않은 경우에 채권계산서에서 이자, 손해금 등을 청구할 수 없다.

2. 부대청구의 경우

가. 채권압류에 있어서 완제일까지의 부대청구(이자, 지연손해금 등)를 인정해야 한다는 견해도 있어 보이나, 대부분의 실무는 압류명령신청의 청구금액 중 지연손해금을 위와 같이 완제일까지라고 하여 구할 경우 제3채무자의 입장에서 볼 때 그 지급이 금지되는 범위가 분명하지 않다는 등의 이유로 신청 당시까지의 구체적인 금액을 계산하여 확정액으로 표시하도록 하고 있다.³⁶⁾ 즉 일부청구가 통례인 것이다.

이에 관해서는 압류명령에 있어서 집행채권의 범위가 확정적이지 않으면 제3채무자의 부담이 증가하고 타당성을 결하는 경우가 많은바, 이는 압류명령이 발하여진 경우 채권자는 추심명령을 얻어 다른 경합하는 채권자가 없는 한 피압류채권으로부터 자기 채권의 한도(집행채권 및 집행비용)에서 추심하는 것이 인정되지만, 이러한 때에 제3채무자에게 부대채권액을 계산하도록 요구하는 것은 적절하지 않기 때문에 위 청구금액을 확정하도록 하는 것이 실무상 오랜 관행이 되어 왔다고 설명하는 견해도 있다.^{37) 38)}

35) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 505.

36) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 309. 예컨대, “금 1,000만 원(대여금), 금 20만 원(위 금원에 대한 2018. 5. 8.부터 2018. 8. 8.까지(신청시)까지의 연 %의 이자 및 지연손해금), 합계 금 1,020만 원”과 같이 표시한다.

37) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 113-114.

38) 그러나 압류명령의 경우에도 압류신청시가 아니라 위와 같이 완제시까지의 이자 및 지연손해금을 청구할 수 있는지 여부에 관하여는 여전히 논란이 되고 있고, 이를 인정하는 듯한 판례도 있기는 하지만(대법원 1999. 12. 10. 선고 99다36860 판결 참조), 이 판례가 이에 대하여 직접적으로 판단하고 있는 것은 아니라고 본다.

나. 그러나 이와 같이 채권압류명령의 신청일까지 부대청구를 한정한다는 견해를 취하더라도 나중에 채권계산서를 제출할 때에 배당기일까지 위 부대청구를 확장할 수 있는가에 관하여는 실무상 이를 긍정하는 견해³⁹⁾와 이를 신청시의 채권액에 한정하는 견해⁴⁰⁾가 나타나고 있다.

살피건대, 전자의 견해는 채권압류명령시와 다르게 배당시에는 제3채무자의 부담이라는 문제도 없기 때문에 확장을 인정해도 될 것이라는 점을 전제로 하고 있다고 보이지만, 채무자가 제3채무자로부터 추심한 경우에는 신청시의 청구채권에 한정되던 것이 배당할 경우에는 그에 한정되지 않는다고 설명하는 것은 적절하지 않다고 생각한다. 따라서 배당에 있어서 청구채권액도 압류명령신청시의 청구채권액과 동일하다고 보는 후자의 견해가 타당하다고 본다.

다. 그리고 비용은 집행비용으로서 우선변제를 받을 비용뿐 아니라 우선변제가 인정되지 아니하는 비용 예컨대 배당요구서에 붙인 인지대나 서기로 등 배당절차에 참가함으로써 생긴 비용도 포함된다. 그 밖의 부대채권으로는 소송비용확정절차에 의하여 확정된 본안소송비용 등이 있다.

라. 위와 같은 계산서에는 소명자료를 붙일 필요가 없으나, 집행비용이나 부대채권과 같이 기록상 분명하지 않은 것에 대하여는 소명자료를 붙여야 배당법원으로부터 채권액으로 인정받을 수 있고, 배당법원도 그러한 경우 소명자료의 제출을 요구할 수 있다(실무상 채권압류명령에서 인정된 집행비용은 배당표상 채권금액란의 비용항목으로 인정해주고 있으나, 그 이후에 지출되어졌다고 주장하는 집행비용에 대하여는 소명자료를 제출하지 않은 경우 이를 인정하지 않고 있다).

3. 가압류채권자의 경우

가압류채권자로서 배당가입하고 있는 경우에는 그 청구채권액은 가압류결정에 있어서의 청구채권(피보전채권)에 한정되고, 가령 그것을 초과하는 액의 집행권원(판결 등)을 얻었어도 그 집행권원의 액에 의하는 것은 아니다.⁴¹⁾ 이 경우 배당액은 가압류채권액 한도에서 인정된다.

39) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 505.

40) 近藤基 編, (實務)債權配當の基本問題, 民事法研究會(平成 13), 101-102.

41) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 505.; 日最判 昭和 35(1960). 7. 27.(民集 14-10, 1894) 참조

IV. 채권계산서의 기재방법

1. 사건번호, 작성자의 표시 등

가. 채권계산서에는 집행법원이 사건을 특정할 수 있도록 배당등 사건의 사건번호를 기재한다.⁴²⁾ 위 사건번호는 배당등 기일통지서에 기재되어 있으므로 그 사건번호를 기재하면 될 것이다.

나. 그리고 채권계산서의 작성명의인은 채권자 본인 또는 그 대리인이다. 대리인이 작성한 경우에는 대리인의 성명뿐만 아니라 채권자의 명칭 또는 성명까지 명확하게 표시해둘 필요가 있다(예컨대, 「채권자 김갑동 대리인 이을동」이라고 표시한다). 또 대리인은 아니지만 대외업무 담당자가 별개로 있는 경우에는 그 자의 이름도 기재해 두면 집행법원 측에서 연락이 용이하므로 채권자로서도 편리할 것이다.

다. 법인의 경우에는 본점 소재지, 상호, 대표자의 자격(대표이사, 이사 등) 및 이름을 기재한다. 또한 채권압류명령신청 후에 주소나 대표자의 변경이 있는데 그 취지의 신고를 하지 않은 경우에는 채권계산서 제출시에 그 취지의 신청서와 변경의 사실을 증명하는 서면(자격증명서 등) 등을 제출한다. 이 신고는 이후 배당 실시 때의 지급위탁서나 증명서(배당액 지급증)에 반영될 것이다. 그리고 자연인의 경우에는 주소와 이름을 기재하고, 채권압류명령신청 후에 주소의 변경이나 이름의 변경 등이 발생하였는데 그 취지의 신고를 하지 않은 경우에는 그 취지의 신청서와 호적등본이나 주민등록등초본 등을 함께 제출한다. 이 신고가 배당 실시 때의 지급위탁서등에 반영되어지는 것은 위 법인의 경우와 동일하다.

라. 채권계산서에 사용되는 인장은 채권압류명령신청서에 사용하였던 인장과 동일한 것을 사용해야 함이 원칙이다. 분실 등에 의해 채권압류명령 신청서에 사용한 인장을 날인할 수 없는 경우에는 그 본인에 대한 확인이 필요하고, 우편 등으로 채권계산서를 제출한 경우에는 본인의 의사확인을 위해 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 첨부한 후 그 등록인감을 날인하는 것이 좋을 것이다(다만 실무에서는 대부분 이 경우에도 유선 등으로 확인하는 절차를 많이 취하고 있다).

42) 별지서식 [10-2] 채권계산서 참조(제10장 말미 수록)

2. 청구채권의 특징

채권계산서에 기재하는 청구채권은 채권의 종류 및 금액 그 밖의 채권을 특정하기에 족한 사항을 명확하게 하여 표시하여야 한다. 원금 외에 이자, 지연손해금도 합하여 청구하고 있는 경우에는 발생기간, 일수, 이율 및 이자, 손해금 별로 특정한다.

가. 채권발생 연월일 및 그 원인 등

금전소비대차, 매매대금 등의 채권발생의 원인으로 된 사실 및 그 날짜를 기재한다. 예컨대, 2018. 10. 23.자 금전소비대차, 2018. 10. 31.자 매매계약 등으로 기재한다.

나. 원금 현재액

채권계산서를 작성하는 시점에서의 원금잔존액을 기재한다. 또, 채권이 복수 있는 경우에는 원금과 이자 등의 관계를 명확하게 하기 위해서 원금번호도 기재한다. 앞서 본대로, 가압류채권자가 본안의 집행권원을 취득하여 배당받는 경우 청구채권으로 되는 것은 가압류의 피보전채권액에 한정되므로 가령 본안에 의한 집행권원의 채권액 쪽이 많아도 그것을 기재해서는 안된다.

다. 이자, 손해금 등

이자, 손해금 등을 청구하는 경우에는 기간으로서 시기와 종기 및 일수를 기재한다. 일수를 기재함에 있어서는, 이자 또는 손해금의 이율이 일을 기준으로 된 경우나 1년을 365일로 하는 특약이 있는 경우에는 단지 일수만을, 예컨대 「75일」 등으로 기재하고, 그 특약이 없는 경우에는 1년에 차지 않은 기간에 대하여 일할계산하게 되므로 예컨대 「2년 105일」 등으로 기재한다. 또 채권이 복수인 경우에는 원금번호도 기재하여 어느 원금에 대한 이자, 손해금인가를 명확히 할 필요가 있다.

이미 본대로 배당의 기초가 되는 이자, 손해금의 액은 신청서 기재의 이자, 손해금의 액이 된다.

그리고 이자, 손해금에 대하여는 그 비율을 기재한다. 그런데 대부분의 경우 위 비율은 연리로 되어 있다. 그래서 이자, 손해금에 대하여 1년에 차지 않은 이자 또는 손해금을 계산하는 경우, 평년에 속하는 기간은 이율을 365일로 나누고, 윤년에 속하는 기간은 연이율을 366으로 나눈 이율을 각각 1일에 해당하는 이율로서 일할계산하게 된다. 또한 윤년에 속하는 기간에 해당하는가 아닌가는 그 기간에 2월 29일이 포함되어 있는가 아닌가에 불구하고, 위 2월 29일이 당해 년에 걸린 경우에는 이를 윤

년으로서 계산하는 견해가 다수이지만, 이와 달리 위 2월 29일이 계산의 대상으로 되는 기간에 포함되어 있지 않으면 이를 윤년으로 보지 않는 견해도 있어 보인다.

위와 같은 내용에 대하여는 다른 특약을 하는 것이 가능하고, 특약이 있는 경우에는 그에 따라 계산하게 되므로 채권계산서에도 그 특약의 내용을 표시해야 한다. 이와 같이 1년을 365일로 하는 일할계산특약이 있는 경우, 전술한 대로 「75일」로 일수만을 기재한 다음, 그 옆의 적당한 여백에 「연 365일의 일할계산 특약 있음」 등으로 기재하면 좋을 것이다. 그리고 1년에 차지 않는 단수기간에 대하여 1년을 365일로 하는 일할계산특약이 있는 경우, 특약이 없는 경우와 동일하게 「○년 ○○○일」과 같이 기재한 다음, 그 옆의 적당한 여백에 「1년에 차지 않는 단수기간에 대하여 1년을 365일로 하는 일할계산 특약 있음」 등으로 기재한다. 이 경우에 있어서는 그 단수기간에 대하여 평년에 속하는 기간과 윤년에 속하는 기간의 유무에 불구하고, 1년을 365일로서 일할계산하게 된다.

채권계산서에는 이와 같은 일수, 이자 또는 손해금의 이율에 기초하여 산출된 이자, 손해금의 현존하는 액을 기재해야 한다.

라. 현존하는 채권액 확정시 유의사항

1) 제3채무자로부터 추심을 한 경우

압류채권자가 제3채무자로부터 채권액을 지급받은 때에는, 바로 그 추심한 채권액을 집행법원에 신고해야 한다(제236조 제1항).

이 신고는 사건의 표시, 채권자·채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급을 받은 금액과 날짜를 기재한 서면으로 해야 한다고 민사집행규칙 제162조 제1항에 규정되어 있고, 실무상 이 서면을 추심신고서라고 부르고 있다.

그런데 실무상으로는 추심신고서를 제출하지 않은 경우가 많고, 한편 채권계산서에는 추심 후의 남은 채권액을 기재하기 때문에 집행법원에서 보아 그 파악이 어려울 경우도 있다. 따라서 추심을 한 경우에는 추심액을 확인함과 동시에 추심신고서의 제출을 빠뜨리지 않도록 해야 한다.

그리고 압류에 기초하여 추심이 된 경우 청구채권에 대하여 법정충당(민법 제461조, 제477조, 제479조)하게 되므로⁴³⁾ 집행비용, 이자 또는 손해금, 원금 순으로

43) 日最判 昭和 62(1987). 12. 8.(民集 41-8, 1592; 判時 1262, 102)은, 부동산경매절차에 있어서 배당금의 충당방법에 대하여, 동일 담보권자에 대한 배당금이 그 담보권자가 가지는 수개의 피담보채권 모두를 소멸시키기에 족하지 않은 때에는 위 배당금은 위 수개 채권에 대하여 일본 민법 제489조 내지 제491조(우리 민법 제461조, 제477조, 제478조, 제479조)의 규정에 따른 변제충당이 되어야 하는 것이라고 판시하고 있다.

충당한 후 남은 채권액을 기재해야 한다.

또 임의변제의 경우에는 법정충당의 제약을 받지 않기 때문에 채권자와 채무자 사이에서 충당의 특약이나 채무자로부터의 충당지정이 존재하지 않는 한, 채권자의 충당방법에 의한다(민법 제476조). 나아가 충당이 행하여진 경우에는 채권계산서의 적당한 여백에 변제 등이 된 금액, 그 사유, 변제 등이 있는 날짜, 충당방법을 기재한다. 수회에 걸쳐서 변제 등을 받은 경우에는 충당관계에 관련된 일람표를 첨부해도 좋다.

2) 계속하여 배당을 받는 경우의 절차비용

채권자가 배당등 절차에 있어서 절차비용(주로 배당등 기일의 통지비용, 지급위탁서 송부비용 등)의 상환을 받는 경우, 이 비용분에 대하여는 채권압류명령의 청구채권과는 별개의 비용이므로 이를 청구채권에 충당할 필요는 없다.

3. 집행비용

공익비용이 아닌 집행비용을 청구하는 때는 그 액을 기재한다. 다만 채권자가 압류명령신청시에 집행비용을 청구하지 않은 경우에는 이를 인정하지 않는 것이 대부분의 실무이다.

또한 공익비용으로 되는 집행비용(절차비용)은 집행법원이 직권으로 인정하므로 이를 채권계산서에 기재할 필요가 없다.

4. 집행권원, 가압류명령 또는 담보권의 표시

가. 강제집행에 의한 압류채권자(집행권원에 의한 배당요구채권자를 포함)의 경우

이 경우는 집행권원의 특징에 필요한 최소한의 기재를 한다. 예컨대, 집행권원이 판결이라면, “○○지방법원 2018. 3. 25. 선고 2018가단○○○ 판결”로 기재하고, 공정증서라면 “공증인 법무법인 ○○○ 작성의 2018년 제3586호 금전소비대차계약 공정증서” 등으로 기재한다.

나. 가압류채권자의 경우

가압류채권자의 지위에 기하여 배당가입을 한 때에는 당해 가압류명령을 발한 법원과 사건번호를 기재한다. “예컨대, ○○지방법원 2018. 3. 25.자 2018가단○○○호 채권가압류결정”등으로 기재한다.

채권계산서 작성 시점에서, 가압류채권자가 본안의 집행권원을 취득한 경우에는

당해 집행권원도 함께 기재한다. 예를 들어, “○○지방법원 2018. 3. 25.자 2018카단○○○호 채권가압류결정, 본안판결(○○지방법원 2018. 10. 31. 선고 2018가단○○○호 대여금사건 판결)” 등으로 기재한다. 채권계산서작성 시점에는 본안의 집행권원이 없지만, 배당기일까지 이를 취득할 수 있는 경우에는 그 취지를 비고란에 기재해 두어도 좋을 것이다.

또한 가압류채권자가 배당등 기일에 현실적으로 배당을 받기 위해서는 당해 집행권원의 집행력 있는 정본(예를 들어, 집행문이 부여된 판결정본 등)과 송달증명서의 제출이 필요하므로 이것이 모두 취득된 경우에는 채권계산서와 동시에 제출해도 된다.

다. 담보권자의 경우

당해 담보권 설정등기의 연월일 및 등기번호, 담보권의 종류(저당권 등)를 기재한다.

또 저당권 등의 양도에 의한 처분이나 대위변제 등이 되어 있는 경우에는 그 부기등기도 병기한다. 예컨대, “○○등기소 2018년 ○월 ○일자 제○○○호 저당권(주등기), 2018년 ○월 ○일자 제○○○호 저당권이전(부기등기)” 등으로 기재한다. 그리고 근저당권의 경우에는 채권최고액도 함께 기재한다.

V. 채권계산서를 제출하지 않는 경우의 조치

채권계산서를 제출하지 아니한 채권자라도 그 때문에 권리를 잃거나 배당에서 제외되는 것은 아니다.⁴⁴⁾

채권계산서의 제출이 없는 경우 집행법원으로서 다른 자료(배당요구서, 사유신고서), 채권압류명령신청사건 기록이나 전회의 배당표 등을 참고하여 배당표를 작성하는 수밖에 없다.

제출하지 않은 채권자에 대하여 배당금의 수령권을 포기한 것으로 배당표에서 삭제하거나 채권액을 “0”으로 할 수는 없기 때문이다. 이 경우 채권자는 다시 채권액을 추가하지 못한다(민집 제254조 제2항).

44) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 506.

제5절 배당재단

I. 서

채권배당절차는 집행법원이 배당재단(배당의 기초가 되는 금전⁴⁵⁾)을 채권자에게 분배하는 절차라고 말할 수 있다. 따라서 배당등 절차를 진행함에 있어서는 그 실시 때마다 배당재단을 확정하는 것이 필요하게 된다.

채권배당절차에 있어서 배당재단으로 되는 것으로는 공탁금과 보관금이 있다. 공탁금은 공탁법의 규정에 기초하여 공탁소에서 취급하는 것이고, 배당등의 실시는 집행법원이 공탁소(공탁관)에 대해 지급위탁을 함으로써 행해진다. 보관금은 법원보관금 취급규칙에 따라서 취급되며, 배당등의 실시는 집행법원의 출금명령에 의해 직접 채권자에게 지급하거나 혹은 그에 대해 은행 등의 예금계좌에 입금시키는 방법에 의해서 행해지게 된다.

이하에서는 우선 부동산배당절차에 있어서 배당재단과의 차이점을 일견해 본 후, 채권배당절차에 있어서 배당재단의 중심이 되는 공탁금을 위주로 하여 그 유의해야 할 사항 등에 대해 살펴보기로 한다.

II. 채권배당절차와 부동산배당절차에 있어서 배당재단의 차이점

1. 배당재단의 구성면에서

부동산배당절차에서는 법원에 납부된 부동산의 매각대금이 배당재단의 중심이고 또 그것이 모두 배당재단으로 된다.

이에 반해 채권배당에 있어서는 공탁금이 배당재단의 중심을 이루고, 또한 예컨대 권리공탁(민집 제248조 제1항)과 같은 경우에는 채권의 일부를 압류한 경우에도 압류에 관계된 채권 전액을 공탁할 수 있으므로 그 공탁금 전액이 모두 배당의 범위로 된다고 단정하기는 어렵다.⁴⁶⁾

45) 이는 반드시 집행법원이 행하는 배당절차를 전제로 하는 것이라기 보다는 오히려 그보다 넓게 집행법원의 주관하에 행해지는 「배당절차를 포함한 변제절차」에서 그 변제(배당)절차의 대상 및 기초가 되는 금전이라고 보면 큰 무리가 없으리라고 생각된다

46) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결

2. 배당재단의 확정, 배당절차의 횟수 등

부동산배당절차에 있어서는 통상 1회의 대금납부에 의하여 배당재단을 확정하고 배당절차도 1회로 종료하게 된다.

그러나 채권배당절차의 경우 급여채권이나 임료채권 등 계속적인 급부를 목적으로 하는 채권을 압류한 때가 많이 있고, 이러한 경우에는 공탁도 1회로 종료하지 않고 계속하여 행해지게 된다. 이때에, 그 방법으로는 제3채무자가 매기마다의 채무를 계속하여 공탁한 데 대하여 집행법원이 이를 통합하여 배당절차를 진행하는 경우도 있고, 제3채무자가 일정 기간 동안의 채무를 몽땅그려 공탁하면 그에 따라 집행법원이 배당절차를 진행하는 경우도 있게 되는데, 어느 경우이든 그 채권을 압류한 채권자들이 모두 만족을 얻을 때까지 공탁을 계속된다. 따라서 위와 같은 계속적 수입채권을 압류한 경우에는 배당절차도 수회 행해지는 것으로 예정되어 있다.

3. 사유신고의 필요성 여하

부동산배당절차의 경우에는 집행법원 스스로가 대금납부절차를 진행하기 때문에 그 당연한 결과로 매수인이 매각대금을 납부하였는가 아닌가의 여부를 곧 인식하는 것이 가능하다. 따라서 집행법원은 대금납부 후 바로 배당절차를 진행할 수도 있는 것이다.

하지만 채권배당절차에 있어서는 예를 들어 제3채무자가 압류에 관계된 채무액을 공탁한 경우에도 집행법원측이 그 사실을 파악하여 배당절차를 진행한다는 시스템이 형성되어 있지 않으므로 어디까지나 제3채무자가 공탁서를 첨부한 사유신고서를 집행법원에 제출하여야만 위 금원의 공탁사실을 비로소 알게 되고 그에 따라 배당절차를 진행하는 것이 가능하게 된다. 따라서 만일 제3채무자가 공탁하였더라도 집행법원에 사유신고서를 제출하지 않는다면 집행법원으로는 배당재단도 인식할 수 없는 것이고 그에 따라 배당등 절차도 진행할 수 없게 되는 차이점이 있다.

Ⅲ. 배당재단의 종류

채권배당절차에서의 배당재단에 공탁금과 보관금이 있다는 것에 대해서는 이미 서술한 바이지만, 어떠한 경우에 배당재단이 공탁금 혹은 보관금으로 되는 것인가에 관하여 이하에서 그 대표적인 것들을 들어 일견해 보기로 한다.

1. 공탁금으로 되는 경우

채권배당절차에 있어서 공탁금이 배당재단으로 되는 경우는 대체로 다음과 같다.

가. 집행관에 의한 공탁⁴⁷⁾

집행관이 유체동산을 압류한 후 현금화한 매각대금(또는 유가증권지급금)에 대하여 그 대금으로 배당에 참가한 모든 채권자를 만족하게 할 수 없고 매각허가된 날부터 2주 이내에 채권자 사이에 배당협의를 이루어지지 아니하여 집행관은 매각대금을 공탁하고 집행절차에 관한 서류를 붙여 그 사유를 집행법원에 신고한 때(민집 제222조 제1항 내지 제3항)

나. 제3채무자에 의한 공탁 등의 경우

① 압류명령을 받은 제3채무자가 압류에 관계된 채권을 공탁하고 사유신고를 한 경우(민집 제248조 제1항 내지 제4항),⁴⁸⁾ ② 채무자의 공탁금출급(지급)청구권에 대한 압류명령을 받은 제3채무자인 공탁관인 사유신고서를 집행법원에 제출한 경우, ③ 추심채권자에 의한 공탁의 경우(민집 제236조 제2항) 등이 이에 해당한다.

2. 보관금으로 되는 경우

위와 달리, ① 집행관 등이 집행법원의 특별현금화명령(민집 제241조, 매각명령, 관리명령, 그 밖의 방법에 의한 현금화명령)에 의하여 현금화하고 그 대금을 법원에 제출한 경우(민집규 제165조 제4항), ② 유체동산청구권집행절차에서 유체동산을 인도받은 집행관이 그것을 유체동산의 현금화에 관한 규정에 따라 현금화하여(민집 제243조 제3항) 그 현금화한 대금을 법원에 제출한 경우(민집규 제169조), ③ 배서가 금지된 유가증권에 대한 채권집행절차(민집 제233조)의 진행 중 유가증권을 보관하는 집행관이 지급제시를 하여 증권채무자로부터 지급을 받은 때에는 그 수령한 금액을 집행법원에 제출한 경우 그 수령금 등은 모두 배당재단 중 법원보관금을 이루게 된다.

47) 유체동산에 관한 청구권의 압류(민집 제243조)의 경우에도 그 현금화는 결국 압류한 유체동산의 현금화에 관한 규정에 따르므로(민집 제243조 제2항), 이때 역시 집행관의 공탁에 의해 공탁금이 배당재단으로 되는 경우라고 할 수 있다.

48) 채납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 (가)압류가 경합하는 경우에 제3채무자가 이를 압류의 경합으로 공탁한 후 사유신고를 하였다면 위 금원이 공탁금을 이루게 됨을 물론이다.

IV. 공탁금과 보관금의 차이

1. 취급관서의 차이

배당재단 중 공탁금과 보관금의 차이는 우선 앞서 본 바와 같이, 공탁금은 공탁소(공탁관)에서 보관 및 관리되어지나, 보관금은 집행법원이 관리하게 된다는 등의 취급관서의 차이에서부터 시작된다.

2. 배당재단의 범위 확정의 필요성 여하

공탁금의 경우에는 사유신고서 및 공탁서가 집행법원에 제출되어도 반드시 그 공탁금 전액이 배당재단으로 된다고 단정할 수 없다는 데에서⁴⁹⁾ 보관금과 다른 차이를 보이고 있다.

즉 이미 기재한 바와 같이 채권 일부가 압류되어 있는데 제3채무자가 권리공탁(민집 제248조 제1항)에 의해 채권 전액을 공탁한 경우에 압류를 하지 않은 부분에 대하여는 변제공탁으로 되므로 집행법원의 배당등의 절차에 의하지 않고 피공탁자가 직접 공탁관에게 출급청구를 함으로써 지급받을 수 있고, 그것은 배당재단으로 되는 것이 아니다. 또 채권 일부에 대하여 채권양도가 되어 그 통지도 송달된 후 다른 채권자가 채권 전액을 압류하여 제3채무자가 채권 전액에 대해 혼합공탁을 한 경우 이미 본 바와 같이 채권양도에 관계되지 아니한 부분에 관하여는 채권양도의 유·무효에 불구하고 배당등 절차를 진행할 수 있으나, 채권양도에 관계된 부분은 그 채권양도의 무효가 확정되지 않는 한 배당등 절차를 진행할 수 없게 된다. 따라서 집행법원은 위와 같은 경우에 모두 공탁금 중에서 배당재단의 범위를 확정할 필요가 생기게 되는 것이다.

그 밖에 압류명령의 압류채권목록의 기재내용과 공탁서의 공탁원인사실란 기재의 내용이 일치하고 있는지 여부가 확실하지 않은 경우에는 집행법원으로서도 제3채무자에 대하여 조회서를 송부하는 방법 등에 의하여 배당재단을 확정할 필요가 있고, 그 결과 압류된 채권과 다른 채권을 공탁한 경우에는 그 금액은 배당재단으로부터 제외되게 된다.

49) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결

3. 출급절차 등의 차이

출급 또는 출납절차 등에 관하여, 보관금의 경우에는 채권자가 집행법원에 출급을 청구하면 법원사무관등은 소정 양식의 법원보관금 출급명령서를 출급청구자에게 교부하고, 출급청구자는 교부받은 출급명령서를 출납공무원에게 제출한다(법원보관금 취급규칙 제13조 제1항, 제2항). 위 출급명령서를 제출받은 출납공무원은 사건번호, 출급금액, 출급금의 종료 및 출급의 구분, 출급청구자 및 대리인, 출급명령일 등과 같은 법원보관금취급규칙 제13조 제3항 각 호 소정의 출급지시사항을 취급점에 전송하고 출급청구자에게 소정 양식의 출급지시서를 교부하여 이를 취급점에 제출하게 하여야 한다(위 규칙 제13조 제3항). 배당수령채권자는 보관금취급점에 위 출급지시서를 제출하고 보관금을 수령하는 방법으로 배당액을 지급받게 된다. 취급점이 배당수령채권자에게 법원보관금을 배당액으로 지급한 때에는 그 지급내역을 즉시 법원사무관등(사건담임자) 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(법원보관금취급규칙 제16조).

이에 대해, 공탁금의 경우에는 그 보관과 관리를 공탁관이 하고 있으므로 법원사무관등은 지급할 배당금액(배당액과 집행비용의 합계액)을 적은 지급위탁서를 공탁관에게 송부하고(공탁서를 붙일 필요 없음), 지급받을 사람에게는 지급받을 자격을 증명하는 배당액지급증(증명서)을 교부하여야 한다(민집 제256조, 제159조 제2항, 제3항, 민집규 제82조, 공탁규칙 제43조 제1항). 그 후 배당수령채권자는 공탁물출급청구서 3통(전산화가 된 곳은 2통)을 작성하고 거기에 법원사무관등으로부터 받은 증명서를 붙여 공탁관에게 제출하여 공탁금을 출급받으면 되는 것이다(공탁규칙 제43조 제2항, 제29조).

4. 이자의 배당가능 여부

보관금에 대해서는 집행법원이 직접 별단예금으로 예탁하여 보관, 관리하므로 그에 대하여 예탁한 날부터 이자가 발생하는데(법원보관금취급규칙 제7조 참조), 그 이자 중 배당기일까지의 이자에서 이자소득세를 원천징수한 잔액은 당연히 배당할 금액에 포함된다(법원보관금취급규칙 제7조 단서).

공탁금의 경우에도 이를 공탁관이 관리하기는 하나, 공탁관은 보관금과 마찬가지로 별단예금 형식으로 예탁하여 보관하므로 공탁일로부터 배당기일까지의 이자(공탁법 제6조, 공탁금의 이자에 관한 규칙 제2조에 따라 금융통화위원회가 정하는 별단예금의 최고이자율로서 현재는 연 1천분의 5)가 덧붙여지게 되어 있다.

다만 위 공탁금의 이자에 관하여는 공탁규칙 제52조가 “공탁금의 이자는 원금과 함께 지급한다. 그러나 공탁금과 이자의 수령자가 다를 때는 원금을 지급한 후에 이자를 지급할 수 있다.”라고만 규정하고 있어서 이를 배당재단에 포함시킬 것인가에 관하여 견해가 나눌 수 있는 여지가 있다. 하지만 금전채권에 대한 압류를 원인으로 하여 제3채무자가 공탁한 경우에는 공탁이자에 관한 부분도 공탁금과 함께 집행절차에 의한 구속에 있기 때문에 이 또한 집행법원에 의한 배당등의 대상으로 된다는 견해가 일반적이며, 우리의 실무도 현재 이를 배당재단에 포함시켜 취급하고 있는 것으로 보인다.

5. 수회 제출의 필요성 여부

공탁금의 경우에는 급료채권이나 임료채권 등과 같이 계속적 수입채권을 압류의 대상으로 하는 사례가 많은데, 이러한 경우 물론 매각대금과 동일하게 1회의 공탁만으로 배당재단이 확정되는 때도 있기는 하지만, 통상 제3채무자가 일정기의 공탁금을 통합하여 공탁하는 사안도 있고 혹은 집행법원이 일정 회수의 공탁분을 통합하여 배당재단으로 하는 사안도 있어 집행채무액이 수회 공탁되어서 그때마다 배당재단이 확정되는 것이 일반적이며, 또한 위와 같은 계속적 수입채권의 공탁에 있어서는 보통 각 지급기에 지급되는 금액이 적은 경우가 많고 오히려 그에 따른 절차비용부분이 증가하거나 또는 그때마다 행해지는 배당이의 등의 신청에 따라 배당절차가 복잡해질 수도 있다.

그러나 보관금의 경우에는 매각대금이 1회 제출되면 그 이후에 추가로 제출되는 경우는 거의 있지 아니하다.

제6절 배당을 받을 채권자

I. 서

집행법원이 배당등 절차를 실시할 경우 그 실시의 전제로서 당해 절차에 있어서 배당등을 받을 수 있는 채권자를 확정하는 작업을 하여야 한다. 배당을 받을 채권자가 결정되지 않으면 그 기일을 통지할 대상도 정하지 못하게 되고, 또 변제금 교부절차를 인정하는 전제하에서라면 배당을 받을 채권자가 확정되어야만 배당기일을 지정할지 아니면 변제금 교부일을 정할지 여부를 결정할 수 있기 때문이다.

위와 같은 배당등을 받을 채권자의 범위를 확정하기 위해서는 압류된 채권에 대하여 다른 채권자들이 어느 시기까지 그 절차에 참가하여 배당을 받을 수 있는지 여부를 결정해야 하는데, 이것을 위해 필요한 개념도구가 바로 배당가입차단효이다. 여기서 배당가입의 차단효란, 그 말 그대로 배당등에 가입하는 것이 차단되는 효력을 말한다. 즉 예를 들어 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 채권자 甲이 압류한 경우에 또다른 채권자가 과연 어느 때까지 그 채권에 대해 압류, 가압류 또는 배당요구를 하면 위 甲과 동일하게(채권자평등주의) 그 이후에 집행법원에 의해 행해지는 배당등 절차에서 배당등을 받을 채권자로 취급될 수 있을 것인가라는 문제인 것이며(제8장 집행공탁 제2절 Ⅷ. 3. 이하 참조), 이러한 배당가입차단효가 언제 발생하는가 하는 문제는 각 채권자마다 이를 나누어 고찰할 필요가 있다.

II. 압류 또는 가압류채권자

1. 압류채권자

압류 또는 가압류채권자의 경우, 그 배당가입의 차단효가 발생하는 시기에 관하여 현행법이 이를 규정하고 있지 아니하므로 이는 이론에 맞추어 해석에 의해 정립할 수밖에 없다.

가. 제3채무자에 의한 공탁의 경우(민집 제248조)

1) 공탁시에 배당가입차단효 발생

가) 제3채무자에 의한 공탁이 있는 경우 배당가입의 차단효는 피압류채권이 소

멸하는 때, 즉 제3채무자가 공탁한 때에 발생하므로 공탁 이후에 압류집행을 한 채권자는 배당에 가입할 수 없다(제8장 집행공탁 제2절 Ⅸ. 3. 이하에서 자세히 설명하였으므로 이를 참조). 즉 이때에 채무자의 제3채무자에 대한 채권은 실체상 소멸하고, 공탁금은 채무자의 일반재산으로부터 이탈하여 배당재단으로서 특정되는 것이다.

제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항의 규정에 의해 공탁을 한 때에는 집행법원에 대하여 사유신고가 제출되고, 위 사유신고서에는 공탁서가 첨부되므로 집행법원은 위 공탁서의 기재로부터 언제 배당가입차단효가 발생하였는지 알 수 있게 된다.

그리고 압류된 채권을 제3채무자가 공탁하였다고 할 때의 「압류」에는 강제집행에 의한 압류 이외에 담보권실행 및 행사에 의한 압류가 포함되지만, 체납처분에 의한 압류는 이에 해당되지 않는다.⁵⁰⁾

나) 금전채권의 일부가 압류된 경우에 제3채무자는 압류에 관계된 채권의 전액을 공탁하는 것이 가능할 뿐만 아니라 당해 압류된 금액만을 공탁할 수도 있는데, 이와 같은 일부 압류의 경우에 제3채무자가 압류에 관계된 채권금액을 공탁한 때에는 위 압류액을 초과한 부분은 순수한 변제공탁이므로 채무자(피공탁자)는 그 부분에 대하여 공탁을 수락함으로써 출급청구를 하는 것이 가능하며, 제3채무자(공탁자)로서는 공탁불수락을 원인으로 회수청구를 할 수 있다.

따라서 이 경우에는 압류액에 대하여는 공탁에 의해 배당가입이 차단되고, 나중에 집행법원의 지급위탁에 기초하여 그 지급이 행해지게 되지만, 압류액을 초과하는 부분에 대하여는 다른 채권자가 다시 위 출급청구권 또는 회수청구권에 대하여 압류 혹은 가압류의 집행을 하는 것이 가능하다.

다) 압류가 경합된 상태에서 제3채무자가 공탁을 하여 피압류채권이 소멸하게 되면 그 효력은 압류경합 관계에 있는 모든 압류채권자에게 미치고, 이때 위 채권자들의 압류명령은 목적을 달성하여 그 효력을 상실하며, 압류채권자의 지위는 집행공탁금에 대하여 배당을 받을 채권자의 지위로 전환된다. 따라서 이러한 압류채권자들은 제3채무자의 공탁사유신고시까지 민사집행법 제247조에 따른 배당요구를 하지 않더라도 배당절차에 참가할 수 있다. 이때 제3채무자가 집행공탁을 하여 사유신고를 하면서 경합된 압류 중 일부에 관한 기재를 누락하였다 하더라도 달리 볼 것은 아니고, 그 후 이루어진 배당절차에서 누락된 압류의 집행채권이 제외된 경우 다른 압류

50) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 404.

채권자 등을 상대로 배당이의의 소를 제기하여 배당표의 경정을 구할 수 있다.⁵¹⁾

2) 담보권자의 경우

가) 담보권의 물상대위에 기초한 압류의 경우 목적부동산에 복수의 담보권이 설정되어 있는 때에, 어떤 범위의 담보권이 어떠한 순위로 배당을 받을 수 있는가가 문제로 된다.

부동산배당의 경우에는 대금납부에 의해서 모든 담보권이 말소되버리기 때문에 모든 담보권자가 배당을 받아야 하는 채권자로 되지만, 채권배당의 경우에는 배당가입의 차단효과 발생할 때까지 압류 등을 하거나 배당요구의 종기(민집 제247조)까지 배당요구를 한 채권자만이 배당등을 받을 채권자로 되는 것이므로 담보권을 설정하였다고 하더라도 위 시기까지 압류 또는 배당요구를 하지 않으면 당해 절차에서 배당등을 받을 수 없다.⁵²⁾

또한 어느 한 채권자가 담보권 실행 내지 행사로서 압류를 한 데 대하여 다른 채권자가 그에 대해 배당가입을 하기 위해서는 위 시기까지 압류 또는 배당요구를 해야 함은 물론이다.

나) 나아가 압류 이후에 설정된 담보권의 담보권자가 담보권실행으로서의 압류를 함으로써 선행하는 압류와 경합하는 경우에 배당등의 절차에 있어서 이 담보권자를 어떻게 취급해야 할 것인가라는 문제가 있다.

51) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013다207774 판결

52) 日裁判 昭和 45(1970). 7. 16.(民集 24-7, 965) 참조; 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결; 그 외에 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다25728 판결; 대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688 판결; 대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다4272 판결; 대법원 2000. 6. 23. 선고 98다31899 판결; 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결 【판결요지】민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사집행법 제273조[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조]에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사집행법 제247조 제1항[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제580조 제1항]에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고, 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다.

점을 감안하면 강제집행에 기한 압류를 하고 있는 채권자는 위 압류에 기초한 배당절차에서는 어디까지나 일반채권으로서의 배당액밖에 받을 수 없는 것이고, 배당가입이 차단될 때까지 위 담보권에 기초하여 별개로 압류 또는 배당요구를 하지 않는 한, 우선채권으로서 배당받을 수 없다고 봄이 타당하다.⁵⁶⁾

나) 다음으로, 압류명령의 경우에는 현재 실무가 그 청구금액을 원본 및 압류명령 신청시까지 부대청구의 합계액에 한정하여 인정하고 있다는 것에 대하여는 이미 말한 바 있거니와(제8장 집행공탁 제2절 X. 참조), 이러한 경우에 배당등 절차에서 채권계산서에 의해 청구채권액을 배당기일까지의 부대청구를 포함한 금액으로 확장하는 것이 허용되는가라는 문제가 있다.

이에 대하여는 적극설과 소극설이 있지만, 이와 같이 채권 중 일부에 관해 집행을 신청한 경우에는 나머지 부대채권 등에 대해 새로운 압류절차나 배당요구를 해야만 배당받을 수 있다고 보는 소극설이 타당하다고 본다.^{57) 58)}

56) 日裁判 昭和 62(1987), 4, 2.(判時 1248, 61), 中野貞一郎, 民事執行法(下), 青林書院新社(1983), 580.

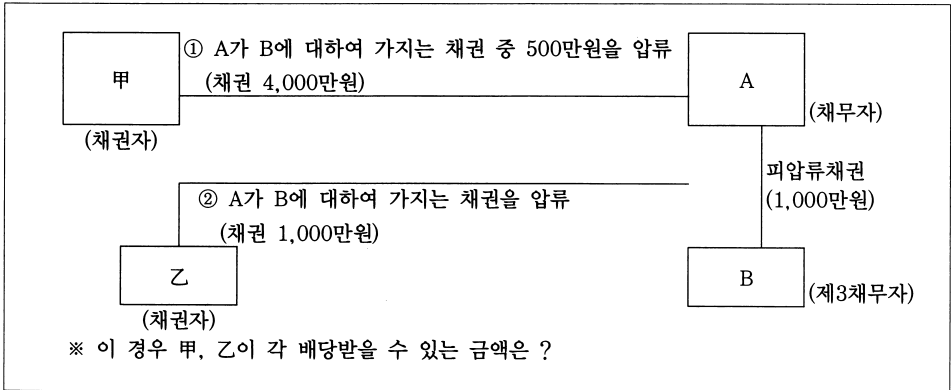
57) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 314.

58) 한편, 이와 같이 부대채권의 종기를 압류명령 신청일까지로 하는 실무와 관련하여, 채권자가 후일 배당절차 등에서 부대채권의 종기를 압류명령 신청일 후로 기재한 채권계산서를 제출한 경우 이를 인정할 수 있는지 여부에 대하여 논의가 진행 중인 바, 이를 소극적으로 보는 견해와 적극적으로 보는 견해가 대립하고 있다.

일본의 경우 日裁判 平成 21(2009), 7, 14.[平成 20年(受)第1134號]이, ① 특단의 사정이 없는 한 집행권원을 가지고 있는 채권자는 압류명령의 효력이 미치는 청구금액 및 배당액 산정의 기초가 되는 채권액에 관하여 배당기일까지의 지연손해금을 포함시키려는 의사를 가지고 있다고 해석할 수 있는 점, ② 위와 같은 채권자의 의사는 제3채무자의 부담에 대한 배려를 위하여 실현 관철되지 않는 경우가 있는데, 특히 압류명령신청단계에서 그러한 점(압류명령을 신청하는 채권자는 재판소의 청구지도 등에 따라 협조 양보하는 것으로서, 이는 제3채무자의 부담에 대한 배려 차원에서 배당재단이 감소되는 불이익을 입을 가능성을 인용 승인하는 것이라고 할 수 있음), ③ 그러나 제3채무자가 압류명령상의 청구금액을 공탁함으로써 이루어지는 공탁금에 대한 배당단계에서는 이미 제3채무자의 부담에 대하여 배려할 필요가 없는 점, ④ 압류채권자가 채권계산서에서 지연손해금을 압류명령신청일까지의 확정금액으로 하여 배당해 줄 것을 요구하는 의사를 명시적으로 표시하는 등의 특단의 사정이 없는 한 여전히 '집행권원의 금액에 기한 배당'을 요구하는 의사를 가지고 있는 것으로 보아야 하는 점 등을 근거로 적극설을 취하고 있다.

그러나 현재 우리 실무는 대체로, ① 채권압류명령신청의 경우 실무상 부대채권을 그 신청일까지의 확정금액으로 기재하도록 하고 있으며, 채권압류명령이 있는 경우 이론상 압류의 효력이 미치는 집행채권의 범위는 압류명령시의 청구채권액으로 한정되고, 실무상 압류 후에는 청구채권의 확장을 인정하지 않는 것이 정착되어 있기 때문에 채권자가 배당절차에서 채권계산서의 제출에 의하여 청구채권액의 확장을 신청한다 하더라도 배당절차에서 압류명령상의 청구채권액 이상의 배당을 받을 수 없는 점, ② 동순위의 채권자가 경합하는 경우 청구채권액의 확장을 인정하면 청구채권액을 확장하는 채권자에 대한 실제의 배당액이 증가할 가능성은 있으나, 다른 채권자도 청구채권액을 확장하는 경우에는 언제나 배당액이 증액되는 것은 아니어서 반드시 채권자에게 이익이 된다고 할 수는 없는 점, ③ 채권자 간의 불공평 발생 가능성이 있는 점(청구채권액의 확장을 인정하지

다) 마지막으로, 압류액에 의한 배당액 한정의 문제가 있다. 즉 이는 청구채권액을 한정하여 목적채권의 일부를 압류함으로써 압류경합이 생긴 경우 단순히 청구채권액에 따른 안분계산을 행하면 배당액이 압류액을 상회할 수가 있지만, 이 경우에 압류액을 배당액의 한도로 제한해야 하는가라는 점이다.



이 경우 단순히 청구채권액을 가지고 안분계산을 행하면 甲에 대한 배당은 800만 원, 乙에 대한 배당은 200만 원으로 되어 甲에 대한 배당액은 甲의 당초 압류액인 500만 원을 초과하는 것으로 되는데, 이 경우 甲에의 배당액을 당초 압류액인 500만 원 한도로 제한할 것인가가 문제되는 것이다.

이에 대하여는 다음과 같이 두 견해가 있다.

(1) 제한설⁵⁹⁾ : 이 설은, 이 경우 甲이 압류의 경합이 없는 때에 스스로 추심할 수 있는 액을 초과하여 배당을 받는 것은 불합리하고, 압류채권자(甲)로서도 압류액

않는 취급이 정착되어 있는 현 시점에서 일부 채권자에 대하여만 청구채권액의 확장을 인정하면, 실무의 취급을 따르는 다른 채권자의 배당액이 감소하게 되는 불공평이 발생하고, 민사집행법상 일부의 채권자로부터 배당기일까지의 지연손해금에 관하여 청구채권액을 확장한 채권계산서가 제출되는 경우 다른 채권자에 대하여도 채권계산서의 제출을 요구하는 등의 방법으로 위와 같은 불공평을 시정할 수 있는 절차가 마련되어 있지 않음), ④ 추심의 경우와 배당의 경우에 있어서 절차적 통일상 일관성 확보, ⑤ 확장신청에 대하여 채무자나 다른 채권자의 불복방법이 마련되어 있지 않는 점, ⑥ 집행절차의 신속성 및 형식주의의 요청, ⑦ 압류신청을 늦게 할수록 다른 채권자에 의한 추심완료 또는 배당가입차단 등의 가능성도 높아지므로 반드시 압류신청을 늦게 하는 채권자에게 유리하다고 볼 수 없는 점, ⑧ 배당요구의 종기까지 부채채권의 증가분에 대하여 압류배당요구를 할 수 있는 점, ⑨ 압류신청 후에 부채채권의 확장을 신청하는 것은 금반언 또는 신의칙에 반하는 점 등의 이유를 들어 이를 소극적으로 해석하고 있다.

이에 관하여 향후 명시적인 판례가 나오기 전까지는 일응 우리 실무의 입장에서 설명하기로 한다.

59) 조정래, “채권에 대한 강제집행에 있어서의 다수채권자의 경합”, 강제집행·임의경매에 관한 제문제(상), 재판자료 제35집, 법원행정처(87.07), 446-447.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 458.; 浦野雄幸, 逐條解説民事執行法, 商事法務研究會(1971), 714.

을 상회하는 부분에 관하여는 수령하지 않겠다는 의사를 표시한 것이라고 볼 수 있으므로 당초 압류액인 500만 원을 배당액의 상한으로 하고 甲에의 배당액을 위 금액에 한정해야 한다는 것이다.

(2) 비제한설⁶⁰⁾ : 이 설은, 이 경우 당초는 일부 압류였어도 압류경합의 결과 압류액은 목적채권의 전액으로 확장되었기 때문에 처음부터 전액을 압류한 경우와 다르지 않고, 또 압류채권자로서는 미리 목적채권의 금액등에 대하여 정확히 파악하고 있는 것은 아니며 초과압류가 되는 것을 회피하려는 등의 이유 때문에 부득이 청구채권의 일부를 압류액으로 하고 있는 것일 뿐, 이를 가지고 압류경합의 경우에 자신에 대한 배당액의 상한을 정하려는 의사가 있다고 보기는 어렵기 때문에 배당액은 원래 압류액인 500만 원에 한정하는 것이 아니라 안분계산에 따른 800만 원으로 된다는 것이다.

압류 효력의 확장을 인정하는 취지는 채권자 사이의 평등을 도모하려는데 있고, 압류채권자에 대하여 그가 구하는 것 이상의 이익을 줄 필요는 없다고 보이므로 위 견해 중 제한설이 타당하다고 본다.

나. 추심권 행사의 경우

압류채권자가 추심명령을 얻어 피압류채권을 추심한 경우에는 언제 배당가입이 차단된다고 볼 것인가.

1) 먼저, 제3채무자가 채권자의 추심에 응하여 그에게 임의로 변제한 경우에는 그 시점에 목적채권(피압류채권)이 소멸하게 되므로 그 때에 배당가입이 차단된다고 봄이 타당하다.⁶¹⁾

다만 민사집행법 제236조 제2항은 추심채권자가 같은 조 제1항에 따라 추심신청을 할 때까지 사이에 다른 채권자에 의해 압류·가압류 또는 배당요구가 있을 경우에는 추심채권자는 추심한 금액을 공탁하고 그 사유를 집행법원에 신고하도록 하고 있다(이때에는 민사집행법 제252조 제2호에 따라 집행법원에 의해 배당절차가 개시되게 된다). 그런데 위 채권자들 중 배당요구채권자를 제외한 압류·가압류채권자의 압류·가압류는 그 자체로서 배당가입이 차단된 후, 즉 이미 피압류채권이 소멸한 뒤에 압류·가압류를 한 것이어서 본래의 효력을 발휘할 수 없는 무효의 것인데도 위 제236조 제2항이 위와 같이 규정하는 취지는 위 압류·가압류에 대하여 배당요구로서의

60) 中野貞一郎(주56), 579.

61) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 796.

효력을 인정하여 배당에 가입시키려는 취지가 아닌가라는 문제가 제기될 수 있다. 이에 관한 상세한 설명은 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 다.를 참조하기 바란다.

2) 제3채무자가 채권자의 추심에 응하지 않아 채권자가 추심소송을 제기한 경우라면 어느 때에 배당가입이 차단된다고 볼 것인가.

현재 이에 관하여는 아무런 논의가 없으나, 우리 민사집행법상 추심채권자들이 추심신고를 하지 않는 것 때문에 집행이 파행되고 있는 현실을 개선하기 위하여 압류가 경합된 경우 추심소송에 있어서 추심채권자에 대하여 무조건적 급부판결이 아닌 공탁판결을 하여야 한다는 당위성 차원에서 이러한 논의는 필요하다고 본다.

이 경우 배당가입이 차단되는 시기로 생각해볼 수 있는 시점은, ㉠ 추심소송제기시, ㉡ 소장송달시, ㉢ 변론종결시, ㉣ 판결선고시, ㉤ 판결확정시 등이 될 것이다.

일본 민사집행법 제156조는 추심소송 제기라는 적극적인 행동을 행한 압류채권자에 대하여 추심소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 시점 이후에 동일 채권을 압류한 자를 배당으로부터 배제하는 방법에 의해 채권자의 위와 같은 추심노력에 보답하고, 나아가 소장의 송달이라는 형태로 위와 같은 압류채권자의 추심노력이 외형적으로 명확하게 될 뿐만 아니라 그 때에 피압류채권이 채무자의 일반재산으로부터 분리되는 외관을 나타낸다고 보아 추심소송의 소장이 피고인 제3채무자에게 송달된 때에 배당가입이 차단된다고 규정하고 있다.

이와 같이 정하는 것이 민사집행법 제249조 제3항이 규정하는 소송참가명령과 관련해서도 편의로운 점이 있다고 생각된다(제3채무자는 소장 송달시까지 절차에 참가한 압류채권자 등을 상대로 참가명령을 신청할 수 있을 것이므로). 이에 대한 자세한 논의는 추심명령에 관한 제4장 제4절 II. 참조.

다. 전부명령의 경우

압류채권자가 전부명령을 받아 그것이 확정되어 효력이 생긴 경우 변제의 효력은 전부명령에 관계된 금전채권이 존재하는 한 전부명령의 확정을 조건으로 전부명령이 그 권면액으로 제3채무자에게 송달된 때에 발생하므로 이때 이후로는 배당가입이 차단된다.⁶²⁾

그리하여, 확정된 전부명령에 대해 그것이 제3채무자에게 송달되기 전에 다른

62) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 796.

압류 또는 가압류집행이 있었다면 결국 위 전부명령은 압류의 경합으로 인해 무효로 되고 다른 채권자와 함께 배당절차에 들어가 청구액에 비례하여 안분배당을 받게 된다.

그리고 이러한 이치는 특별현금화명령 중 양도명령(민집 제241조 제1항 제1호)의 경우에도 동일하다.

라. 매각명령 또는 그 밖에 적당한 방법에 의한 현금화명령의 경우

(민집 제241조 제1항 제2호, 제4호)

1) 피압류채권에 관하여 매각명령에 의한 매각이 실시된 경우(민집 제241조 제1항 제2호)에는 언제 배당가입이 차단된다고 할 것인가.

생각전대 이 경우에는 집행관이 채권을 매각하여 매각대금의 교부를 받은 때에 압류의 목적물이 금전으로 전화(轉化)하고, 그 때에 채무자의 일반재산으로부터 완전히 분리하여 배당재단으로서 특정되기 때문에 위 시점, 즉 집행관이 매각대금의 교부를 받은 때를 배당가입차단시기로 볼 것이다.

또한 위 매각명령은 조건부채권, 기한부채권 또는 반대급부에 관계된 채권 등 추심이 곤란한 사정이 있는 금전채권 외에 유체동산인도청구에 대한 집행에 있어서 동산인도청구권 자체를 현금화하는 경우에도 발하여지고, 이와 같이 동산인도청구권에 대한 집행에 있어서 매각명령에 의한 현금화가 행해질 경우에는 위와 마찬가지로 집행관이 매각대금의 교부를 받은 때를 배당가입차단시기라고 보아야 한다.

2) 그리고 민사집행법 제241조 제1항 제4호는 현금화방법 중 하나로 위 매각명령 등 외에 「그 밖의 적당한 방법에 의한 현금화를 명하는 명령」을 규정하고 있는데, 이 적당한 방법에 의해 현금화를 명하는 명령은 일반 금전채권에 대한 집행에 있어서는 통상 그 예를 찾아보기 어렵지만, 이 명령에 의해 현금화가 행해진 경우에는 그 배당재단이 특정되는 시점이라는 의미에서 매각명령의 경우와 동일하게 위 명령에 의해 매각을 명받은 자가 매각대금의 교부를 받은 때에 배당가입이 차단된다고 할 것이다.

마. 관리명령(민집 제241조 제1항 제3호)의 경우

압류채권자가 관리명령(민집 제241조 제1항 제3호)을 받은 경우에는 민사집행법 제169조가 준용되므로 부동산에 대한 강제관리와 동일하게 집행법원이 정하는 기간(법원이 정한 수의처리기간, 민집규 제91조 제1항, 민집 제169조 제4항, 제148조 참

조)의 종기까지 그 기간에 해당하는 수익 등에 대해 압류 또는 가압류를 해야만 한다.⁶³⁾

따라서 집행법원이 주기적인 배당을 명한 경우에는 법원이 정한 기간 동안에 발생한 수익에 대하여 그 기간마다 배당을 실시하게 되므로 각 회의 배당에 관하여는 각 기간의 만료시까지 압류 또는 가압류를 하지 않으면 배당에 참가할 수 없고, 이미 지나간 배당부분에 대하여는 위 압류등의 효력이 미칠 수 없으며, 언제나 장차 실시하게 될 배당절차에서 배당받을 수 있음에 불과하다.

바. 유체동산인도청구권에 대한 압류(민집 제243조)의 경우

유체동산인도청구권에 대한 집행에 있어서 집행관에게 인도된 유체동산은 유체동산 압류의 경우와 마찬가지로 민사집행법 제199조의 규정에 따라 집행관의 매각에 의하여 현금화된다(민집 제243조 제3항).

1) 이 경우 인도청구권에 대한 강제집행과 인도를 받은 유체동산의 현금화절차의 관계에 관하여 견해의 대립이 있다.

그 중 제1설은 집행법원의 압류명령에 의한 유체동산인도청구권의 압류는 동산집행에 선행하는 절차이고 집행관이 하는 동산의 인도 및 현금화 이후의 절차는 원래 채권집행이 아닌 동산집행이라는 견해⁶⁴⁾이고, 제2설은 유체동산인도청구권에 대한 집행을 시종(始終) 채권집행으로 해석하고 집행관은 집행법원의 보조기관으로서 현금화에 종사함에 불과하다는 견해⁶⁵⁾이다.

생각건대 위 민사집행법 제243조의 규정 위치 및 태도를 감안할 때, 우리 집행법은 현금화의 방법에 관해서만 유체동산의 현금화방법에 적합한 방법을 채용하여 이를 채권집행의 절차에 포섭하는 데 그치고 결국 최후까지 채권집행의 절차를 관철한다는 절차구조를 취하였다고 보이므로⁶⁶⁾ 위 견해 중 제2설에 입각하고 있다 할 것이다.

2) 그리고 이와 같은 유체동산인도청구권에 대한 집행에 있어서 언제까지 다른 채권자들이 압류 등 집행을 하면 당해 배당등 절차에 참여할 수 있을 것인지가 문제된다.

63) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 864-865.

64) 兼子一, 増補強制執行法, 酒井書店(1979), 216.

65) 板倉松太郎, 強制執行法義海, 嚴松堂(昭和 5), 616.

66) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 442.

이에 관하여는 압류목적물이 채무자의 지배가능한 재산으로부터 이탈하는 시기고, 또 인도청구권이 실체적으로 소멸하며, 나아가 그 목적동산이 특정되는 때인 집행관이 위 유체동산의 인도를 받은 시점이 바로 배당가입이 차단되는 시기라 할 것이다.

또한 동산인도청구권에 대한 집행에서 압류가 경합한 경우에는 제3채무자는 경합하는 압류채권자 중 어느 채권자이든 신청이 있었던 채권자의 집행관에게 동산을 인도하면 되기 때문에 그와 같이 인도한 때에 배당가입이 차단된다고 보면 된다.

다만 유체동산인도청구권에 대한 집행이어도 집행관에게 동산을 인도하기 전에 압류채권자가 제3채무자에 대하여 당해 동산을 집행관에게 인도하라는 취지의 소송을 제기한 경우에는 앞서 보았듯이 위 소송의 소장이 제3채무자에게 소장이 송달된 때에 배당가입이 차단되고, 집행관에게 동산의 인도가 되지 않은 상태에서 매각명령에 의한 유체동산인도청구권 자체의 현금화를 행하는 경우에는 이미 본대로 집행관이 매각대금을 교부받은 때에 배당가입이 차단된다고 봄이 타당할 것이다.

2. 가압류채권자

가압류채권자의 경우에는 위 압류채권자에 대한 내용 중 추심권 행사의 경우를 제외하고(가압류채권자에게 추심권이 인정될 수 없으므로), 나머지는 모두 그에 준하여 생각하면 된다.

가. 가압류채권자의 존재는 본집행으로서의 압류와 가압류의 집행의 경합에 기초하여 제3채무자가 공탁한 경우 제출하는 사유신고에 의해 집행법원이 이를 알 수 있다.

1개의 가압류집행만을 원인으로 제3채무자가 공탁한 경우에는 제3채무자로부터 공탁신고서가 가압류집행의 집행법원에 제출되고, 위 공탁에 의해서는 아직 배당등 절차가 개시되지 않는다. 위 공탁금에 관한 채무자의 출급청구권에 대하여 다시 다른 채권자가 압류를 한 때에 공탁소(공탁관)로부터 압류명령을 발한 집행법원에 대하여 사유신고서가 제출되고, 위 사유신고에 의해 배당등을 실시하는 집행법원은 위 가압류채권자의 존재를 알게 되는 것이다.

따라서 추심이 곤란한 채권이나 유체동산인도청구권에 대한 집행과 같이 제3채무자에 의한 공탁이라는 것이 있을 수 없는 분야에 있어서는 집행법원이 위 가압류채권자의 존재를 알 기회가 절차상 보장되어 있지 않다.

나. 가압류채권자가 받을 배당금에 대하여는 법원사무관등이 그 액에 상당한 금전을 공탁(채권 불확정으로 인한 배당유보공탁, 민집 제256조, 제160조 제1항)하고 본집행으로 이행하는 요건이 정비된 때에 배당등이 실시되는데, 이때에 가압류에 의해 보전된 채권이 담보권 등 우선권을 가진다고 하여 가압류채권자가 배당단계에서 우선채권으로서의 배당을 구할 수 있는지 여부가 문제로 될 수 있다.

그러나 가압류는 어디까지나 강제집행을 보전하는 절차이고, 담보권 등 우선권의 실행 내지 행사를 보전하는 것이 아니므로 이 경우 우선권을 주장할 수 없다고 볼 것이다. 따라서 우선채권으로서의 배당을 받기 위해서는 배당가입이 차단되는 시기까지 다시 담보권 등 우선권에 기해 그 실행을 위한 압류를 별개로 해야 한다.⁶⁷⁾

3. 체납처분에 의한 압류채권자

체납압류는, 비록 그 자체만을 이유로 집행공탁을 할 수 있는 민사집행법 제248조 제1항의 '압류'에는 포함되지 않지만, 제3채무자에게 채무자에 대한 지급을 금지하고 채무자에게 채권의 처분과 영수를 금지하는 효력을 가지는 것으로서 민사집행절차에서 압류명령을 받은 채권자의 전속적인 만족을 배제하고 배당절차를 거쳐야만 하게 하는 민사집행법 제229조 제5항의 '다른 채권자의 압류'나 민사집행법 제236조 제2항의 '다른 압류'에는 해당한다.

일반 압류 및 추심명령과 체납압류가 경합한 후 제3채무자가 일반 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구에 응하거나 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁을 하게 되면, 피압류채권은 소멸하게 되고 이러한 효력은 민사집행절차에

67) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 809.; 대법원 2003. 3. 28. 선고 2002다13539 판결【판결요지】[1] 민법 제370조, 제342조에 의한 저당권자의 물상대위권의 행사는 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하거나, 구 민사소송법 제580조에 의하여 배당요구를 하는 방법에 의하여 하는 것이고, 이는 늦어도 구 민사소송법 제580조 제1항각호 소정의 배당요구의 종기까지 하여야 하는 것으로 그 이후에는 물상대위권자로서의 우선변제권을 행사할 수 없다고 하여야 할 것인바, 물상대위권자로서의 권리행사의 방법과 시한을 위와 같이 제한하는 취지는 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전하고 평등배당을 기대한 다른 일반 채권자의 신뢰를 보호하는 등 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니함과 동시에 집행절차의 안정과 신속을 꾀하고자 함에 있다. [2] 저당권자의 물상대위권 행사로서의 압류 및 전부는 그 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 효력이 생기며, 물상대위권의 행사를 제한하는 취지인 '특정성의 유지'나 '제3자의 보호'는 물상대위권자의 압류 및 전부명령이 효력을 발생함으로써 비로소 달성될 수 있는 것이므로 배당요구의 종기가 지난 후에 물상대위에 기한 채권압류 및 전부명령이 제3채무자에게 송달되었을 경우에는, 물상대위권자는 배당절차에서 우선변제를 받을 수 없다.

서 압류 및 추심명령을 받은 채권자에 대하여는 물론 체납압류권자에 대하여도 미치므로, 일반 압류 및 추심명령과 함께 체납압류도 목적을 달성하여 효력을 상실한다.

따라서 일반 압류 및 추심명령을 받은 채권자뿐만 아니라 체납압류권자의 지위도 민사집행법상의 배당절차에서 배당을 받을 채권자의 지위로 전환되므로, 체납압류권자가 공탁사유신고시나 추심신고시까지 민사집행법 제247조에 의한 배당요구를 따로 하지 않았다고 하더라도 배당절차에 참가할 수 있다.⁶⁸⁾

4. 집행채권이 양도된 경우

민사집행법 제248조에 따라 공탁이 이루어져 배당절차가 개시된 다음 집행채권이 양도되고 채무자에게 양도 통지를 했더라도, 양수인이 승계집행문을 부여받아 집행법원에 제출하지 않은 이상,⁶⁹⁾ 집행법원은 여전히 배당절차에서 양도인을 배당금채권자로 취급할 수밖에 없다. 이러한 상태에서는 양수인이 집행법원을 상대로 자신에게 배당금을 지급하여 달라고 청구할 수 없다. 양수인이 집행채권 양수 사실을 집행법원에 소명하였다고 하더라도 마찬가지이다.

집행채권의 양도와 채무자에 대한 양도 통지가 있었더라도, 승계집행문의 부여·제출 전에는 배당금채권은 여전히 양도인의 책임재산으로 남아 있게 된다. 따라서 승계집행문의 부여·제출 전에 양수인의 채권자가 위 배당금채권에 대한 압류 및 전부명령을 받았다고 하더라도, 이는 무효라고 보아야 한다.⁷⁰⁾

III. 배당요구채권자

민사집행법 제247조 제1항에 의하면 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자와 집행력 있는 정본을 가진 채권자는 다음 시기까지 배당요구의 방법으로 절차에 참가할 수 있는바, 위 시기가 배당요구채권자에 있어서 배당가입이 차단되는 시점이 된다.

민사집행법 제247조 제1항이 위와 같이 금전채권에 대한 강제집행에 있어서 배당요구를 할 수 있는 채권자의 범위를 ‘민법·상법 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청

68) 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결

69) 대법원 2008. 2. 1. 선고 2005다23889 판결; 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015다23284 판결

70) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

구권이 있는 채권자'와 '집행력 있는 정본을 가진 채권자'로 제한하여 규정하고 있으므로 그 어느 것에도 해당하지 않는 채권자는 위 조항 각 호의 사유 발생 전에 미리 가압류를 하여 이른바 경합압류채권자로서 배당에 참가하게 되는 것은 별론으로 하고, 별도의 배당요구를 할 자격이 없다.⁷¹⁾

1. 제3채무자에 의한 공탁(민집 제248조)의 경우

이 경우는 제3채무자가 공탁한 다음 민사집행법 제248조 제4항에 의해 사유신고를 할 때까지 배당요구를 할 수 있다(민집 제247조 제1항 제1호). 다만 이 규정이 배당요구의 부종성과 관련하여 문제가 있다는 점에 대하여는 제8장 집행공탁 제2절 Ⅸ. 3. 이하에서 자세히 언급한 바 있다.

2. 추심권 행사의 경우

압류채권자가 추심명령을 얻어 피압류채권을 추심하였는데, 제3채무자가 압류채권자의 추심에 응하여 임의로 변제한 경우라면 채권자가 민사집행법 제236조에 따라 추심의 신고를 할 때까지 배당요구를 할 수 있다(민집 제247조 제1항 제2호).

그러나 제3채무자가 추심에 응하지 않아 채권자가 추심소송을 제기한 경우에는 위 Ⅱ.항에서 본 것과 같은 이유로 그 소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 때를 배당요구의 종기로 봄이 타당할 것이지만, 이에 대하여는 위에서 본 대로(위 Ⅱ. 1. 나.) 입법적 조치가 필요하다고 본다.

3. 전부명령의 경우

압류채권자가 전부명령을 받아 그것이 확정되어 효력이 생긴 경우에는 앞서(위 Ⅱ. 다.) 본 것과 동일한 이유로 전부명령이 제3채무자에게 송달된 뒤에는 배당요구를 할 수 없다(민집 제247조 제2항).

양도명령의 경우에도 같다.

4. 매각명령 또는 그 밖에 적당한 방법에 의한 현금화명령의 경우

이 경우는 압류 또는 가압류채권자의 경우와 달리, 민사집행법 제247조 제1항 제3호에 따라 집행관 또는 매각명령을 명받은 자가 현금화한 금전(매각대금)을 법원에 제출한 때가 배당요구의 종기이다.

71) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2003다47638 판결

5. 관리명령의 경우

압류채권자가 관리명령(민집 제241조 제1항 제3호)을 받은 경우에는 다른 압류채권자의 경우와 동일하게 집행법원이 정하는 기간(법원이 정한 수익처리기간, 민집규 제91조 제1항, 민집 제169조 제4항, 제148조 참조)의 종기까지 그 기간에 해당 하는 수익등에 대해 배당요구를 해야만 한다.⁷²⁾

따라서 집행법원이 주기적인 배당을 명한 경우에는 법원이 정한 기간 동안에 발생한 수익에 대하여 그 기간마다 배당을 실시하게 되므로 각 회의 배당에 관하여는 각 기간의 만료시까지 배당요구를 하지 않으면 배당에 참가할 없고, 이미 지나간 배당부분에 대하여는 배당요구의 효력이 미칠 수 없으며, 언제나 장차 실시하게 될 배당절차에서 배당받을 수 있음에 그친다.

6. 유체동산인도청구권에 대한 압류(민집 제243조)의 경우

이 경우, 우리 집행법은 앞서 본대로 현금화의 방법에 관해서만 유체동산의 현금화방법에 적합한 방법을 채용하고 이를 채권집행의 절차에 포섭하는 데 그치고 결국 최후까지 채권집행의 절차를 관철한다는 절차구조를 취하고 있으므로 배당요구는 절차의 어느 단계에서도 집행관이 아닌 집행법원에 대하여 해야 하며, 배당요구의 종기는 민사집행법 제247조 제1항 제3호에 따라 동산을 인도받은 집행관이 그 동산을 현금화하여 그 매각대금을 법원에 제출한 때라고 볼 것이다.

IV. 교부청구권자

1. 세무서장은 납세자가 강제집행을 받을 때에는 집행법원에 대하여 국세, 가산금과 체납처분비의 교부를 청구하여야 하고(국세징수법 제56조), 지방세의 경우에도 교부청구를 할 수 있다(지방세기본법 제91조).

이와 같은 국세 등의 교부청구는 과세관청이 이미 진행 중인 강제환가절차에 가입하여 체납된 조세의 배당을 구하는 것으로서 강제집행에 있어서의 배당요구와 그 성질이 같은 것이다.⁷³⁾ 따라서 이러한 채권자는 배당요구채권자와 마찬가지로 민사집

72) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 864-865.

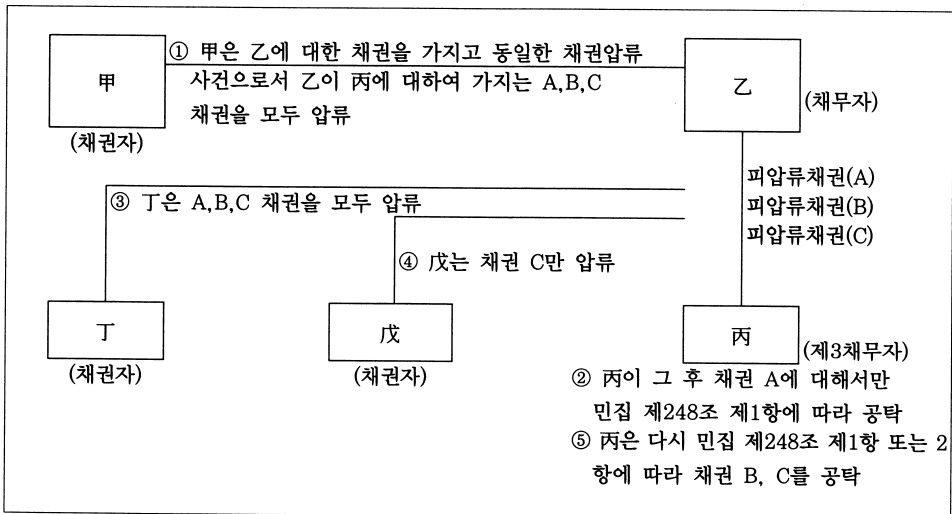
73) 대법원 2001. 11. 27. 선고 99다22311 판결【판결요지】[6] 국세징수법 제56조에 규정된 교부청구는 과세관청이 이미 진행중인 강제환가절차에 가입하여 체납된 국세의 배당을 구하는 것으로서 민사소송법에 규정된 부동산경매절차에서의 배당요구와 같은 성질의 것이므로 당해 국세는 교

행법 제247조 제1항이 규정하는 시기까지 교부청구를 해야만 배당등 절차에 가입할 수 있다.

2. 또한 세무서장은 압류하고자 하는 재산이 이미 다른 기관에서 압류하고 있는 재산인 때에는 위 교부청구에 갈음하여 참가압류통지서를 그 재산을 이미 압류한 기관에 송달함으로써 그 압류에 참가할 수 있고(국세징수법 제57조), 이러한 참가압류는 선행압류가 해제되지 않는 한 교부청구의 효력밖에 없으므로 위 교부청구와 마찬가지로 민사집행법 제247조 제1항이 규정하는 시기까지 참가압류가 된 경우에만 배당등 절차에 참여할 수 있을 것이다.

V. 피압류채권의 개수(個數)와 배당가입차단효

1. 위에서 말한 배당가입의 차단효는 개개의 피압류채권마다 생기는 것이고, 압류 내지 가압류 집행이 경합되었는지 여부에 대하여도 개개의 피압류채권마다 판단되는 것이므로⁷⁴⁾ 배당등을 받을 채권자의 범위도 개개의 피압류채권마다 판단되어야 한다. 이와 관련하여 아래의 사례를 한번 보기로 하자.



부청구 당시 채납되어 있음을 요하고 또한 과세관청이 경락기일까지 교부청구를 한 경우에 한하여 비로소 배당을 받을 수 있으며, 적법한 교부청구를 하지 아니한 세액은 그 국세채권이 실체법상 다른 채권에 우선하는 것인지의 여부와 관계없이 배당할 수 없다.

74) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 797.

위 사례의 경우 피압류채권 A에 대해서는 甲의 압류 후 권리공탁에 의해서 배당가입이 차단되었고, 위 채권 A에 대하여 공탁 후에 행해진 丁의 압류는 목적물을 흡결한 무효인 압류이기 때문에, 결국 채권 A에 대하여 배당등을 받을 채권자는 甲뿐이다. 채권 B에 대하여는 배당등에 관여하는 것은 공탁 전에 이를 압류한 甲·丁 두 사람이고, 채권 C에 대해서는 甲·丁·戊 세 사람이다(戊는 채권 C만을 압류하였으므로 채권 AB에 대하여 배당등을 받을 지위에 있지 않은 것은 당연하다).

2. 배당요구에 관하여도 채권자 甲이 동일하게 채권 ABC를 동일한 채권압류사건으로서 압류하고, 제3채무자가 채권 A만을 권리공탁하고 사유신고한 다음 채권자 丁이 甲의 채권압류사건에 대하여 배당요구를 하였으며, 그 후 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항 또는 제2항에 의해 채권 BC를 공탁한 사례를 생각해보면, 채권 A에 대하여는 공탁 후 사유신고 전에는 甲의 압류만이 되어 있고 丁의 배당요구는 되어있지 않기 때문에 배당등을 받아야 하는 채권자는 甲뿐이고, 채권 BC에 대해서는 丁의 배당요구 후에 공탁이 행해졌으므로 배당에 관여하는 것은 甲·丁 두 사람이 된다.

3. 급료 기타 계속적 급부에 관계된 채권에 대한 압류에 있어서는 이러한 채권 속에 각 기(期)에 있어서 공탁에 관계된 지급부분마다 배당등을 받을 채권자의 범위를 판단하게 된다.⁷⁵⁾

즉 제3채무자가 각 지급기가 도래할 때마다 각 기(期)에 있어서의 지급부분을 공탁한 사례의 경우에는 각 지급부분은 각각 공탁시(혹은 사유신고시)에 배당가입의 차단효과 발생하기 때문에 그 각각에 관하여 배당등을 받을 채권자의 범위를 확정짓게 된다.

VI. 개별상대효와 배당가입차단효

1. 배당을 받을 채권자의 범위를 판단함에 있어서는 압류에 의한 처분금지효력과 의 관계에서 주의할 점이 있다.

압류의 효력에 관하여 우리 실무와 판례는 개별상대효설을 취하고 있다(제3장 압류명령 제2절 V. 3. 이하 참조). 따라서 압류 후에 채무자가 채권을 양도 등의 방법으로 처분할 경우 목적물인 피압류채권은 다른 채권자에 대한 관계에서는 이제 집행채무자(양도인)의 것이 아닌 것으로 되기 때문에, 이후 다른 채권자는 압류 또는

75) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 第一法規(昭和 51), 383.[稻葉威雄 집필부분]

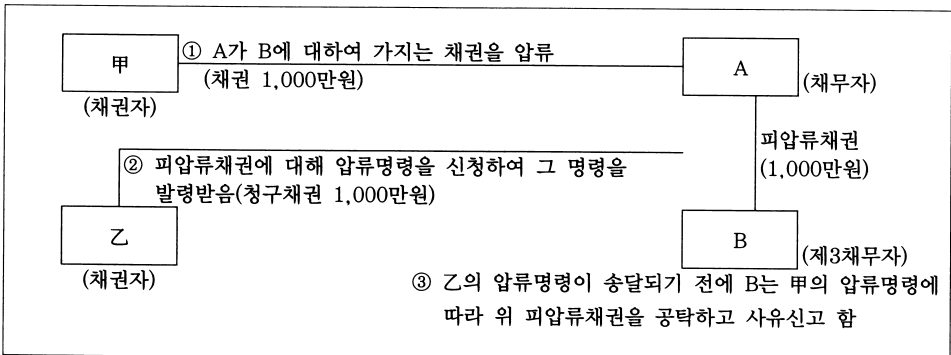
가압류는 말할 것도 없고 배당요구의 방법에 의해서도 집행에 참가하는 것이 불가능하게 된다.

예를 들어, 채권자 甲의 압류 후에 채무자가 피압류채권을 양도하고 그 후에 다시 채권자 乙이 동일한 채무자를 상대로 위 채권을 압류하고 채권자 丙은 甲의 압류에 대해 배당요구를 한 사례를 생각하면, 위 피압류채권에 관한 배당등 절차에 있어서 배당을 받을 채권자는 甲만이 해당될 뿐이다(만약, 1인의 채권자가 행한 압류는 평등주의의 견지에서 당해 집행절차에 참가하여 오는 모든 채권자를 위해서 효력이 생기는 것으로 보고 다른 채권자는 배당요구에 의해 당해 집행절차에 참가하는 것이 가능하다고 하는 절차상대효설에 의하면, 이 경우 배당을 받을 채권자는 甲과 丙이다).

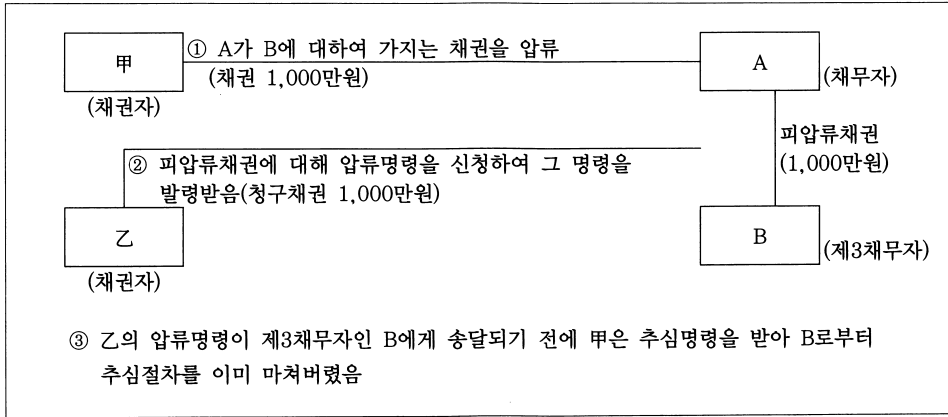
2. 이 경우, 채권양도 이후에 압류 또는 가압류집행을 한 채권자에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지 여부가 문제로 될 수 있는바, 압류의 처분금지효에 대하여 절차상대효설(이는 채권양도 이후에도 다른 채권자의 배당요구를 인정하는 견해임)을 취하고 있는 일본 민사집행법하에서는 이에 관하여 긍정설과 부정설의 대립이 있을 수 있으나, 압류의 위 효력에 대하여 개별상대효설(이는 채무자에 의한 채권양도 이후에는 다른 채권자는 배당요구도 할 수 없음)을 취하는 우리 집행법하에서는 이를 인정할 여지가 없다고 이미 설명한 바 있다[제9장 혼합공탁 제2절 Ⅱ. 1. 다. 2) 참조].

Ⅶ. 공탁 등 후의 (가)압류에 대한 배당요구효 인정 여부

[사례1]



[사례2]



1. 위 [사례1]과 같은 경우에 후행 압류명령의 신청(채권자 乙의 신청)에 관하여 선행절차에 대한 배당요구의 효력을 인정할 수 있을 것인가.

이에 대하여는 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 나.에서 적극설과 소극설의 입장이 대립하고 있음을 말한 바 있다. 우리 대법원은 이에 관하여 “다른 채권자의 신청에 의하여 발령된 압류·가압류명령이 제3채무자의 집행공탁 후에야 제3채무자에게 송달되었더라도, 공탁사유신고서에 이에 관한 내용까지 기재되는 등으로 집행법원이 배당요구의 종기인 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 있었고, 또한 그 채권자가 법률에 따라 우선변제청구권이 있거나 집행력 있는 정보를 가진 채권자인 경우라면 배당요구의 효력은 인정되나, 집행법원이 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 없었던 경우라면 설령 이러한 압류·가압류명령이 공탁사유신고 전에 제3채무자에게 송달되었다고 하더라도 배당요구의 효력도 인정될 수 없다.”라고 판시하여 이른바 ‘한정적 적극설’의 태도를 취하고 있다.⁷⁶⁾

따라서 압류채권자의 경우 제3채무자가 공탁한 이후 사유신고할 때까지 그 신청을 한 경우 그 압류는 실체법상 효력이 없을 뿐만 아니라 나아가 그에 대하여 배당요구로서의 효력도 인정하기 어려우나, 다만 그때까지 위 압류에 관한 내용이 공탁사유신고서에 기재되는 등의 방법으로 집행법원이 이를 알 수 있었던 경우에는 배당요구의 효력을 인정할 수 있다.

이에 반해 위 [사례2]의 경우에는 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 다.에서 본 대로

76) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다87502 판결

우리 판례⁷⁷⁾가 소극설을 취하고 있으므로, 채권자 甲의 추심 이후에 압류명령이 송달된 乙의 압류는 실체법상 효력이 없을 뿐만 아니라 배당요구로서의 효력도 인정되지 않는다.

2. 민사집행법 제247조 제1항 제3호가 “집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출한 때”로 배당요구의 종기를 정하고 있음과 관련하여, 매각명령 또는 그 밖에 적당한 방법에 의한 현금화명령의 경우에는 이미 본대로 압류명령에 대하여 배당가입이 차단되는 시기인 ‘집행관 혹은 매각을 명받은 자가 현금화한 금전(매각대금)을 교부받은 때’ 이후에 그리고 집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출하기 이전에 신청된 압류명령에 대하여 이를 배당요구로 보아 그에 해당하는 효력을 인정할 수 있을 것인지의 문제 및 유체동산인도청구권에 대한 압류의 경우 압류명령에 대한 배당가입이 차단되는 시점인 ‘집행관이 유체동산을 인도받은 때’ 이후에 그리고 집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출하기 전에 신청된 압류명령에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지의 문제가 발생할 수 있다.

또 관리명령의 경우에도 앞서 보았듯이 압류 또는 가압류채권자이든, 배당요구채권자이든 모두 집행법원이 정하는 기간(법원이 정한 수익처리기간, 민집규 제91조 제1항, 민집 제169조 제4항, 제148조 참조)의 종기까지 압류 또는 가압류집행을 하거나 또는 배당요구를 하여야만 하므로(위 시기 이후에는 배당요구조차 인정되지 않음), 그 이후에 압류명령을 신청하거나 또는 그 이전에 압류명령의 신청을 하였지만 제3채무자에 대한 송달이 그 이후인 경우 등에 있어서 유사한 문제가 발생한다.

이러한 문제들에 관하여도 적극설과 소극설의 견해가 나올 수 있으나, 이 에 대하여는 위 [사례1]에 준하여 집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출하기 전까지 또는 법원이 정한 수익처리기간의 종기까지 집행관 또는 집행법원이(실체법상 효력이 없는) 압류명령의 신청·발령사실을 알았거나 알 수 있었던 경우에는 그에 대하여 배당요구의 효력을 인정하여 취급할 수 있는 여지가 있다. 이에 관하여는 향후 판례의 발전을 기다려 보기로 한다.

VIII. 그 밖에 문제되는 경우

1. 배당가입차단시기가 복수 존재하는 경우

동일한 채권집행에 있어서 배당가입이 차단되는 시기가 수개 존재하는 경우, 예

77) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결

컨대 전부명령의 송달·확정 후에 제3채무자에 의한 공탁이 된 경우 등에는 그 중 최초의 시기가 배당가입차단효 발생시기가 된다.⁷⁸⁾

따라서 위의 예에서라면 확정된 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때가 위 시기가 될 것이다.

2. 공탁물지급청구권에 대하여 압류가 된 경우

공탁물지급청구권에 대한 압류로서는 공탁자가 가지는 회수청구권에 대하여 압류한 경우와 피공탁자가 가지는 출급청구권에 대하여 압류한 경우 등 두 가지가 있다.

가. 공탁물지급청구권에 대하여 1개의 압류가 된 경우

[사례] 채권자 甲은 채무자 乙에 대하여 1,000만 원의 채권을 가지고 있다. 채무자 乙은 변제기가 도래하자 위 채무액을 일정한 사유를 이유로 변제공탁하였다. 그런데 채권자 甲에 대하여 1,000만 원의 채권을 가지는 채권자 丙은 채권자 甲이 위 공탁물에 대하여 가지는 출급청구권을 압류하였다.
(또는 채무자 乙에 대하여 1,000만 원의 채권을 가지는 채권자 丙은 채무자 乙이 위 공탁물에 대하여 가지는 회수청구권을 압류하였다.)

1) 위 사례와 같이 채무자가 채무액을 변제공탁하게 되면 공탁자인 乙에게는 회수청구권(공탁법 제9조 제2항, 공탁규칙 제34조)이, 피공탁자인 甲에게는 출급청구권(공탁법 제9조 제1항, 공탁규칙 제33조)이 각 독립하여 공탁과 동시에 발생한다. 그리고 이들 양 권리를 합하여 강화상 공탁금지급청구권 또는 공탁물지급청구권이라고 한다.

공탁물지급청구권은 공탁자 또는 피공탁자에게 귀속하는 일종의 지명채권의 성질을 가지며 일신전속권이 아니므로 상속의 대상이 되고, 양도·질권설정 등의 임의처분은 물론 압류·가압류·가처분·전부·추심명령·채납처분 등 집행의 대상이 될 수 있으며, 채권자대위권의 목적이 된다.

공탁물출급청구권과 회수청구권은 하나의 동일한 공탁에 의하여 발생한 두 개의 권리인 점에서 그 중 어느 일방의 권리가 행사되면 타방의 권리도 소멸하게 되지만, 그 전까지는 양 권리는 서로 독립한 별개의 청구권이기 때문에 원칙적으로 어느 일방에 대한 양도, 압류 등은 타방에 대하여 아무런 영향을 미치지 않는다.

78) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 675.

2) 먼저 공탁물지급청구권에 대하여 위 사례와 같이 1개의 압류가 된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 제3채무자인 공탁관(공탁소)은 압류채권자 丙의 추심에 응하여 위 공탁액을 지급하면 된다(다만 회수청구권의 경우에는 민법 제489조의 요건에 따라 공탁자의 회수가 인정되는 경우에 가능할 것이다).

이 경우 공탁관은 민사집행법 제248조 제1항에 의해 공탁(관념적인 공탁)을 한 후 위 제248조 제4항에 의해 집행법원에 사유신고를 하는 것도 이론상 가능하기는 하다. 그러나 그렇게 하더라도 공탁소(공탁관)가 공탁금지급의무를 면하는 것은 아니다. 또 이 경우는 그렇게 함으로써 배당가입이 차단되는 시기를 도래하게 하여 압류채권자에게 독점적 만족을 얻게 할 필요나 실익이 없고, 공탁관이 집행법원의 지시를 기다려 지급해야 되는 경우도 아니다. 따라서 공탁관은 압류채권자의 추심에 응하여 공탁액을 지급하면 될 것이다.

나. 공탁물지급청구권에 대하여 압류의 경합이 있는 경우

[사례] 채권자 甲은 채무자 乙에 대하여 1,000만 원의 채권을 가지고 있다. 채무자 乙은 변제기가 도래하자 위 채무액을 일정한 사유를 이유로 변제공탁하였다. 그런데 채권자 甲에 대하여 각 1,000만 원의 채권을 가지는 채권자 A와 B는 채권자 甲이 위 공탁물에 대하여 가지는 출급청구권을 각 압류하였다.
(또는 채무자 乙에 대하여 각 1,000만 원의 채권을 가지는 채권자 A와 B는 채무자 乙이 위 공탁물에 대하여 가지는 회수청구권을 각 압류하였다.)

1) 위 사례와 같이 공탁물지급청구권에 대하여 압류의 경합이 있는 경우라면 제3채무자인 공탁관은 공탁의무를 부담하게 된다.⁷⁹⁾

다만 이때에 공탁관이 공탁한다고 말해도 이는 자기 자신에 대하여 공탁할 뿐이므로 관념적인 공탁에 불과하고 실제상은 그대로 공탁을 지속할 뿐이며, 공탁관은 민사집행법 제248조 제4항에 따라 사유신고를 해야 한다.

2) 그런데 이 경우 공탁관이 위와 같이 실제로 공탁절차를 행하는 것은 아니므로 어느 시점을 배당가입이 차단되는 「공탁을 한 때」라고 해석할 것인가가 문제로 된다.

이에 관해 “공탁관이 내부적으로 이를 민사집행법 제248조의 공탁으로서 취급하기로 결정한 때”를 그때에 해당한다고 해석할 수도 있지만, 이것은 객관적으로 명백하지 않으므로 오히려 공탁관은 국가기관이고 법률상 공탁의무가 생긴 경우에는 바로

79) 대법원 행정예규 제542호, “공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침” 참조

그것을 이행해야 할 의무를 부담하기 때문에, 위와 같은 공탁의무가 생긴 때를 위 「공탁을 한 때」라고 봄이 적절할 것이다.⁸⁰⁾

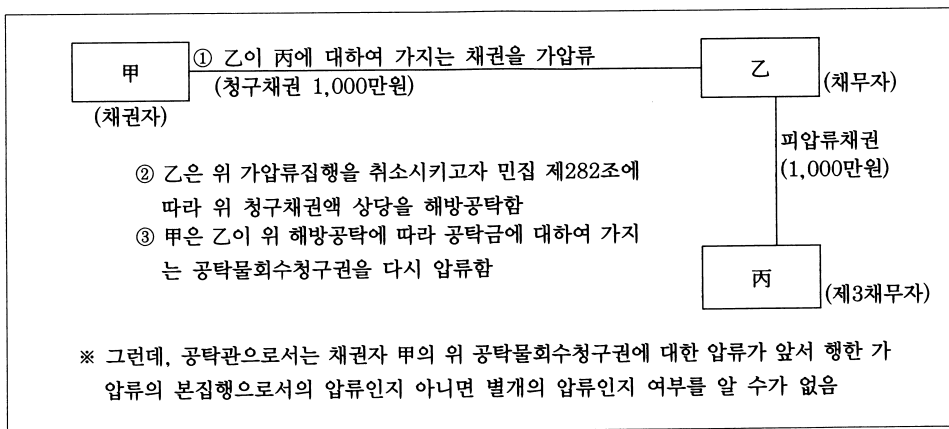
그리고 위 공탁의무가 언제 생기는가에 대하여는 ① 공탁금지급청구권에 대하여 경합하는 압류명령 또는 가압류명령의 송달을 받을 것(배당요구의 경우에는 그 취지를 기재한 문서의 송달을 받을 것) ② 공탁금지급청구에 응할 수 있는 상태에 있을 것 등의 2가지 요건이 구비된 때에 생기는 것으로 볼 것이다(이에 대한 자세한 내용은 제8장 집행공탁 제4절 Ⅱ. 2. 나. 참조).⁸¹⁾

3) 위와 같이 압류의 경합 등에 의해 제3채무자인 공탁관이 공탁의무를 부담하게 되면 민사집행법 제248조에 의해 바로(관념상으로) 공탁한 다음 집행법원에 사유신고를 하여야 하고 이렇게 공탁관으로부터 제출된 사유신고서에는 공탁의무의 발생 일시가 기재되기 때문에 집행법원은 위 기재로부터 배당가입이 차단된 시기를 알 수 있게 된다.

3. 가압류해방금의 공탁금회수청구권에 대하여 압류가 된 경우

가압류해방금의 공탁금회수청구권에 대하여 압류가 된 경우에는 그 압류가 당해 가압류의 본집행으로서의 압류인 것이 명확한 경우와 그렇지 못한 경우로 나누어서 볼 필요가 있다.

가. 후행 압류가 가압류의 본집행인지 여부가 불명인 경우



80) 日最判 昭和 62(1987). 4. 2.(判時 1248, 61) 참조

81) 深澤利一, 民事執行の實務(中), 新日本法規(1997), 393.

1) 가압류명령에는 가압류의 집행을 정지하거나 집행한 가압류를 취소시키기 위하여 채무자가 공탁할 금액을 적어야 한다(민집 제282조). 가압류명령에 정한 금액을 공탁한 때에는 법원은 결정으로 집행을 정지하거나 집행한 가압류를 취소하여야 한다(민집 제299조).

이와 같이 가압류의 집행정지나 집행한 가압류를 취소하기 위하여 채무자가 공탁할 금액을 해방금액 또는 해방공탁금이라 하는데, 가압류채무자가 가압류명령에 정한 금액을 공탁하는 것이 민사집행법 제282조의 가압류해방공탁이다.⁸²⁾

법원은 가압류명령을 발한 때에는 해방금액을 기재하여야 하고 그 전액을 공탁하였을 때에는 반드시 집행을 정지하거나 집행한 가압류를 취소하여야 한다.⁸³⁾

2) 해방공탁금은 가압류의 집행정지나 취소로 인한 채권자의 손해를 담보하는 것이 아니고 가압류의 목적재산에 갈음하는 것이므로 소송비용의 담보에 관한 규정이 준용되지 않고, 채권자는 여기에 대하여 우선변제권이 없다.

즉 가압류집행의 목적물에 갈음하여 가압류해방금이 공탁된 경우에 그 가압류의 효력은 공탁금 자체가 아니라 공탁자인 채무자의 공탁금회수청구권에 대하여 미치는 것이므로 채무자의 다른 채권자가 해방공탁금 회수청구권에 대하여 압류명령을 받은 경우에는 가압류채권자의 가압류와 다른 채권자의 압류는 그 집행대상이 같아 서로 경합하게 된다.⁸⁴⁾

82) 가압류제도는 금전적 청구권을 보전하기 위한 것이므로 채무자가 금전적 청구권 보전에 필요한 충분한 금액을 공탁한 경우에는 채권자로서는 가압류집행이 필요없게 되고 가압류의 효력을 공탁금회수청구권 위에 생기게 함으로써 채권자는 여전히 공탁금회수청구권 위에 가압류의 효력을 유지하는 결과가 되므로 아무런 불이익을 받지 아니한다.

한편 채무자는 가압류의 집행으로 인하여 가압류된 동산·부동산·채권 등의 처분이나 이용 등에 제한을 받게 된다. 통상 가압류집행 대상 목적물의 평가액은 가압류 청구금액보다 훨씬 상회하는 것이 보통인데, 가압류집행으로 인하여 재산권의 처분, 이용 등이 제한된다면 채무자의 일상생활이나 경제활동에 불이익과 고통을 받게 된다.

그러므로 채무자는 채권자의 가압류집행에 갈음하여 또는 이에 동일한 정도의 장래의 강제집행을 보전함에 족한 다른 방법을 선택할 수 있는 편의를 주어 채권자의 지위를 위태롭게 하지 않는 범위 내에서 금전을 공탁하고 가압류의 집행으로부터 해방을 얻게 된다면 채무자의 고통이나 불이익은 크게 줄어든 것이다.

이와 같이 가압류는 금전적 청구권을 보전하기 위한 수단이므로 집행목적재산 대신 상당한 금전을 공탁하면 구태여 가압류집행을 할 필요 없이 채권보전의 목적을 달할 수 있게 되므로 채무자로 하여금 불필요한 집행을 당하지 않도록 마련한 제도가 가압류해방공탁이다.

83) 대법원 1962. 5. 31.자 62마5 결정

84) 대법원 1966. 10. 17.자 66마614 결정; 대법원 1996. 11. 11.자 95마252 결정【결정요지】[1] 가압류집행의 목적물에 갈음하여 가압류해방금이 공탁된 경우에 그 가압류의 효력은 공탁금 자체가 아니라 공탁자인 채무자의 공탁금 회수청구권에 대하여 미치는 것이므로 채무자의 다른 채권자가 가압류해방공탁금 회수청구권에 대하여 압류명령을 받은 경우에는 가압류채권자의 가압류와 다른 채권자의 압류는 그 집행대상이 같아 서로 경합하게 된다. [2] 압류된 금전채권에 대하여

결국 가압류해방공탁금은 가압류목적물에 갈음하는 것으로서, 가압류해방공탁이 된 경우에 가압류명령 그 자체의 효력은 소멸되는 것이 아니라 가압류채무자의 공탁금회수청구권에 미치게 되는 것이다.

가압류해방금액을 공탁하게 하는 목적은 가압류의 집행과 마찬가지로 피보전채권의 강제집행을 보전하는 데 있으므로 가압류해방공탁은 채무변제를 위한 공탁이 아니며, 따라서 가압류채무자는 가압류해방공탁에 의하여 채무의 소멸을 주장할 수 없다.

3) 위 사례의 경우와 같이 가압류해방금의 공탁금회수청구권에 대하여 압류가 되더라도 그것이 가압류의 본집행으로서의 압류인 것이 명확하지 않으면 공탁관은 바로 집행법원에 대하여 사유신고를 해야 한다.⁸⁵⁾

그 이유는, 가압류해방금에 대해서는 위 해방금의 공탁에 의해 가압류의 효력은 공탁금회수청구권 위에 이행함으로써 공탁금이 위 가압류의 목적물로 되는 것이므로⁸⁶⁾ 가압류해방금은 재판상의 담보공탁과 달리 공탁과 동시에 회수청구권이 생기고 있으나 다만 그 지급청구권 위에 가압류집행의 효력이 미치고 있는 것 때문에 지급제한을 받고 있는 상태라고 해석되고 있다. 따라서 이 회수청구권에 대하여 공탁소(공탁관)를 제3채무자로 하여 다시 압류가 된 경우에는 위 가압류집행과의 사이에서 압류의 경합이 발생하게 되고, 그에 따라 공탁관은 공탁의무를 부담하게 되므로(민집제291조, 제248조, 대법원 행정예규 제542호 참조), 공탁관은 그대로 공탁을 지속하

배당요구가 있어 채권자가 경합하게 된 경우에 제3채무자가 그 권리로서 채무액을 공탁할 수 있음을 규정한 민사소송법 제581조 제1항은 제3채무자가 각 채권자의 변제수령권의 유무나 채무액의 배분 등에 있어서 판단을 잘못함으로써 이중변제의 책임을 지게 되는 위험을 제거하고 집행절차의 적정을 도모하는 데 그 취지가 있으며, 그와 같은 제3채무자 보호 및 집행절차의 적정이라는 이념은 중복압류(가압류를 포함한다)에 의하여 채권자가 경합된 경우에도 역시 요청되는 것이므로 제3채무자가 그 권리로서 채무액을 공탁할 수 있음을 규정한 민사소송법 제581조 제1항은 중복압류의 경우에도 유추 적용된다. [3] 채무자의 가압류해방공탁금 회수청구권이 가압류채권자의 본안소송에서의 패소확정 등을 정지조건으로 하는 조건부 채권이라고 하더라도 가압류해방공탁금은 가압류목적물에 갈음하는 것으로서 이를 공탁하게 하는 목적이 가압류의 집행과 마찬가지로 피보전채권의 강제집행을 보전하는 데 있고, 가압류채권자가 가압류목적물에 대하여 우선변제를 받을 권리가 없는 것과 마찬가지로 가압류해방공탁금에 대하여도 우선변제권이 없으므로 집행력 있는 채무명의를 가진 다른 채권자가 가압류해방공탁금 회수청구권에 대하여 강제집행절차를 밟는다고 하여 가압류채권자에게 별다른 손해를 주는 것도 아니며, 만일 가압류채권자가 다른 채권자의 채권이 허위채권이라거나 청구채권액이 부당히 과다하다고 판단한다면 이를 이유로 배당이의의를 하여 다른 채권자에 대한 배당을 보류시키면 되는 것이므로 가압류채권자의 배당이의가 있다고 하여 배당절차의 개시 자체가 위법하게 되는 것은 아니다.

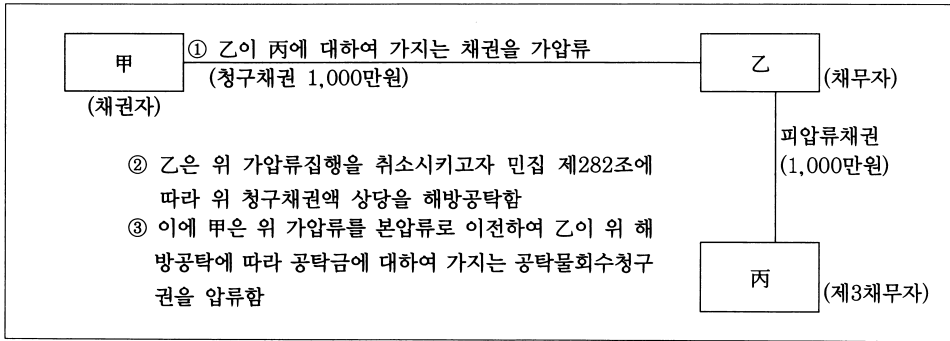
85) 深澤利—(주81), 394.

86) 浦野雄幸(주59), 714.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 458.

면서(관념상의 공탁) 바로 집행법원에 대하여 사유신고를 해야 하는 것이다.

이 경우 배당가입차단효는 공탁관에게 공탁의무가 생긴 시점, 즉 후행 압류명령이 제3채무자인 공탁소에 송달되어 공탁관이 사유신고를 한 시점에 발생한다고 볼 것이다.⁸⁷⁾

나. 후행 압류가 가압류의 본집행인 경우



위 사례와 같이 후행 압류가 당해 가압류해방금의 대상인 가압류의 본집행으로서 된 압류인 것이 명확한 때는 압류의 경합이 생기지 않는다.

따라서 이 경우는 공탁관에게 공탁의무가 발생하지 않기 때문에 집행법원에 대해 사유신고를 하지 않고, 압류채권자가 추심명령을 얻어 추심권의 행사로서 혹은 전부명령을 받은 다음 회수청구를 한 경우에는 그에 응하여 지급을 하면 된다.⁸⁸⁾

그리고 이 경우에는 배당가입이 차단되는 시기가 아직 아직 도래하지 않았기 때문에 다른 채권자는 위 공탁금의 지급 전에 다시 위 회수청구권에 대하여 압류 또는 가압류를 함으로써 배당등에 참여하는 것이 가능하다(배당요구채권자의 경우에는 가압류에 대한 본집행으로서의 위 압류에 배당요구를 함으로써 참여가 가능).

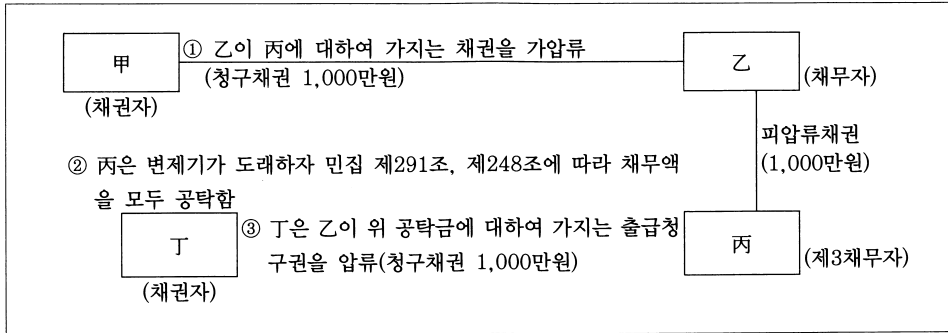
그리하여 다른 채권자에 의한 압류, 가압류(혹은 배당요구)가 다시 행해진 때에는 공탁관에게 공탁의무가 생기므로 집행법원에 대하여 사유신고를 하고, 위 압류명령, 가압류명령의 취지를 기재한 문서가 공탁소에 송달될 때(배당요구의 경우에는 그 취지를 기재한 문서가 위 사유신고 전에 접수된 때)에 비로소 배당가입이 차단된다고 볼 것이다.

87) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 825.은 압류명령 송달시점으로 보고 있다.

88) 中野貞一郎(주56), 579.

4. 가압류집행에 기초하여 제3채무자가 공탁한 공탁금의 출급청구권에 대하여 압류가 된 경우

가. 후행 압류가 공탁원인이 된 가압류의 본집행이 아닌 다른 압류인 경우



1) 금전채권에 대하여 가압류의 집행이 행해져 제3채무자가 민사집행법 제291조에 의해 준용되는 민사집행법 제248조에 따라 채무액을 공탁한 경우에는 위 공탁은 변제공탁의 성질을 가지고, 채무자는 공탁금에 대해 출급청구권을 가지게 되지만, 가압류해방금액(통상은 피보전채권액과 일치한다)의 한도에서 가압류집행의 효력이 위 출급청구권 위에 이행하는 것으로 되기 때문에 지급의 제한을 받는 상태가 된다고 해석되고 있다.⁸⁹⁾

즉 금전채권에 대한 가압류를 원인으로 제3채무자가 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 공탁을 하면 공탁에 따른 채무변제 효과로 당초의 피압류채권인 채무자의 제3채무자에 대한 금전채권은 소멸하고, 대신 채무자는 공탁금출급청구권을 취득하며, 가압류의 효력은 그 청구채권액에 해당하는 공탁금액에 대한 채무자의 공탁금출급청구권에 대하여 존속한다(민집 제297조).⁹⁰⁾

2) 그런데 위 사례와 같이 공탁금출급청구권에 대하여 공탁소(공탁관)를 제3채무자로 하여 다시 별개의 압류가 된 경우에는 채권자 甲의 가압류집행과 채권자 丁의 압류 사이에는 압류의 경합이 생기고, 그에 따라 공탁관은 공탁의무에 기해 사유신고를 하여야 한다.

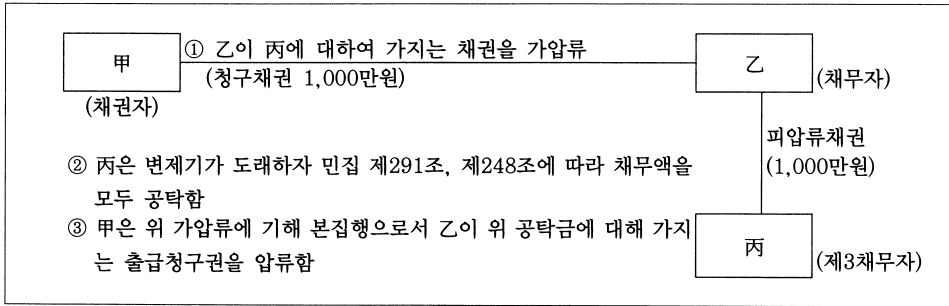
그리고 이 경우 공탁소에 대하여 채권자 丁의 압류명령이 송달되어 공탁관이 사

89) 田中康久(주7), 396.

90) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

유신고를 한 때에 배당가입이 차단되는 것은 위에서 본 가압류해방금의 회수청구권이 압류된 경우와 동일하다.

나. 후행 압류가 공탁원인으로 된 가압류의 본집행으로서의 압류인 경우



1) 그런데 위 사례와 같이 후행 압류가 공탁원인으로 된 가압류의 본집행으로서의 압류인 때에는 이를 어떻게 취급할 것인가에 관해서 다음과 같이 견해가 나뉘어지고 있다.

가) 제1설⁹¹⁾ : 이 설은, 이 경우를 가압류해방금의 회수청구권의 경우와 동일하게 보아 위 본집행으로서의 압류에 의해서는 아직 배당가입차단시기가 도래하지 않으므로 공탁관은 압류채권자의 추심권행사가 있으면 이에 응하여 지급하고, 또 다른 채권자는 위 지급 전에 위 출급청구권에 대하여 다시 압류 또는 가압류를 하거나 혹은 본집행으로서의 압류에 대해 배당요구를 함으로써 배당등에 관여할 수 있다고 본다.

나) 제2설⁹²⁾ : 이 견해는, 이와 같이 공탁의 원인이 된 가압류의 본집행으로서의 압류가 된 때에는 민사집행법 제291조에 의해 준용되는 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁이 본집행으로서의 압류에 의해 순수한 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁으로 전화(轉化)되므로 위 본집행으로서의 압류명령이 공탁소(공탁관)에 송달된 시점에 배당가입이 차단되며(따라서 그 이후에는 더 이상 다른 채권자에 의한 배당가입이 인정되지 않는다), 또 이 경우는 처음부터 민사집행법 제248조 제1항에 의해 공탁이 되었던 것과 동일하기 때문에 나중에 집행법원이 배당등 절차를 실시한 후 지급위탁에 의해 비로소 본집행을 한 가압류채권자에게 그 채권액이 지급된다고 보고 있다.

91) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 828.

92) 田中康久(주7), 397.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 455.

2) 위 두 견해에 관해 생각해 보건대, 가압류채권자가 본집행으로서의 압류를 하게 되면 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 “당초부터” 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있는 것이고, 그에 따라 이와 같이 이미 가압류에 기해 공탁된 가압류채권이 본집행으로 이행되면 당초부터 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁한 것과 동일시하는 것이 가능하다 할 것이므로 위 견해 중 제2설이 타당하다고 본다.⁹³⁾

다만 제2설을 취하더라도 본집행으로서의 압류명령을 송달받은 공탁관이 새로이 집행법원에 대해 사유신고를 할 필요가 있는가에 대하여는 다시 부정설과 긍정설이 나타나고 있으나, 사유신고가 없을 경우 집행법원이 배당등 절차의 개시 여하를 인식하기 어려우므로 공탁관은 이에 기초한 사유신고서를 압류명령의 집행법원에 제출해야 한다는 긍정설⁹⁴⁾이 타당하다 할 것이다.⁹⁵⁾

우리 판례⁹⁶⁾도 이에 관하여, “금전채권에 대한 가압류를 원인으로 제3채무자가 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 공탁을 하면 공탁에 따른 채무변제 효과로 당초의 피압류채권인 채무자의 제3채무자에 대한 금전채권은 소멸하고, 대신 채무자는 공탁금출급청구권을 취득하며, 가압류의 효력은 그 청구채권액에 해당하는 공탁금액에 대한 채무자의 공탁금출급청구권에 대하여 존속한다(민사집행법 제297조). 이후 공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 국가(공탁관)에게 송달되면 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따른 공탁은 민사집행법 제248조에 따른 집행공탁으로 바뀌어 공탁관은 즉시 압류명령의 발령법원에 그 사유를 신고하여야 하는데, 이로써 가압류의 효력이 미치는 부분에 대한 채무자의 공탁금출급청구권은 소멸하고, 그 부분 공탁금은 배당재단이 되어 집행법원의 배당절차에 따른 지급위탁에 의하야만 출급이 이루어질 수 있게 된다.”라고 판시하여 동일하게 보고 있다.

이 경우 금전채권에 대한 가압류를 원인으로 한 제3채무자의 공탁에 의해 채무자가 취득한 공탁금출급청구권에 대하여 압류·추심명령을 받은 채권자는, 그러한 공

93) 대법원 행정예규 제1018호, “제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차” 중 6.항 공탁관이 제3채무자인 경우 참조

94) 古島正彦, “債權執行における第三債務者の供託と配當(3) 第18問”, 書協會報 87号, 75.

95) 우리 실무도 이와 같다[대법원 행정예규 제1018호, “제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차” 중 6.항 공탁관이 제3채무자인 경우 및 대법원 행정예규 제950호, “공탁관의 사유신고에 관한 업무처리지침” 중 1.항 사유신고의 요건]

96) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다118785 판결; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

탁이 위에서 본 법리에 따라 민사집행법 제248조에 따른 집행공탁으로 바뀌는 경우에는 더 이상 추심권능이 아닌 구체적으로 배당액을 수령할 권리, 즉 배당금채권을 가지게 된다.⁹⁷⁾

5. 집행정지 후 제3채무자의 공탁의 경우

금전채권에 대한 집행에 있어서 집행정지서면이 집행법원에 제출된 후에 제3채무자가 공탁을 한 경우 그 공탁에 의해 배당가입차단효가 생긴다고 볼 것인가에 대하여는 견해가 나뉘어지고 있다.

이에 대하여는, 제3장 압류명령 제2절 Ⅳ. 3. 나. 2) 라) (1)에서 보았듯이 「배당가입차단효 불발생설」과 「배당가입차단효 발생설」 등 두 가지 견해가 나오고 있다.

그러나 집행정지의 효력은 배당가입을 저지하는 것은 아니고(집행정지 중에도 배당요구를 하는 것이 가능하고, 압류의 경합도 발생한다), 또 추심명령을 얻은 채권자의 추심권능을 박탈하는 것이 아니라 일시정지해 두고 있음에 불과하므로 이 경우에도 배당가입의 차단효가 발생한다고 봄이 타당하다.

따라서 집행법원으로서도 달리 배당등을 받을 채권자가 있는 때에는 바로 배당등 절차를 실시해야 할 것이나(민집 제256조, 제160조 제1항 제3호), 다만 집행정지서면이 제출된 채권자에 대한 배당등의 액은 그대로 공탁이 계속된다(민집 제256조, 제160조 제1항 제3호. 이 경우 당해 채권자에 대한 배당등의 액에 대하여는 권리공탁이 민사집행법 제160조에 의한 배당유보공탁으로 전환된다).

6. 제3채무자의 공탁 후 압류명령이 취하, 취소된 경우

제3채무자의 공탁 후에 압류명령이 취하 혹은 취소된 경우의 배당가입차단시기에 대하여는 논의의 여지가 있다.

1. 우선, 공탁 후에 압류명령이 취소된 경우에 관해서는, 채권집행에 있어서 제3채무자의 공탁은 부동산집행에서의 “대금납부”에 상당하는 것으로서 공탁 후 취소가 있더라도 공탁에 의한 배당가입의 차단효과는 복멸(覆滅)되지 않고, 취소된 압류에 대해 다른 가압류채권자나 배당요구채권자가 있는 때에는 그 자들을 위해서 배당등을 실시해야 한다(제8장 집행공탁 제2절 Ⅸ. 3. 및 제9장 혼합공탁 제2절 Ⅱ. 1. 가. 1) 나) 참조).

97) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

2. 다음으로, 취하의 경우에 있어서도 제3채무자의 공탁 후의 취하는 그 소급효가 인정되지 않고 다만 배당수령권의 포기로 취급되므로⁹⁸⁾ 그에 따라 공탁 후에 취하가 있더라도 공탁에 의해 생긴 배당가입차단효는 복멸(覆滅)되지 않으며, 취소에 있어서와 마찬가지로 나머지 가압류채권자나 배당요구채권자를 위해 배당등을 실시하게 된다.

3. 또한 압류명령의 취소, 취하 후 그 취지가 제3채무자에게 통지되기 전에 제3채무자가 공탁한 경우 위 공탁은 변제공탁으로서는 유효하지만, 공탁에 의한 배당가입차단효는 발생하지 않는다.⁹⁹⁾

다만 경합하는 압류 또는 가압류의 집행이 있음을 이유로 민사집행법 제248조 제1항 또는 제2항에 의한 공탁이 된 경우에는 다른 1개의 압류 또는 가압류의 집행을 원인으로 한 공탁으로서 유효하게 취급할 것이다(전자의 경우에는 공탁에 의해 배당가입차단효가 발생한다).

7. 수익자의 배당금지급청구권에 대하여 지급정지가처분을 해둔 채권자의 경우

수익자에 대한 사해행위취소(소유권이전등기말소)소송에서 승소하고 그 목적물인 부동산의 경매절차에서 발생한 수익자의 배당잔금지급청구권에 대하여 지급정지가처분(위 사해행위취소소송을 본안으로 한 가처분)을 하여 두었을 뿐인 채권자가 배당요구채권자에 해당하는지 여부가 문제될 수 있다.

그러나 이에 대하여는 대법원 2003. 12. 11. 선고 2003다47638 판결이 명시적으로 위와 같은 채권자는 위 배당잔금지급청구권에 대한 압류경합에 따라 개시된 배당절차에서 배당요구를 할 수 있는 채권자에 해당하지 않는다고 판시하여 이를 부정하고 있다.¹⁰⁰⁾

98) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355-356.

99) 다만 취소에 있어서 그 고지등이 있어야 효력이 발생하는 경우에는 달리 볼 여지가 있다.

100) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2003다47638 판결【판결요지】[1] 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제580조 제1항은 금전채권에 대한 강제집행에 있어서 배당요구를 할 수 있는 채권자의 범위를 '민법·상법 기타 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자'와 '집행력 있는 정본을 가진 채권자'로 제한하여 규정하고 있으므로 그 어느 것에도 해당하지 않는 채권자는, 위 조항 각 호의 사유 발생 전에 미리 가압류를 하여 이른바 경합압류채권자로서 배당에 참가하게 되는 것은 별론으로 하고, 별도의 배당요구를 할 자격이 없다. [2] 수익자에 대한 사해행위취소(소유권이전등기말소)소송에서 승소하고 그 목적물인 부동산의 경매절차에서 발생한 수익자의 배당잔금지급청구권에 대하여 지급정지가처분(위 사해행위취소소송을 본안으로 한 가처분)을 하여 두었을 뿐인 채권자는 위 배당잔금지급청구권에 대한 압류경합에 따라 개시된 배당절차에서 배당요구를 할 수 있는 채권자에 해당하지 않는다고 한 사례.

제7절 배당순위

I. 서

배당기일에서 모든 채권자가 출석한 다음 모든 채권자 사이에서 집행법원이 작성하는 배당표원안과 다른 협의가 성립한 경우에는 그 협의에 따라 배당의 순위 및 액이 배당표에 기재되고, 실무상 이러한 배당절차를 협의배당이라고 할 수 있지만,¹⁰¹⁾ 실제로 있어서 이와 같은 형태로 협의에 의한 배당이 되어지는 예는 거의 있지 아니하며, 대부분 집행법원이 작성한 배당표원안에 따라 절차가 진행되고 있다.

집행법원이 작성하는 배당표의 원안은, 대략적으로 말하면, 민법·상법 그 밖의 법률이 정한 것에 기초하여 우선 우선권을 가지는 채권자에게 그 우선순위에 따라 배당하고(민집규 제185조 제2항, 민집 제145조 제2항), 우선권을 가지는 채권자가 없는 경우나 또는 우선권을 가지는 채권자에게 배당해도 배당재단이 남는 경우에는 우선권이 없는 일반채권자 사이에서 각 채권자의 채권액에 비례하여 안분함으로써 그 배당액이 결정된다. 단순히 압류가 빠른 순서에 따라 배당되는 것이 아님을 주의할 필요가 있다(채권자평등주의).

그리고 민법·상법 그 밖의 법률에 의하여 일반채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있도록 규정되어 있는 채권자에 대하여는 우선적으로 변제하여야 하므로 배당표에 각 채권자의 배당순위를 표시하여야 한다.

배당순위는 번호로 표시하며, 같은 순위의 채권자가 여러 명인 때에는 같은 번호로 표시한다. 예컨대 국세채권, 압류채권, 배당요구채권이 배당에 가입한 경우에는 국세채권에 대하여는 1로 나머지에 대하여는 2로 표시한다.

101) 일본의 경우, 명문으로 민사집행법 제166조 제2항, 제85조 제5항이 “전항에서 규정하는 배당의 순위 및 액은, 배당기일에 있어서 모든 채권자 사이에 합의가 성립한 경우에는 그 합의에 의하고, 그 밖의 경우에는 민법·상법 기타 법률이 정하는 바에 따라 기재해야 한다.”라고 규정함으로써 집행법원에 의한 강제적 배당방법 이전에 채권자들 사이의 합의에 의한 배당이 가능하도록 근거규정을 두고 있지만, 우리의 경우에는 이러한 규정이 없다. 그러나 배당 자체의 성격이 「채무의 변제행위」에 다름 아니고, 다만 이를 강제적인 집행방법에 의해 구현하는 것일 뿐이므로 만일 변제받을 채권자들 사이에서 그 채무액의 배분에 관해 완전한 합의에 이르렀다면 사적자치의 원칙상 이를 부정할 이유가 없기 때문에, 비록 우리 민사집행법이 이를 규정하고 있지 않더라도 해석상 충분히 인정할 수 있다고 본다.

II. 제3채무자의 공탁비용 등

1. 제3채무자는 금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 경우에 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을, 금전채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거둬 압류명령 또는 가압류명령이 내려진 경우에 압류 또는 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 각 공탁하여야 하는바(민집 제248조 제2항, 제3항), 이를 실무상 ‘의무공탁’이라고 부르고 있다.

2. 공탁은 채권자나 채무자의 보통재판적이 있는 지방법원 또는 집행법원에 할 수 있고(민집 제19조 제1항), 공탁하기 위해서는 본래의 채무이행의 경우에 비하여 더 많은 여비, 일당 등이 필요하더라도 공탁하여야 할 금액에서 그 비용액을 빼고 공탁하는 것을 예정하고 있지는 않으나, 제3채무자에게 위와 같이 공탁의무를 부담하게 하면서 그로 인한 불이익을 받도록 하는 것은 상당하지 않으므로 제3채무자는 공탁신고서를 낼 때까지 집행법원에 청구하면 공탁금 중에서 지급을 받을 수 있다(민사소송비용법 제10조의2 제1항).

다만 이 청구는 집행법원에 대해 공탁의 사유를 신고할 때까지 해야 하고, 사유 신고 후의 청구는 인정되지 않는다(민사소송비용법 제10조의2 제2항).

3. 이와 같이 제3채무자가 청구하는 비용의 우선순위에 대하여는 명문의 규정이 없지만, 집행법원이 제3채무자의 청구에 따라 공탁금 중에서 지급하는 것이고(배당금으로서 지급되는 것이 아님), 본질적으로는 배당절차 전에도 집행법원의 지급결정에 기초하여 지급할 수 있는 것 등을 감안하면, 이는 배당순위와 관계없이 또한 절차비용보다 우선하여 지급받을 수 있다고 볼 것이다.¹⁰²⁾

집행법원은 제3채무자로부터 이러한 비용의 계산서가 사유신고서를 제출할 때까지 제출되면 그 내용을 심사하여 정당하다고 인정할 경우 지급결정을 하고, 배당순위에 관계없이 공탁금으로부터 집행비용에 우선하여 법원사무관등이 지급위탁의 방법으로 지급하게 될 것이나, 이 비용만을 먼저 지급하게 되면 배당재단을 알기 어렵게 되고 공탁금의 지급절차가 번잡하게 되므로 배당절차 중에서 지급하는 것도 무방할 것이다.

102) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 354.

4. 그런데 현재의 실무는 이에 관하여 다음과 같이 편법적으로 운용되고 있는 실정이다.

첫째로, 위와 같이 제3채무자는 공탁을 하고, 그 중 공탁비용에 대해 계산서를 제출하여야 하고, 집행법원이 그 계산서에 관해 타당성 여부를 검토한 다음 그것이 적정하다고 판단될 때에 법원사무관등으로 하여금 지급위탁의 방법으로 지급하여야 할 것인데도, 제3채무자가 아예 공탁을 하면서 자신의 공탁비용을 공탁금으로부터 공제하고 공탁하는 것을 그대로 용인해주고 있는 실정이다.

하지만 이러한 공탁비용의 선 공제는 우리 집행법이 예정하고 있는 것이 아닌바, 그럼에도 불구하고 이를 그대로 인정하여 공제하도록 하는 것은 집행법원이 판단하여야 할 공탁비용의 타당성 여부를 공탁관이 판단하거나 혹은 판단하지 않고 공탁금 중 일부를 지급해버리는 것과 같으며, 이는 배당재단인 (집행)공탁금의 지급권한이 공탁관이 아니라 집행법원에 있음을 간과한 것으로서 잘못된 것이다.

예컨대, 제3채무자가 공탁하면서 그 비용 중 실제 소명하여 지급받을 수 있는 금액이 불과 20만 원인데도 지급받을 수 없는 사소한 비용(예컨대, 불필요한 교통비용 또는 식사비용 등)까지 모두 포함시켜 그보다 훨씬 더 많은 80만 원을 공제한 후 나머지만 공탁해버렸다면, 이는 다른 채권자들에게 가야할 돈이 아무런 이유도 없이 제3채무자에게 지급되어 버린 결과가 되고 만다. 그 때문에 배당재단인 공탁금으로부터 지급되어야 하는 위 공탁비용에 대하여는 집행법원에 의한 엄격한 심사가 필요한 것이다. 이러한 실무의 운용례는 시정되어야 하고, 그렇게 함으로써 배당재단이 아무 이유 없이 누수되어 다른 채권자들의 이익을 해치는 것을 막아야 할 것인바, 이에 대한 예규 등의 제정이 필요하다고 본다.

둘째로, 민사소송비용법 제10조의 2 제1항이 규정하는 “채무액을 공탁한 제3채무자”는 앞서 본 바와 같이 민사집행법 제248조 제2항, 제3항에 따라 의무공탁을 한 제3채무자만을 가리킨다고 해석해야 한다.

이는 의무공탁의 경우에 제3채무자가 공탁을 위해 필요한 비용은 실제 집행채무자의 행위에 의해 증가한 변제비용으로서 본래 채무자가 부담해야 하는 것(민법 제473조 단서)으로 해석되기 때문에, 제3채무자로 하여금 이를 부담케 하는 것이 적절하지 않으므로 그 비용을 공탁금으로부터 지급할 수 있도록 하는 것이다.

따라서 위와 같은 의무공탁이 아니라 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 하는 제3채무자는 위 민사소송비용법이 적용되지 않으므로 위와 같이 공탁비용

을 지급받을 수 없는 것이다. 이는 민사집행법 제248조 제1항의 권리공탁은 본질적으로 변제공탁으로서 채무변제행위의 성질을 가지고 있는 것이며, 이러한 채무변제행위를 위한 비용은 원칙적으로 채무자가 부담해야 하므로 그 공탁을 위한 비용 또한 채무자인 제3채무자가 부담해야 하기 때문이다.

그런데 현재의 대다수 실무는 권리공탁의 경우에도 제3채무자의 비용공제를 인정해주고 있으며, 더욱이 집행법원에 의한 그 비용의 타당성 검토도 이루어지지 않은 채 위와 같이 선 공제를 해주고 있는 실정이다.

이러한 실무례 역시 빠른 시일 내에 시정되어야 할 필요가 있다 할 것이다.

☞ 현재의 실무가 이와 같이 제3채무자의 공탁비용에 대하여 법리에 맞지 않게 집행되고 있는 주요 원인은 바로 민사집행법 제248조의 규정 태도 때문이다.

즉 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 채권자가 경합하는 경우에 제3채무자에게 온전한 공탁의무를 인정하고 있다면, 이 문제에 대하여 고민할 필요 없이 의무공탁의 경우에만 집행법원이 제3채무자의 공탁비용을 인정해주면 될 것이나, 위 규정이 채권자가 경합하고 있음에도 채권자의 공탁청구가 있을 때에만 제3채무자에게 공탁할 의무를 인정하는 데에 그침에 따라(불완전한 의무공탁규정), 제3채무자는 추심채권자에게 채무액을 지급해도 되는 상태가 되었고, 이와 같이 지급된 채무액을 추심해간 채권자들이 대부분 민사집행법 제236조에 의한 추심신고를 외면하고 있는 상황이 되버린 터에, 법원으로서는 제3채무자가 권리공탁해 주기만을 바라는 결과가 되고 만 것이다.

이에 따라 권리공탁을 하는 제3채무자에 대하여 그것이 단지 채무의 변제행위임을 들어 매물차게 그 비용을 전혀 공제하지 않는 것으로 운영하는 것이 어렵게 된 것이다.

그러나 이와 같은 현실하에서도 무분별하게 채권액이 제3채무자에게 유출되는 사태는 막아야 할 것이므로 이에 대한 합리적 기준을 세우는 대책이 필요하다 할 것이다.

III. 절차비용

1. 개념

강제집행에 필요한 비용은 채무자의 부담으로 하고, 그 집행에 의하여 우선적으

로 변상을 받는다(민집 제53조 제1항). 집행비용은 집행권원 없이도 배당재단으로부터 각 채권액에 우선하여 배당받을 수 있다.

위 집행비용에는 공익비용으로 되지 않는 집행비용과 공익비용으로 되는 집행비용 즉 절차비용이 있다. 집행비용 가운데 각 채권자의 공동의 이익을 위해 지출되는 것이 공익비용으로 되는 집행비용(절차비용)이고, 이 공익비용으로 되는 집행비용, 즉 절차비용은 배당재단으로부터 최우선순위로 배당을 받게 된다.¹⁰³⁾

그리고 절차비용에는 당해 집행사건을 통하여 모든 채권자를 위하여 체당한 비용으로서의 성격을 가지는 집행절차비용과 당해 배당절차비용이 포함되는데, 그 중 전자는 압류채권자가 강제집행의 신청과 그 준비를 위하여 지출한 필요비용¹⁰⁴⁾ 및 그 절차의 진행을 위하여 예납한 금액 중 실제로 사용된 비용을 말하고, 후자에는 예컨대 사실조회비용, 기록송부촉탁비용, 계산서제출 최고비용, 배당기일통지서 송달비용 등이 여기에 해당된다.

배당법원은 직권으로 채권자가 제출한 계산서와 집행기록에 의해 집행비용을 산정한다.

배당표의 집행비용란에는 위와 같은 우선변제의 대상인 집행비용의 합계액만을 적고 그 명세는 집행비용계산서(재문양 2-176)를 따로 작성하여 배당표에 붙인다.

2. 절차비용 포함 여부가 문제되는 경우

가. 채권집행의 이중압류의 경우에 부동산집행과 같이 선행압류에 의하여 절차를 진행한다는 명문의 규정(민집 제87조)이 없으므로 여러 압류가 경합된 상태에서 절차가 진행되는 것으로 보아야 하지만, 집행비용에 관한 한 선행압류의 압류채권자가 지출한 비용만이 우선변제의 대상이 되고, 다른 압류채권자가 지출한 비용은 공익비용이 아니므로 우선변제를 받을 수는 없으며, 이러한 비용은 집행채권의 원금, 이자와 함께 그 채권자의 채권금액에 산입하여 배당하게 된다.

다만 유체동산집행의 경우에 후행 압류시에 추가압류를 하였으면 추가압류에 든 비용은 우선 배당하여야 한다.

나. ‘강제집행에 필요한 비용’(민집 제53조 제1항)에는 가압류의 집행비용이 당연

103) 민사집행법에는 절차비용이 최우선적으로 상환된다는 명문의 규정이 없지만, 위 절차비용이 전 채권자의 이익을 위해 지출된 점을 감안하여, 이와 같은 최우선적 상환은 집행법상 당연한 전제로 받아들여지고 있다.

104) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010다79565 판결

히 포함된다. 그리고 가압류가 집행된 후 그 가압류가 본압류로 이행된 때에는 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있다. 그러므로 가압류만 되어 있을 뿐 아직 본압류로 이행되지 아니한 단계에서는 가압류채권자가 그 가압류의 집행비용을 변상받을 수 없다.¹⁰⁵⁾ 다만 가압류집행 후에 다른 채권자의 집행신청에 의하여 집행이 된 경우의 배당절차에서, 그 가압류는 모든 채권자의 이익을 위한 것이라고 볼 수 있으므로 그 가압류집행비용은 우선배당을 받을 수 있다.

다. 선행압류가 집행절차 종료 전에 취소, 취하된 경우에는 그때까지 선행압류채권자가 지출한 비용은 그 채권자의 부담으로 되는 것이 원칙이므로 그 다음 순위의 압류채권자가 지출한 모든 필요비용이 우선변제를 받을 집행비용에 해당하게 된다.

다만 선행압류채권자가 지출한 비용 중 집행목적재산에 대한 감정료와 같은 순수한 공익비용(집행신청이나 그 준비를 위한 비용을 제외한 것)은 이를 우선 배당하여 그 채권자에게 반환하여야 한다.

라. 배당요구채권자가 지출한 비용도 공익비용이 아니므로 우선변제의 대상은 되지 않고 그 채권자의 채권금액에 산입하여 배당하게 된다.

마. 또한 유체동산집행이나 특별현금화방법에 의한 채권집행 등에 있어서 집행채권자가 집행관 등에게 직접 예납하고 집행관 등에 의한 공탁이나 제출 전에 매각대금 등으로부터 이미 공제된 비용은 여기의 집행비용에 산입하지 않는다.

바. 선행압류사건이 집행정지되어 뒤에 한 압류신청에 따라 절차가 진행된 경우에는 집행정지시까지 생긴 선행사건의 절차 비용은 우선변제되어야 하는데, 이 경우 선행사건의 절차비용은 모든 채권자를 위하여 채당한 공익비용으로서 집행정지된 채권이 궁극적으로 집행이 불허되더라도 우선변제되어야 할 것이므로 집행정지서면이 무엇이든 상관없이 채권자에게 배당액을 지급하여야 하고 공탁할 것이 아니다.

이와 같이 하여 집행비용을 우선변제받을 채권자가 2인 이상이 된 경우에는 각 채권자별로 집행비용액을 적어야 한다.

105) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2006다35223 판결. 따라서 제3취득자가 가압류의 집행비용을 고려함이 없이 그 처분금지의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는 청구금액만을 변제함으로써 가압류의 집행을 배제를 소구할 수 있지만, 가압류에서 본압류로 이행된 후에는 민사집행법 제53조 제1항의 적용을 받게 되므로 가압류 후 본압류로의 이행 전에 가압류의 목적물의 소유권을 취득한 제3취득자로서는 가압류의 청구금액 외에, 그 가압류의 집행비용 및 본집행의 비용 중 가압류의 본압류로의 이행에 대응하는 부분까지를 아울러 변제하여야만 가압류에서 이행된 본압류의 집행배제를 구할 수 있다.

사. 여기에 산입될 집행비용(절차비용) 이외에 각 채권자가 지출한 집행비용(필요비용)은 공익비용으로 되지 않는 집행비용으로서, 집행을 실시를 위해 필요한 비용(예컨대, 채권압류명령의 신청수수료, 채권압류명령의 송달비용 등) 뿐만 아니라, 집행신청의 준비를 위해 필요한 비용(예컨대, 집행문부여의 수수료, 판결정본송달증명신청비용 등)도 포함된다.

이러한 비용들에 대하여는, 일반채권과 동순위로 배당을 받는다는 견해도 있으나, 각 채권자의 본래 청구채권과 동순위로 배당을 받는다는 견해가 타당할 것이다.¹⁰⁶⁾ 그리하여, 위 비용은 당해 채권자의 채권금액란 중 비용란에 기재하여 배당을 하고 있다.

IV. 각 채권의 우선순위

1. 제1순위 : 최종 3월분의 임금 등 채권

가. 근로기준법의 규정

1) 구 근로기준법(1980. 12. 31. 신설되어 1997. 3. 13. 법률 제5305호로 폐지되기 전의 것) 제30조의2 제1항은 “임금, 퇴직금, 재해보상금 기타 근로관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권을 제외하고는 조세, 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. 다만 질권 또는 저당권에 우선하는 조세, 공과금에 대하여는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고, 제2항은 “1항의 규정에 불구하고 최종 3월분의 임금과 퇴직금 및 재해보상금은 사용자의 총재산에 대하여 질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권, 조세, 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다.”라고 규정하고 있었고(1987. 11. 28. 신설 당시에는 최종 3월분의 임금만 규정되어 있었으나 1989. 3. 29. 개정되면서 퇴직금 및 재해보상금이 추가되었다), 개정 전 근로기준법(1997. 12. 24. 개정되기 전의 것) 제37조도 같은 내용을 규정하고 있었다.

2) 그런데 1987. 8. 21. 헌법재판소¹⁰⁷⁾는 위와 같은 구 근로기준법 제30조의2 제2항의 규정 중 ‘퇴직금’부분에 대하여, “근로자에게 그 퇴직금 전액에 대하여 질권자나 저당권자에 우선하는 변제수령권을 인정함으로써 결과적으로 질권자나 저당권자가 그

106) 近藤基 編(주40), 154.

107) 헌법재판소 1997. 8. 21. 선고 94헌바19, 95헌바34, 97헌가11 전원재판부 결정 참조

권리의 목적물로부터 거의 또는 전혀 변제를 받지 못하게 되는 경우에는, 그 질권이나 저당권의 본질적 내용을 이루는 우선변제수령권이 형해화하게 되므로 질권이나 저당권의 본질적 내용을 침해할 소지가 생기게 된다.”는 내용으로 헌법불합치결정을 하였다.

3) 이에 따라 1997. 12. 24. 개정된 근로기준법은 구 근로기준법 제30조의2 제2항을 개정하여, 질권이나 저당권에 의하여 담보된 채권보다 우선하여 변제받을 수 있는 퇴직금의 범위를 최종 3년간의 퇴직금으로 제한하고, 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금으로 계산하도록 하였다(근로기준법 제37조 제2항, 제3항). 다만 부칙에 경과규정을 두어, 개정법의 시행 전에 퇴직한 근로자의 경우에는 1989. 3. 29. 이후의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 우선변제의 대상으로 하고(부칙 제2조 제1항), 개정법 시행 전에 채용된 근로자로서 개정법 시행 후에 퇴직하는 근로자의 경우에는 1989. 3. 29. 이후부터 개정법 시행 전까지의 계속근로기간에 대한 퇴직금에 개정법 시행 후의 계속근로기간에 대하여 발생하는 최종 3년간의 퇴직금을 합산한 금액을 우선변제의 대상으로 하며(근로기준법 부칙 제2조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 부칙 제4조 제2항), 계속근로기간 1년에 대하여는 30일분의 평균임금으로 하되, 우선변제의 대상이 되는 퇴직금은 250일분의 평균임금을 초과할 수 없도록 하였다(근로기준법 부칙 제2조 제3항, 제4항, 근로자퇴직급여 보장법 부칙 제4조 제3항, 제4항).

나. 최종 3월분의 임금

최종 3월분의 임금채권의 범위는, 그 퇴직의 시기를 묻지 아니하고 사용자로부터 지급받지 못한 최종 3월분의 임금을 말하는 것이고, 반드시 사용자의 도산 등 사업 폐지시로부터 소급하여 3월 내에 퇴직한 근로자의 임금채권에 한정하여 보호하는 취지는 아니다.¹⁰⁸⁾ ¹⁰⁹⁾ 또한 최종 3개월분의 임금채권은 사용자의 총재산에 대하여

108) 대법원 1996. 2. 23. 선고 95다48650 판결【판결요지】근로기준법 제30조의2 제2항에서 규정한 근로자의 최종 3월분의 임금에 대한 우선특권은 사용자의 총 재산에 대하여 일반 담보물권의 효력을 일부 제한하고 임금채권을 우선 변제받을 수 있는 권리로서, 근로자의 최저 생활을 보장하고자 하는 공익적 요청에서 나온 규정이므로 이에 의하여 보호되는 임금채권의 범위는 퇴직의 시기를 묻지 아니하고 사용자로부터 지급받지 못한 최종 3월분의 임금을 말하고, 반드시 사용자의 도산 등 사업 폐지시로부터 소급하여 3월 내에 퇴직한 근로자의 임금채권에 한정하여 보호하는 취지라고 볼 수 없다.

109) 최종 3개월분의 기산일에 관하여, 이를 사용자의 재산을 청산하여야 할 원인사실이 발생한 날(예를 들면 도산하거나 사업폐지한 날)을 기준으로 하여 그 이전 3개월간 미지급된 임금의 총액을 말한다는 견해와 근로자들이 임금을 최종적으로 지급받지 못한 시점을 기준으로 그 이전의 3개월간 미지급된 임금의 총액이라는 견해가 있었는데, 위 대법원 95다48650 판결은 후자의 견해를 취했다고 볼 수 있다.

사용자가 그 지위를 취득하기 전에 설정한 질권 또는 저당권에 따라 담보된 채권에도 우선하여 변제되어야 한다.¹¹⁰⁾

배당요구 이전에 이미 근로관계가 종료한 근로자의 경우 최종 3월분의 임금에 대한 기산점은 근로관계 종료일이고, 배당요구 당시에 근로관계가 종료되지 않은 경우에는 배당요구 시점을 그 기산점으로 본다.¹¹¹⁾

다. 최종 3년간의 퇴직금

1997. 12. 24. 개정되기 전의 구 근로기준법하에서는 전체 퇴직금 중 1989. 3. 29.(퇴직금에 관한 우선변제권을 규정한 근로기준법의 시행일) 이후 근무기간에 상응한 퇴직금 부분만이 구 근로기준법 제30조의2 제2항 소정의 우선변제의 대상이었고, 이에 대하여 실무는 입사일부터 퇴직일까지의 총퇴직금을 산정한 다음 입사일부터 1989. 3. 29.까지의 퇴직금을 공제하는 방법으로 우선변제의 대상이 되는 퇴직금을 산정하였으나, 1997. 12. 24. 개정된 근로기준법하에서는 같은 법 제37조 제2항, 제3항 및 부칙 제2조에 의하여 우선변제의 대상이 되는 퇴직금을 산정하여야 한다.

즉 같은 법 시행 전에 채용된 근로자로서 같은 법 시행 후 퇴직하는 근로자의 경우에는 1989. 3. 29. 이후부터 같은 법 시행 전까지의 계속근로기간에 대한 퇴직금에다가 같은 법 시행 후의 계속근로기간에 대하여 발생하는 최종 3년간의 퇴직금을 합산한 금액을 우선변제받을 수 있는데(근로기준법 부칙 제2조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 부칙 제4조 제2항), 우선변제의 대상이 되는 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금으로 계산한 금액으로 하고 250일의 평균임금을 초과할 수 없다(근로기준법 부칙 제2조 제3항, 제4항, 근로자퇴직급여 보장법 부칙 제4조 제3항, 제4항).

퇴직금은 본질적으로는 후불적 임금의 성질을 지닌 것이라는 점을 고려할 때, 배당요구서에 채권의 원인을 '임금'이라고만 기재하였다고 하더라도 그 임금에 '퇴직금'도 포함되어 있을 수 있으므로 이를 신중하게 판단할 필요가 있으나, 배당요구서의 기재 내용 및 첨부서면에 의하면 배당요구한 임금채권에 퇴직금채권이 포함되어 있지 아니한 것이 분명하다면 그 배당요구에 퇴직금채권에 대한 배당요구가 포함되어

110) 대법원 2011. 12. 8. 선고 2011다68777 판결

111) 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006다1930 판결(2003. 10.경 근로계약관계가 종료되었다면, 우선변제의 대상이 되는 '최종 3월분의 임금'은 근로계약관계 종료 시점으로부터 소급하여 3개월 이내인 2003년 8월분, 9월분 및 10월분 급여 및 상여금이고, 근로자들이 2003년 8월분 급여를 지급받았다고 하여 그 이전에 지급사유가 발생한 2003년 7월분 급여가 이에 포함되는 것은 아니라고 판시); 대법원 2015. 8. 19. 선고 2015다204762 판결

있다고 볼 수 없는 것인 바, 배당요구의 종기 이후에 제출한 채권계산서에 퇴직금채권을 추가하여 기재하였다거나 당초 배당요구한 임금채권의 액수가 근로기준법 제38조 제2항에 따라 최우선 변제되는 최종 3개월분의 임금을 초과하는 것이어서 최우선 변제되지 아니하고 남아 있는 부분이 있다고 하여 달리 볼 것은 아니다.¹¹²⁾

최종 3년간의 퇴직금도 배당요구 종기일 이전에 퇴직금 지급사유가 발생하여야 한다.¹¹³⁾

라. 우선변제의 효력(배당순위)

1) 저당권, 조세 등에 우선

위에 기술한 최종 3월분의 임금, 최종 3년간의 퇴직금,¹¹⁴⁾ 재해보상금은 저당권에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 일반채권보다는 선순위로 배당받는다(근로기준법 제38조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항).¹¹⁵⁾

2) 그 밖의 근로관계채권

임금·퇴직금 기타 근로관계로 인한 채권 중 위에 적은 것을 제외한 것(이하, 근로관계채권이라 한다)은 저당권에 의하여 담보되는 채권보다는 후순위이고, 당해세를 포함한 조세·공과금 및 일반채권보다는 선순위이다(근로기준법 제38조 제1항 본문, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항 본문, 국세기본법 제35조 제1항 제5호, 지방세기본법 제99조 제1항 제5호).

다만 조세·공과금이 저당권에 우선하는 경우에는 조세·공과금, 저당권에 의하여 담보되는 채권, 근로관계채권의 순으로 된다(근로기준법 제38조 제1항 단서, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항 단서).

따라서 저당권과 조세 등 채권의 우열을 따져 저당권이 우선하는 경우에는 저당권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권, 조세 등 채권의 순위가 되고, 조세 등 채권이 저당권에 우선하는 때에는 조세 등 채권, 저당권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권의 순위로 우선 변제된다.

112) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결

113) 대법원 2015. 8. 19. 선고 2015다204762 판결

114) 퇴직금의 우선변제에 관해서는 2005. 1. 27. 법률 제7379호로 근로기준법이 개정되면서 근로기준법에서 삭제되었고, 별도로 근로자퇴직급여 보장법이 제정되면서 동법 제12조가 이를 규정하게 되었다.

115) 다만 부동산집행의 경우 주택임대차보호법 제8조에 의한 소액보증금채권과는 다 같은 우선채권으로서 동순위로 배당한다[재판예규 제692호, “부동산경매에서 우선채권간의 배당순위(재민 91-2)” 참조].

그런데 조세채권 중 당해세가 있는 경우에 당해세는 원칙적으로 저당권에 우선하므로 근로관계채권과 당해세 등 조세채권 및 저당권에 의하여 담보되는 채권을 동시에 배당할 때는 근로기준법 제38조 제1항 단서, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항 단서에 의하여 당해세가 근로관계채권보다 선순위가 된다. 따라서 당해세, 저당권으로 담보된 채권, 근로관계채권, 기타의 조세 등 채권의 순위가 되거나, 당해세, 그 밖의 조세 등 채권, 저당권 등에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권의 순위가 될 것이다.

그러나 배당에 참가한 채권 중 조세 등 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 담보권에 의하여 담보된 채권의 후순위이고, 담보권에 의하여 담보된 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 당해세를 포함한 조세 등 채권에 우선하게 된다.

3) 임금 등에 대한 지연손해금

임금 등에 대한 지연손해금에 관하여는 우선변제권을 인정할 수 없으므로 임금채권자들이 집행력 있는 정본으로써 배당요구를 하는 경우에 원금만을 우선배당하고, 지연손해금은 일반채권자와 안분배당한다.¹¹⁶⁾

4) 임금채권의 대위변제자의 경우

우선변제권이 있는 임금채권을 대신 변제한 자는 채무자인 사용자에게 대한 임금채권자로서 사용자의 총재산에 대한 강제집행절차나 임의경매절차가 개시된 경우에 배당요구의 종기까지 배당요구를 하여 그 배당절차에서 저당권의 피담보채권이나 일반채권보다 우선하여 변제받을 수 있다(대법원 1996. 2. 23. 선고 94다21160 판결 참조).

특히 임금채권보장법 제7조에 따라 고용노동부장관이 대신 지급한 임금(체당금)에 대하여는 고용노동부장관이 당해 사업주에 대한 당해 근로자의 미지급 임금 등의 청구권을 대위하고, 근로기준법 제38조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조의 규정에 의한 임금 등의 우선변제권은 대위되는 권리에 존속한다(임금채권보장법 제8조).

116) 대법원 2000. 1. 28.자 99마5143 결정【결정요지】근로기준법 제37조 제2항에 의하면, 근로관계로 인한 채권 중 최종 3월분의 임금, 최종 3년간의 퇴직금, 재해보상금의 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있는바, 위와 같은 임금 등 채권의 최우선변제권은 근로자의 생활안정을 위한 사회정책적 고려에서 담보물권자 등의 희생 아래 인정되고 있는 점, 민법 제334조, 제360조 등에 의하면 공시방법이 있는 민법상의 담보물권의 경우에도 우선변제권이 있는 피담보채권에 포함되는 이자 등 부대채권 및 그 범위에 관하여 별도로 규정하고 있음에 반하여, 위 근로기준법의 규정에는 최우선변제권이 있는 채권으로 원본채권만을 열거하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 임금 등에 대한 지연손해금 채권에 대하여는 최우선변제권이 인정되지 않는다고 봄이 상당하다.

그런데 이와 관련하여 고용노동부장관이 체당금을 지급함에 있어서 같은 법 제7조 제2항 단서에 따라 상한액을 제한하여 일부만 대신 지급한 경우, 예컨대 근로기준법 제38조 제2항의 최종 3월분의 임금, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항의 최종 3년간의 퇴직금(재해보상금은 체당금의 대상이 아니다. 같은 법 제7조 제2항 참조) 중 고용노동부장관이 상한액을 제한하여 일부만 대신 지급한 경우에는 잔여부분에 대한 당해 근로자의 임금우선변제권과 고용노동부장관의 체당금에 대한 대위권에 기한 우선변제권이 병존하게 된다.

이 경우 당해 근로자의 우선변제권과 고용노동부장관의 대위권에 기한 우선변제권 중 어느 것이 우선하는가가 문제로 될 수 있는데, 이에 관하여는 ㉠ 당해 근로자의 우선변제권이 우선한다는 견해(임금채권자 우선설)와 ㉡ 고용노동부장관의 대위권에 기한 우선변제권이 우선한다는 견해(대위변제자 우선설), ㉢ 채권자와 대위자는 채권액에 비례하여 배당에 참가할 수 있다는 견해(채권자·대위변제자 평등설) 등으로 입장이 나뉘어져 있다. 그러나 생각건대 근로복지공단이라고 하여 보통의 대위변제자와 달리 구별할 이유가 없다고 할 것이므로 변제자 일부 대위법리에 따라 근로자가 근로복지공단보다 우선한다는 견해가 타당하다고 본다.^{117) 118)}

117) 근로복지공단의 체당금지급채무는, ① 법률의 규정에 의하여 발생한 채무로 근로자의 청구가 있어야 하는 점(구채적으로 임금채권보장법시행령 제9조 제1항은 도산등 사실이 있는 날부터 2년 이내에 청구하여야 한다고 규정하고 있다), ② 대통령령으로 그 지급금액의 상한액을 제한할 수 있는 점, ③ 체당금이 적은 경우에는 이를 지급하지 아니할 수 있는 점, ④ 체당금지급청구권을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다는 점 등과 같이 일반채무와 다른 특징을 가지고 있기는 하나, 그러한 특성들이 있다는 이유만으로 근로복지공단이 근로자의 임금채권을 대위변제한다는 기본적인 구조, 즉 대위변제자로서의 근로복지공단의 법률적 지위가 변경되는 것은 아니라 할 것이다. 또한 임금채권보장법이 제8조에서 대위에 관한 규정을 두고 있는 것은 변제자대위에 따른 당연한 법리를 재확인한 주의적 규정에 불과하며, 위 규정으로 인하여 근로복지공단에 새로이 우선변제권이 창설되거나 부여되는 것은 아니라 할 것이다.

118) 대법원 1996. 2. 23. 선고 94다21160 판결【판결요지】[1] 타인의 채무를 변제하고 채권자를 대위하는 대위변제의 경우 채권자의 채권은 동일성을 유지한 채 법률상 당연히 변제자에게 이전하고, 이러한 법리는 채권이 근로기준법상의 임금채권이라 하더라도 그대로 적용되므로 근로기준법 제30조의2 제2항에 규정된 우선변제권이 있는 임금채권을 변제한 자는 채무자인 사용자에 대한 임금채권자로서 사용자의 총재산에 대한 강제집행절차나 임의경매절차가 개시된 경우에 경락 기일까지 배당요구를 하여 그 배당절차에서 저당권의 피담보채권이나 일반채권보다 우선하여 변제받을 수 있으며, 이와 같이 근로자가 아닌 대위변제자에게 임금의 우선변제권을 인정하더라도 근로자에 대하여 임금이 직접 지급된 점에 비추어 이를 근로기준법 제36조 제1항 소정의 직접지불의 원칙에 위배된다고 할 수 없다. [2] 임의대위에 있어서는 변제자가 제3자에게 대항하기 위하여는 확정일자 있는 증서에 의한 대위의 통지나 승낙이 필요한 것이지만, 이 경우 제3자라 함은 대위변제의 목적인 그 채권 자체에 관하여 대위변제자와 양립할 수 없는 법률상 지위에 있는 자만을 의미한다. [3] 임금채권에 대하여 아무런 관련이 없는 사용자에 대한 근저당권부 채권자는 임금채권의 대위변제자가 대항요건을 갖추어야 할 제3자에 해당된다고 할 수 없으므로 변제로 인

판례¹¹⁹⁾도, ‘변제할 정당한 이익이 있는 자가 채무자를 위하여 근저당권의 피담보채무의 일부를 대위변제한 경우, 대위변제자는 변제한 금액의 범위 내에서 종래 채권자가 가지고 있던 채권 및 담보에 관한 권리를 법률상 당연히 취득하게 되지만 이때에도 채권자는 대위변제자에 대하여 우선변제권을 가진다. 이러한 법리는 근로복지공단이 최우선변제권이 있는 최종 3개월분의 임금과 최종 3년분의 퇴직금 중 일부를 채당금으로 지급하고 그에 해당하는 근로자의 임금 등 채권을 대위하여 행사하는 경우에도 그대로 적용되어 최우선변제권이 있는 근로자의 나머지 임금 등 채권이 공단이 대위하는 채권에 대하여 우선변제권을 갖는다고 보아야 한다.’라고 판시함으로써 동일한 견해를 밝히고 있다.

다만 이러한 판시는 임금의 일부를 채당금으로 지급받은 근로자와 근로복지공단 사이의 배당순위에 관한 것이고, 만일 공단이 대위행사하는 채권이 배당요구한 근로자들과 무관한 다른 근로자에 대한 채당금 지급으로 인하여 생긴 것이라면(즉 공단으로부터 아무런 채당금을 지급받지 못한 근로자의 배당요구 임금채권과 그 근로자와 무관한 다른 근로자에게 지급한 채당금에 대하여 배당요구하는 근로복지공단 사이에 서라면), 공단과 배당요구한 근로자들 사이에는 평등하게 동순위로 배당되어야 하므로 주의를 요한다.

위와 같은 견해와 대법원 판시에 따라 배당관계를 예시해보면 다음과 같다.

- ▶ 임금채권자 甲, 乙, 丙은 최종 3개월 임금 1,000만 원을 각 지급받지 못하였음
- ▶ 공단은 채당금으로 甲에게 300만 원, 乙에게 700만 원 등 합계 1,000만 원을 지급하였고, 丙은 채당금을 지급받지 못함
- ▶ 배당재단은 1,200만 원임

한 임의대위자의 사용자에게 대한 대위의 통지가 적법히 된 이상 근저당채권자가 신청한 경매절차에서 경매개시결정으로 인한 압류의 효력이 발생한 날보다 그 대위 통지 일자가 늦다고 하더라도 대위에 영향이 없다고 한 사례. [4]근로기준법 제30조의2 제2항의 입법 과정이나 목적 및 취지에 비추어 보면 그 조항에서의 ‘최종 3월분의’라는 문구는 퇴직금을 수식하지 않는다고 보여지므로 그 조항상의 우선변제의 대상이 되는 퇴직금이 최종 3개월간 근무한 부분에 대한 퇴직금만으로 한정되는 것이라고는 볼 수 없고, 원칙적으로 퇴직금 전액이 그 대상이 된다.

119) 대법원 2011. 1. 27. 선고 2008다13623 판결

채권자	미지급 임금(A)	공단 대위 변제금 (B)	배당 요구액 (D)	1차 안분 (J) (제1단계)	부족분 (D-J)	채당금 안분(K) (제2단계)	채당금 흡수 (M) (제3단계)	배당액 (J+M) (제4단계)
甲	1,000만원	300만원	700만원	280만원	420만원	120만원	120만원	400만원
乙	1,000만원	700만원	300만원	120만원	180만원	280만원	180만원	300만원
丙	1,000만원	0	1,000만원	400만원				400만원
공단			1,000만원	400만원			-300만 원	100만원
합계		1,000 만원	300 만원	1,200 만원		400 만원		1,200 만원

- * 제1단계 : 먼저 근로복지공단을 포함한 모든 배당요구채권자들에 대하여 실제 배당할 금액을 안분하여 배당한다(안분액 甲, 乙, 丙 및 공단 순서로 각 280만 원, 120만 원, 400만 원 및 400만 원이 됨).
- * 제2단계 : 제1단계에서 근로복지공단에 안분배당된 금액(위 400만 원)에 대하여, 근로복지공단에서 채당금을 지급받은 근로자(甲, 乙)에 대하여 근로복지공단의 채당금(B)을 기준으로 다시 안분한다.
- * 제3단계 : 위 대법원 2008다13623 판결에 따르면 공단으로부터 임금의 일부를 지급받은 근로자(甲, 乙)의 나머지 임금채권은 공단의 채당금채권보다 우선하게 되므로 甲과 乙은 제1단계의 배당금액(J)과 자신의 배당요구액(D) 사이의 부족분(D-J)을 제3단계의 안분된 금액(K)을 한도로 하여 근로복지공단의 제1단계 배당액(위 400만 원)으로부터 흡수한다.
- * 제4단계 : 제1단계에서 1차로 안분한 금액(J)과 제3단계에서 근로복지공단의 제1단계 배당액으로부터 흡수한 금액(M)을 합산하여 각 채권자의 배당액을 산정한다.

마. 임금직접지급의 원칙과 배당

1) 임금은 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다(근로기준법 제43조 제1항). 이를 임금직접지급의 원칙이라 한다.

따라서 근로자가 임금채권을 양도한 경우에도 그 임금의 지급에 관하여는 근로기준법 제43조 제1항에 정한 임금 직접지급의 원칙이 적용되어 사용자는 직접 근로

자에게 임금을 지급하지 아니하면 안 되고, 그 결과 비록 적법 유효한 양수인이라도 스스로 사용자에게 대하여 임금의 지급을 청구할 수 없으며, 그러한 법리는 근로자로부터 임금채권을 양도받았거나 추심을 위임받은 자가 사용자의 집행재산에 대하여 배당을 요구하는 경우에도 그대로 적용된다.¹²⁰⁾

2) 그러나 우선변제권이 있는 임금채권을 변제한 자가 사용자의 총재산에 대한 강제집행절차나 임의경매절차에서 임금채권자를 대위하는 경우에 근로자가 아닌 대위변제자에게 임금의 우선변제권을 인정하더라도 근로자에 대하여 임금이 직접 지급된 점에 비추어 이를 근로기준법 제43조 제1항 소정의 직접지급의 원칙에 위배된다고 할 수 없다.¹²¹⁾

또한 위와 같은 직접지급의 원칙은 임금채권 중 압류가 금지되지 아니한 부분(민집 제246조 제1항 제4호 참조)이 근로자의 채권자에 의하여 압류가 된 경우(예를 들어, 乙이 사용자인 丙에 대하여 가진 임금채권 100만 원 중 1/2에 해당하는 50만 원 부분이 乙의 채권자인 甲에 의해 압류된 경우)에는 적용되지 아니하므로 근로자의 임금우선변제권에 기한 배당요구에 따라 우선 지급할 배당금채권에 대하여 당해 근로자의 다른 채권자가 압류가 금지되지 아니한 부분에 관하여 추심명령이나 전부명령을 얻었을 경우에는 추심권자나 전부명령을 얻은 자에게 지급하여야 한다.

3) 한편, 실무상 압류의 범위를 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호의 범위로 제한하지 아니하고 임금채권 전액에 대하여 압류가 있는 경우에는 압류가 전 부무효는 아니고, 다만 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호의 압류금지에 해당하는 부분에 대하여는 압류가 무효이나 나머지 부분에 대하여 압류가 유효한 것으로 보아야 할 것이다.

바. 임금우선변제권의 적용 대상

임금우선변제권의 적용대상이 되는 「사용자의 총재산」이라 함은 근로계약의 당사자로서 임금채무를 1차적으로 부담하는 사업주인 사용자의 총재산을 의미하는 것이

120) 대법원 1996. 3. 22. 선고 95다2630 판결【판결요지】근로자가 그 임금채권을 양도한 경우라 할지라도 그 임금의 지급에 관하여는 근로기준법 제36조 제1항에 정한 임금 직접지급의 원칙이 적용되어 사용자는 직접 근로자에게 임금을 지급하지 아니하면 안 되고, 그 결과 비록 적법 유효한 양수인이라도 스스로 사용자에게 대하여 임금의 지급을 청구할 수 없으며, 그러한 법리는 근로자로부터 임금채권을 양도받았거나 그의 추심을 위임받은 자가 사용자의 집행 재산에 대하여 배당을 요구하는 경우에도 그대로 적용된다.

121) 위 대법원 1996. 2. 23. 선고 94다21160 판결 참조

고,¹²²⁾ 따라서 사용자가 법인인 경우에는 법인 자체의 재산만을 가리키며, 법인의 대표자 등 사업경영 담당자의 개인 재산은 이에 포함되지 아니한다.

또한 사용자가 재산을 취득하기 전에 설정된 담보권에 대하여는 임금우선변제권이 인정되지 않고, 또한 사용자의 재산이 제3자에게 양도된 경우 위 우선권은 그 재산에 대해 더 이상 추급할 수 없어 양수인의 양수재산에 대하여는 우선변제권이 인정되지 않는다.¹²³⁾

사. 우선변제권 있는 임금채권의 소명

우선변제권이 있는 임금채권자가 임금채권을 피보전권리로 하여 매각부동산에 관하여 첫 경매개시결정등기 전에 가압류집행을 한 경우에는 가압류권자로서는 배당요구가 있는 것으로 취급되게 되는데, 이 경우 우선변제권이 있는 임금채권자로서의

122) 대법원 1999. 2. 5. 선고 97다48388 판결【판결요지】[1] 구 근로기준법(1953. 5. 10. 법률 제286호로 제정되어 1997. 3. 13. 법률 제5305호로 폐지된 것) 제30조의2 제2항은 근로자의 최종 3월분의 임금과 퇴직금 및 재해보상금은 사용자의 총재산에 대하여 질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있는바, 이는 근로자의 최저생활을 보장하고자 하는 공익적 요청에서 예외적으로 일반 담보물권의 효력을 일부 제한하고 임금채권의 우선변제권을 규정한 것으로서 그 입법 취지에 비추어 볼 때 여기에서 말하는 ‘사용자의 총재산’이라 함은 ‘근로계약의 당사자로서 임금채무를 1차적으로 부담하는 사업주인 사용자의 총재산’을 의미한다. [2] 사업이 수차의 도급에 의하여 행하여지는 경우 하수급인이 직상수급인의 귀책사유로 근로자에게 임금을 지급하지 못하게 됨에 따라 직상수급인이 구 근로기준법(1953. 5. 10. 법률 제286호로 제정되어 1997. 3. 13. 법률 제5305호로 폐지된 것) 제36조의2 제1항에 의하여 하수급인의 근로자들에 대하여 하수급인과 연대하여 임금을 지급할 책임을 지게 된다 하더라도(도급이 1차에 걸쳐 행하여짐으로써 도급인과 수급인만이 있는 경우에는 도급인이 직상수급인에 해당한다고 할 것이다.), 직상수급인과 하수급인의 근로자 사이에 묵시적인 근로계약관계의 성립을 인정할 수 있는 특별한 사정이 존재하지 않는 이상 그 직상수급인은 하수급인의 근로자에 대한 관계에서 근로계약의 당사자로서 임금채무를 1차적으로 부담하는 사업주인 사용자에 해당하지 않는다고 할 것인바, 직상수급인 소유의 재산에 대한 강제집행절차에서 하수급인의 근로자들이 직상수급인 소유의 재산을 사용자의 총재산에 해당한다고 보아 이에 대하여 임금 우선변제권을 주장할 수 없다.

123) 대법원 1994. 1. 11. 선고 93다30938 판결【판결요지】[1] 근로기준법 제30조의2 제2항은 근로자의 최저생활을 보장하고자 하는 공익적 요청에서 일반 담보물권의 효력을 일부 제한하고 임금채권의 우선변제권을 규정한 것으로서 그 규정의 취지는 최종 3월분의 임금 등에 관한 채권은 다른 채권과 동시에 사용자의 동일재산으로부터 경합하여 변제받을 경우에 그 성립의 선후나 질권이나 저당권의 설정 여부에 관계없이 우선적으로 변제받을 수 있는 권리가 있음을 밝힌 것일 뿐, 나아가 사용자의 특정재산에 대한 배타적 지배권을 본질로 하는 추급효까지 인정할 것은 아니므로 사용자의 재산이 제3자에게 양도된 경우에 있어서는 양도인인 사용자에 대한 임금 등 채권의 우선권은 이 재산에 대하여는 더 이상 추구될 수 없고, 양수인의 양수재산에 대하여까지 우선권을 인정할 수는 없다. [2] 사용자가 재산을 취득하기 전에 설정된 담보권에 대하여까지 위 [1]항 임금채권의 우선변제권을 인정할 수도 없다.

소명을 언제까지 하여야 하는가에 관하여, 판례¹²⁴⁾는 배당표 확정시까지 소명하면 된다고 하는바, 이러한 이치는 채권배당에서도 동일하다고 볼 것이다.

1) 배당요구의 자격을 소명하는 서면

근로자가 집행법원에 근로기준법 제38조, 근로자퇴직급여 보장법 제12조에 정해진 임금채권 우선변제권에 기한 배당요구를 하는 경우에는, 판결 이유 중에 배당요구채권이 우선변제권 있는 임금채권이라는 판단이 있는 법원의 확정판결이나 노동부지방사무소에서 발급한 체불임금확인서 중 하나와 ① 사용자가 교부한 국민연금보험료원천공제계산서(국민연금법 제77조 참조) ② 원천징수의무자인 사업자로부터 교부받은 근로소득에 대한 원천징수영수증(소득세법 제143조 참조) ③ 국민연금관리공단이 발급한 국민연금보험료 납부사실 확인서(국민연금법 제75조 참조) ④ 국민건강보험공단이 발급한 국민건강보험료 납부사실 확인서(국민건강보험법 제62조 참조) 중 하나를 소명자료로 첨부하여야 한다.¹²⁵⁾ 다만 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크기 때문에, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다는 것이 판례¹²⁶⁾의 입장이다.

2) 다수의 근로자가 임금채권으로 배당요구를 하는 경우¹²⁷⁾

가) 근로자 대표자를 선임하여 그의 명의로 배당요구를 하는 경우 : 집행법원은 근로자들이 대표자를 선임하여 그에게 배당요구 및 임금채권 추심에 관한 일체의 권한을 위임하고 그와 같은 내용의 결의서나 위임장을 첨부하여 대표자 명의로 배당요구를 하는 경우 그 대표자 이외의 근로자의 배당요구로서는 효력이 없다는 사실 및 근로자 대표자가 사용자와 약속어음 공정증서 등을 작성하고 그에 기하여 자신의 명

124) 대법원 2002. 5. 14. 선고 2002다4870 판결【판결요지】근로기준법에 의하여 우선변제청구권을 갖는 임금채권자라고 하더라도 임의경매절차에서 경락기일까지 배당요구를 하여야만 우선배당을 받을 수 있다는 것이 원칙이나, 경매절차개시 전의 부동산가압류권자는 배당요구를 하지 않았더라도 당연히 배당요구를 한 것과 동일하게 취급하여 설사 그가 별도로 채권계산서를 제출하지 아니하였다 하여도 배당에서 제외하여서는 안 되는 것인바, 민사집행절차의 안정성을 보장하여야 하는 절차법적 요청과 근로자의 임금채권을 보호하여야 하는 실체법적 요청을 형량하여 보면 근로기준법상 우선변제청구권이 있는 임금채권자가 경매절차개시 전에 경매 목적 부동산을 가압류한 경우에는 경락시까지 우선권 있는 임금채권임을 소명하지 않았다고 하더라도 배당표가 확정되기 전까지 그 가압류의 청구채권이 우선권 있는 임금채권임을 입증하면 우선배당을 받을 수 있다고 해석하여야 한다.; 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다52312 판결

125) 재판예규 제1120호, “근로자의 임금채권에 대한 배당시 유의사항(재민 97-11)”

126) 대법원 2006. 12. 7. 선고 2004다29376 판결

127) 재판예규 제1120호, “근로자의 임금채권에 대한 배당시 유의사항(재민 97-11)” 참조

의로 배당요구를 하는 경우 임금채권 우선변제권을 인정할 수 없다는 사실을 적절히 고지하는 것이 바람직하다.

나) 선정당사자 제도를 이용하여 배당요구를 하는 경우 : 근로자들이 민사소송법 제53조 제1항의 규정에 따라 선정당사자를 선정하여 배당요구를 한 경우 및 근로자들이 집행절차가 개시되기 전에 선정당사자 명의로 (가)압류를 한 경우(다만 이 경우에 집행법원은 직권으로 근로자별 임금채권액을 조사하여야 한다)에는 선정당사자를 채권자로 인정한다. 이 경우 선정당사자는 배당요구를 할 때에, ㉠ 선정당사자를 포함한 선정자의 이름, 주소를 적은 당사자선정서, ㉡ 선정자별 배당요구임금채권액을 적은 서면, ㉢ 선정자별 임금채권이 우선변제권이 있는 임금채권임을 소명하는 위 1) 항의 내용을 적은 서면 등을 제출해야 한다. 집행법원은 배당표에 선정당사자를 채권자로 적고, 선정자별 임금 합계액을 채권액으로 적으며, 배당표에 별지 양식의 선정자 및 선정자별 배당채권액 목록을 첨부한다.

2. 제2순위 : 집행의 목적물에 대하여 부과된 관세(관세법 제3조 제1항), 국세와 가산금(국세기본법 제35조 제1항 제3호), 지방세와 가산금(지방세기본법 제99조 제1항 3호)

가. 의의

집행의 목적물에 대하여 부과된 국세, 지방세 및 가산금 등을 당해세라고 한다(국세기본법 제35조 제1항 제3호, 지방세기본법 제99조 제1항 제3호).

지방세에 대하여도 지방세기본법 제99조 제2항 제3호에서 당해세우선의 원칙을 규정하였다가 1991. 12. 14. 개정하면서 위 원칙을 폐지하였는데, 1995. 12. 6. 법률 제4995호로 지방세법을 개정하면서 당해세우선의 규정을 부활시켜(시행일은 1996. 1. 1.) 오늘에 이르고 있다.

관세의 경우, 관세를 납부하여야 할 물품에 대하여는 다른 조세 기타 공과금과 채권에 우선하여 그 관세를 징수한다(관세법 제3조 제1항). 따라서 당해 기계나 설비를 직접 세관장이 압류한 경우뿐만 아니라 다른 채권자가 압류하여 강제집행하는 경우에도 세관장은 교부청구 또는 참가압류를 통하여 당해세우선의 경우와 동일하게 우선배당받을 수 있다.¹²⁸⁾

128) 그러나 국세징수의 예에 의하여 관세를 징수하는 경우 체납처분의 대상이 당해 관세를 납부하여야 하는 물품이 아닌 재산인 때에는 관세의 우선순위는 국세기본법에 의한 국세와 동일한 순위로 한다(관세법 제3조 제2항). 이때 다른 조세와의 사이에서는 압류선착주의가 적용된다고 볼 것이다[위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 537 참조].

나. 당해세의 종류

어떤 조세가 당해세에 해당되는지에 관한 구체적·세부적 판단문제는 개별법령의 해석·적용의 권한을 가진 법원의 영역에 속한다.¹²⁹⁾

1) 국세의 경우

가) 국세에 관하여 국세기본법 제35조 제5항은 상속세·증여세·종합부동산세를 당해세로 규정하고 있다.

나) 상속세, 증여세에 대하여, 이는 과세물건에 대한 재산세라기보다는 권리변동을 대상으로 하여 부과되는 것이므로 이를 당해세로 인정한다면 담보물권의 본질적 내용을 침해할 우려가 있어 위헌의 소지가 있다는 견해도 있어 보이나, 증여세에 관하여 대법원은 이를 그 목적물 자체에 관하여 부과된 이른바 당해세에 해당한다고 판시한 바 있어,¹³⁰⁾ 증여세나 이와 유사한 상속세는 모두 위 시행령의 규정대로 당해세로 취급하는 것이 실무의 입장이다. 다만 집행절차에서 교부청구한 상속세와 증여세가 집행물건에 대한 당해세에 해당하는지에 관하여는 신중한 판단이 필요하다.

이에 관한 대법원의 입장을 부동산집행의 경우를 중심으로 살펴보자면, 우선 증여세에 관하여, 부동산을 매수한 후 소유권이전등기를 하지 아니한 채 수증자 앞으로 직접 소유권이전등기를 한 것을 과세대상으로 삼아 부과된 증여세는 당해세에 해당하

129) 현재 2001. 2. 22. 99헌바44 【결정요지】[1] 국세기본법 제35조 제1항 제3호의 “(그 재산에 대하여 부과된 국세와 가산금을 제외한다)”는 부분 중 당해 재산의 소유 그 자체를 과세의 대상으로 하여 부과하는 이른바 강학상의 재산세에 해당하는 국세와 가산금 부분은 담보권자의 예측가능성을 해치지 아니하므로 과세요건 명확주의에 위반되지 아니하고, 재산권인 저당권 등의 본질적인 내용을 침해하거나 그 내용을 과도하게 제한하는 것이라고 볼 수 없다. [2] 어떤 국세가 우선징수권이 인정되는 “당해 재산의 소유 그 자체를 과세의 대상으로 하여 부과하는 국세와 가산금”에 해당되는지에 관한 구체적·세부적인 판단 문제는 개별법령의 해석·적용의 권한을 가진 법원의 영역에 속하므로 헌법재판소가 가려서 답변할 성질의 것이 아니다.

130) 대법원 1999. 8. 20. 선고 99다6135 판결 【판결요지】증여자가 타인으로부터 부동산을 매수하여 자기 앞으로 소유권이전등기를 경료하지 아니한 채 수증자에게 위 부동산을 증여하고 바로 수증자 앞으로 소유권이전등기를 경료하였다면, 그 소유권이전등기시에 수증자가 부동산 자체를 증여받은 것으로 보아야 할 것이지, 이와 달리 단지 부동산에 관한 소유권이전등기청구권을 증여받았을 뿐이라고 볼 수는 없으므로 갑과 그의 처 을 공동 명의로 부동산에 관한 소유권이전등기청구권 보전 가등기를 경료하였다가 갑으로부터 을 앞으로 부동산의 2분의 1 지분에 관한 소유권이전등기청구권 보전 가등기 이전의 부기등기를 경료한 다음, 을 앞으로 가등기에 기한 본등기를 경료한 경우, 실질적으로 을은 가등기에 기한 본등기를 경료한 때에 갑으로부터 그 부동산 지분 1/2 을 증여 받았다고 보아야 할 것이고, 위 증여를 과세대상으로 하여 을에게 부과된 위 증여세 및 그 가산금은 그 부동산 자체에 관하여 부과된 이른바 당해세에 해당하므로 국세기본법 제35조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 법정기일이 부동산에 관하여 설정된 근저당권설정등기일 보다 앞서는지 여부에 관계없이 근저당권의 피담보채권에 우선하여 징수하여야 한다.

지만,¹³¹⁾ 매각재산의 취득자금을 증여받은 것으로 추정하여 그 재산의 취득자금에 대하여 부과하는 증여세는 당해세라고 할 수 없고,¹³²⁾ 구 상속세법(1996.12.30. 법률 제5193호로 전문개정되기 전의 것) 제34조의2 제1항의 규정에 의하여 부과되는 증여의제로 인한 증여세는 당해세가 아니라고 판시함으로써,¹³³⁾ 매각재산 자체가 증여된 경우에 한하여 그 재산에 부과된 증여세가 당해세에 해당한다고 하고 있다.

또한 부동산에 대하여 근저당권설정 이전에 이루어진 증여를 원인으로 하여 부과된 증여세는 위 부동산 자체에 관하여 부과된 것이고 근저당권설정 당시 이미 등기 기록상 증여를 원인으로 하여 근저당권설정자 명의로 소유권이전등기가 마쳐져 있었으므로 근저당권자로서는 장래 이 증여를 과세원인으로 하여 증여세가 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있다고 봄이 상당할 것이고, 따라서 위 증여세는 당해세에 해당한다고 판시하고 있다.¹³⁴⁾

131) 위 대법원 1999. 8. 20. 선고 99다6135 판결 참조

132) 대법원 1996. 3. 12. 선고 95다47831 판결 【판결요지】국세기본법상의 법정기일 전에 설정된 근저당권에 의하여 담보된 채권보다 우선하는, 그 매각재산에 대하여 부과된 국세·가산금은 근저당권이 설정된 재산 자체에 대하여 부과된 국세·가산금이어야 할 것인데, 상속세법의 규정에 의하여 부과된 증여세는 재산의 취득자금을 증여받은 것으로 추정하여 그 재산의 취득자금에 대하여 부과하는 것이어서 국세기본법상의 그 매각재산 자체에 대하여 부과된 국세·가산금이라고 할 수 없으므로 위 법정기일 전에 설정된 근저당권에 의하여 담보된 채권에 우선하지 못한다.

133) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000다49534 판결 【판결요지】[1] 국세기본법 제35조 제1항 제3호는 공시를 수반하는 담보물권과 관련하여 거래의 안전을 보장하려는 사법적(私法的) 요청과 조세채권의 실현을 확보하려는 공익적 요청을 적절하게 조화시키려는 데 그 입법의 취지가 있으므로 당해세가 담보물권에 의하여 담보되는 채권에 우선한다고 하더라도 이로써 담보물권의 본질적 내용까지 침해되어서는 아니 되고, 따라서 같은 법 제35조 제1항 제3호 단서에서 말하는 '그 재산에 대하여 부과된 국세'라 함은 담보물권을 취득하는 사람이 장래 그 재산에 대하여 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있는 것으로서 오로지 당해 재산을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 국세만을 의미하는 것으로 보아야 한다. [2] 구 상속세법(1996. 12. 30. 법률 제5193호로 전문 개정되기 전의 것) 제34조의2 제1항의 규정에 의하여 부과되는 증여의제로 인한 증여세는 특수관계에 있는 자로부터 재산 등을 시가보다 낮은 대가로 이전받은 경우에 수증자가 그 대가와 시가의 차액을 상당하는 이익을 증여받은 것으로 보고 이에 대하여 부과하는 것으로서, 그 재산 자체의 증여에 대하여 부과하는 통상적인 증여세와는 과세대상을 달리 하는 것이어서, 당해 재산을 소유하는 것 자체에 담세력을 인정하는 국세기본법 제35조 제1항 제3호 소정의 당해세의 본질과는 다른 것이고, 또한 담보물권자로서는 부동산의 증여자와 수증자 사이에 위 상속세법이 규정하는 특수관계가 있는지 여부, 재산이 시가보다 낮은 대가로 이전되었는지 여부 및 장래 부과될 증여세액이 어느 정도 될 것인지 등에 대한 예측가능성이 있었다고 보기 어려우므로 위 증여세는 당해세가 아니라고 한 원심의 판단은 정당하다고 한 사례.

134) 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다47972 판결 【판결요지】[1] 국세기본법 제35조 제1항 제3호는 공시를 수반하는 담보물권과 관련하여 거래의 안전을 보장하려는 사법적(私法的) 요청과 조세채권의 실현을 확보하려는 공익적 요청을 적절하게 조화시키려는 데 그 입법의 취지가 있으므로 당해세가 담보물권에 의하여 담보되는 채권에 우선한다고 하더라도 이로써 담보물권의 본질적 내용까지 침해되어서는 아니 되고, 따라서 같은 법 제35조 제1항 제3호 단서에서 말하는 '그 재산

상속세에 관하여는, 국세에 대하여 우선적으로 보호되는 저당권으로 담보되는 채권이라 함은 원래 저당권 설정 당시의 저당권자와 저당권설정자와의 관계를 기본으로 하여 그 설정자의 납세의무를 기준으로 한 것이라고 해석되므로 저당권설정자가 그 피담보채권에 우선하여 징수당할 아무런 조세의 체납도 없는 상태에서 사망한 경우에 그 상속인에 대하여 부과한 국세인 상속세는 이를 당해세라 하여 우선 징수할 수 없다고 판시하였다.¹³⁵⁾

다) 한편, 당해세와 저당권의 우선관계에 관하여 법문의 형식으로만 보면 납세의 무자가 누구인지 또는 저당권이 설정되어 있는지의 여부와 관계없이 우선 징수되는 것으로서 저당 목적물이 양도된 사실에 불구하고 양수인의 당해세에 대하여도 우선한다고 보는 무제한설도 있을 수 있으나, 판례는 저당권 설정자에게 부과된 세금에 한하여 우선할 수 있고 양수인에게 부과된 증여세라든가 설정자의 사망으로 인하여 그 상속인에게 부과된 상속세와 같은 당해세는 기존의 저당권자에 우선하여 징수할 수 없다는 제한설에 따르고 있다.¹³⁶⁾ 137)

에 대하여 부과된 국세'라 함은 담보물권을 취득하는 사람이 장래 그 재산에 대하여 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있는 것으로서 오로지 당해 재산을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 국세만을 의미하는 것으로 보아야 한다. [2] 부동산에 대하여 근저당권설정 이전에 이루어진 증여를 원인으로 하여 부과된 증여세는 위 부동산 자체에 관하여 부과된 것이고, 근저당권설정 당시 이미 등기부상 증여를 원인으로 하여 근저당설정자 명의로 소유권이전등기가 마쳐져 있었으므로 근저당권자로서는 장래 이 증여를 과세원인으로 하여 증여세가 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있다고 봄이 상당할 것이고, 따라서 위 증여세는 국세기본법 제35조 제1항 제3호 단서에서 말하는 '그 재산에 대하여 부과된 국세', 즉 이른바 당해세에 해당한다.

135) 대법원 1996. 7. 12. 선고 96다21058 판결; 그 밖에 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001다44376 판결(명의신탁해지를 원인으로 상속인 명의의 소유권이전등기가 마쳐져 부동산등기기록 기재상 상속재산임이 공시되어 있지 아니한 부동산의 경우 담보물권자가 당해 부동산에 상속세가 부과된다는 점을 예측할 수 없었음을 이유로 상속세가 당해세에 해당하지 않는다고 판시)

136) 대법원 1995. 4. 7. 선고 94다11835 등 판결 [판결요지][1] 구 상속세법(1988.12.26. 법률 제4022호로 개정되기 전의 것) 제9조 제4항, 같은법시행령(1988.12.31. 대통령령 제12567호로 개정되기 전의 것) 제5조의2 제2호, 제3호는 시가주의 원칙을 정한 같은 법 제9조 제1항의 규정을 보충하여 시가에 보다 근접한 가액을 산정하려는 취지에서 규정된 것으로서, 근저당권을 설정하는 경우 피담보채권최고액은 통상 재산의 실제가액 범위 내에서 결정되는 것으로 볼 수 있어서 근저당권의 피담보채권최고액이 다른 방법으로 산정한 가액보다 클 때에는 채권최고액을 실제가액으로 봄이 일반적으로 거래의 실정에 부합한다는 데에 그 타당성의 근거가 있는 것이므로 예외적으로 재산의 실제가액보다 큰 금액을 피담보채권액으로 하여 근저당권이 설정된 경우에는 납세의무자가 그와 같은 사정을 입증하여 위 규정의 적용으로부터 벗어날 수 있다. [2] 제1순위 상속권자인 처와 자들이 모두 상속을 포기한 경우에는 손이 직계비속으로서 상속인이 된다. [3] 구 국세기본법(1990.12.31. 법률 제4277호로 개정되기 전의 것) 제35조 제1항 제3호의 규정에 의하여 특히 국세에 대하여 우선적으로 보호되는 저당권으로 담보되는 채권은 저당권 설정 당시의 저당권자와 설정자와의 관계를 기본으로 하여 그 설정자의 납세의무를 기준으로 한 취지의 규정으로 해석되고, 이러한 국세 등에 우선하는 저당채권은 설정자가 사망하고 그 상속인에게 국세의 체납이 있었다고 하더라도 특별규정이 없는 현행법하에서는 그 보호의 적격이 상실되는 것은 아니라고 할 것이므로

2) 지방세의 경우

가) 지방세에 관하여는 지방세법에 그 재산에 대하여 부과된 지방세와 가산금이 라는 표현을 사용할 뿐 하위법령에도 당해세의 종류에 관한 아무런 규정을 두고 있지 않았었다.

그 반면, 헌법재판소 1994. 8. 31. 91헌가1 결정은 당해세우선 규정의 위헌여부가 문제가 된 사건에서, “조세는 과세물건을 기준으로 할 때 소득세·재산세·소비세 및 유통세로 분류되는데, 이 중에서 당해세우선의 원칙을 취하더라도 담보물권의 본질적 내용을 침해한다거나 과도하게 제한하는 것으로 볼 수 없는 것은 당해 재산의 소유 그 자체 즉 어떤 사람이 당해 재산을 소유하고 있다는 사실 그 자체에 담세력을 인정하여 부과하는 강화상의 재산세에 한한다.”고 판시하면서, 지방세 중에서 취득세·등록세·면허세에 대하여는 헌법 규정상 당해세우선의 원칙을 적용할 수 없고, 재산세 및 자동차세와 같은 재산세에 한하여 당해세우선의 원칙을 적용할 경우 헌법위반의 문제는 생길 수 없다고 하였다.

나) 그런데 1996. 12. 31. 대통령령 제15211호로 개정된 지방세법시행령은 제14조의 제4를 신설하여 당해세의 종류로 취득세·등록세·재산세·자동차세·종합토지세·도시계획세 및 공동시설세를 규정하고 있었다. 그러나 그 중 취득세와 등록세는 위헌법재판소의 결정에 반하는 것이었기 때문에 실무¹³⁸⁾는 그 중 취득세와 등록세를 인정하지 않고 있었다. 그러다가 2005. 1. 5. 대통령령 제18999호로 지방세법 시행령의 위 조항이 개정되어 이제는 당해세가 아니다.

현재는 지방세기본법이 지방세 중 당해세를 재산세, 자동차세(자동차 소유에 대한 자동차세만 해당한다), 도시계획세,¹³⁹⁾ 지역자원시설세(특정 부동산에 대한 지역자원시설세만 해당한다),¹⁴⁰⁾ 지방교육세(재산세와 자동차세에 부가되는 지방교육세만

사망한 저당권설정자에게 저당권에 우선하여 징수당할 아무런 조세의 체납도 없는 상태에서 상속인에 대하여 부과한 국세인 상속세를 당해세라고 하여 우선징수할 수는 없으나, 담보물권에 의하여 담보된 채권보다 우선하는 이른바 당해세의 개념 및 범위에 관하여는 위 규정에서도 “그 재산에 대하여 부과된 국세 또는 가산금”이라고만 하고 있어 이에 대한 대법원판결들이 선고될 때까지는 그 법리가 반드시 명확한 것이 아니었으므로 위 판결들이 있기 전에 행정청이 한 공매대금배분처분에서 위 상속세를 저당권보다 우선하여 배분한 것이 위와 같은 법리에 위반된 것이라 하더라도 그 하자가 객관적으로 명백하다고는 할 수 없어 이를 당연무효라고까지 볼 수는 없다.

137) 이러한 법리는 우선변제권 있는 임금채권의 경우도 마찬가지이다. 즉 사용자가 재산을 취득하기 전에 설정된 담보권에 대하여서는 임금채권의 우선변제권을 주장할 수 없다(대법원 1994. 1. 11. 선고 93다30938 판결).

138) 대법원 1996. 3. 8. 선고 95다51113 판결 참조

139) 위 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다58088 판결 참조

140) 대법원 2002. 2. 8. 선고 2001다74018 판결

해당한다)로 규정하고 있다(지방세기본법 제99조 제5항).

다. 당해세의 순위

당해세는 최우선순위의 임금채권을 제외하고는 다른 채권에 대하여도 우선한다(다만 조세채권 사이에서는 동순위라고 보아야 한다. 국세기본법 제35조 제1항 제3호, 지방세기본법 제99조 제2항 제3호). 이를 당해세우선의 원칙이라고 한다.

이 원칙은 공시를 수반하는 담보물권과 관련하여 거래의 안전을 보장하려는 사법적 요청과 조세채권의 실현을 확보하려는 공익적 요청을 적절하게 조화시키려는 데 입법취지가 있기 때문에, 당해세가 담보물권에 의하여 담보되는 채권에 우선한다고 하더라도 이로써 담보물권의 본질적 내용까지 침해되어서는 안 되므로 당해세라 함은 담보물권을 취득하는 사람이 장래 그 재산에 대하여 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있는 것으로서 오로지 당해 재산을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 국세만을 의미하는 것으로 보아야 한다.¹⁴¹⁾

141) 대법원 1999. 3. 18. 선고 96다23184 전원합의체 판결; 대법원 2002. 2. 8. 선고 2001다 74018 판결 등 【판결요지】[1] 가산금·증가산금의 법정기일에 관하여는 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정된 것) 제31조 제2항 제3호에서 따로 정한 바가 없으나, 같은 법 제1조 제13호와 제27조 제1항 및 제2항의 규정에 의하면 지방세를 납부기한까지 납부하지 아니한 때에는 이 법에 의하여 고지세액에 가산금을 가산하여 징수하고 납기경과 후 일정기한까지 납부하지 아니한 때에는 그 금액에 다시 소정의 증가산금을 가산하여 징수하도록 규정되어 있으므로 가산금·증가산금은 같은 법 제25조 소정의 납세고지서에 의한 본세의 납부고지에서 고지된 납부기한이나 그 이후의 소정의 기한까지 체납된 세액을 납부하지 아니하면 과세관청의 가산금·증가산금에 대한 별도의 확정절차 없이 위 규정에 의하여 당연히 발생하고 그 액수도 확정되는 것이고, 따라서 가산금·증가산금의 법정기일은 같은 법 제31조 제2항 제3호(다)목의 규정을 유추 적용하여 가산금·증가산금 자체의 납세의무가 확정되는 때, 즉 납부고지에서 고지된 납부기한이나 그 이후의 소정의 기한을 초과할 때로 보아야 한다. [2] 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정된 것) 제31조 제2항 제3호는 공시를 수반하는 담보물권과 관련하여 거래의 안전을 보장하려는 사법적(私法的) 요청과 조세채권의 실현을 확보하려는 공익적 요청을 적절하게 조화시키려는 데 그 입법의 취지가 있으므로 당해세가 담보물권에 의하여 담보되는 채권에 우선한다고 하더라도 이로써 담보물권의 본질적 내용까지 침해되어서는 아니 되고, 따라서 같은 법 제31조 제2항 제3호 괄호 안의 단서에서 말하는 ‘그 재산에 대하여 부과된 지방세라 함은 담보물권을 취득하는 자가 장래 그 재산에 대하여 부과될 것을 상당한 정도로 예측할 수 있는 것으로서 오로지 당해 재산을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 지방세만을 의미하는 것으로 보아야 한다. [3] 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정된 것) 제239조, 제241조, 경기도도세조 제32조, 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정된 것) 제240조, 제242조 제1항, 제189조 등의 규정들을 종합하여 보면, 소방공동시설에는 소방시설에 필요한 비용에 충당할 것을 목적으로 하여 그 소방시설로 인하여 이익을 받는 건축물 또는 선박의 소유자가 건축물·선박을 소유하고 있는 것 자체에 담세력을 인정하여 부과되는 지방세라고 볼 수 있고, 담보물권을 취득하는 자로서도 장래 그 건축물·선박에 대하여 매년 과세기준일 현재의 소유자에게 소방공동시설세가 부과되리라는 것을 쉽게 예측할 수 있으므로 소방공동시설세는 당해 건축물·선박과 관련하여 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정된 것) 제31조 제2항 제3호 괄호 안의 단서에서 말하는 “그 재산에 대하여 부과된 지방세”에 해당한다.

라. 지방세법의 개정과 우선되는 당해세의 범위

1) 지방세에 관하여 당초 지방세법 제31조 제2항은 당해세우선의 원칙을 규정하였다가 1992. 1. 1.부터 시행된 개정 지방세법에서 당해세우선 규정을 삭제하였고, 1995. 12. 29. 지방세법이 다시 개정되면서(시행일은 1996. 1. 1.) 당해세우선의 원칙이 새로이 규정되었다.

2) 이에 따라 어느 시점의 당해세에 대하여 신법을 적용할 것인가가 문제될 수 있는데, 개정법 부칙 제8조는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 부과 또는 감면하였거나 혹은 부과 또는 감면하여야 할 지방세에 대하여는 종전의 예에 의한다고 규정하고 있으므로 이에 따라 개정법의 시행일인 1996. 1. 1. 이후에 납세의무가 성립하는 당해세, 즉 1996년도분부터 신법에 의하여 당해세 우선의 원칙이 적용된다고 해석해야 할 것이다.

3) 한편, 1996. 1. 1. 이후 납세의무가 성립한 당해세가 그 이전에 성립된 저당권 등에 우선할 수 있는지가 또한 문제되는데, 이에 관하여 대법원은 당해세는 위 개정법 시행 이전에 이미 설정된 근저당권의 피담보채권에 대하여 우선할 수 없다고 판시하였다.¹⁴²⁾

4) 또한 1996. 1. 1. 이후에 성립한 당해세가 1992. 1. 1. 이전(당해세 규정이 폐지되기 전)에 설정된 저당권 등에 우선하는지 여부에 관하여 역시 견해가 대립될 수 있으나, 이미 법 개정으로 폐지된 규정이 그 후 다시 개정되었다고 하여 그 효력이 부활한다고 보기는 어려우므로 부정적으로 해석하여야 할 것이다.¹⁴³⁾

142) 대법원 1999. 3. 12. 선고 98다59125 판결【판결요지】“모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다.”고 한 헌법 제13조 제2항의 규정에 비추어, 개정된 지방세법(1995. 12. 6. 법률 제4995호로 개정되어 1996. 1. 1.부터 시행된 것)에 의하여 새로 규정된 당해세의 우선적 효력은 그 우선적 효력을 설정한 법률이 제정되기 전에 이미 성립한 저당권이나 질권에 대해서까지 소급하여 적용될 수는 없고, 나아가 지방세법에 당해세 우선 규정이 전혀 없는 시점에 저당권을 설정받는 자에게 장래에 당해세 우선 규정이 신설될 것을 예측할 것을 요구할 수는 없으므로 저당권 설정 후 제정된 당해세 우선 규정을 그 규정 제정 전에 이미 성립한 저당권에 대해서까지 적용하는 것은 저당권자의 예측을 침해한다는 점에서도 허용될 수 없다 할 것인바, 따라서 과세관청이 배당요구를 한 재산세 및 종합토지세가 모두 근저당권의 목적물에 관하여 부과된 당해세이고 그 법정기일(납세고지서 발송일)이 개정된 지방세법 시행 이후라고 하더라도, 그 조세채권은 개정된 지방세법 시행 이전에 설정된 근저당권의 피담보채권에 대해서는 우선할 수 없다.

143) 대법원 1999. 3. 12. 선고 98다59125 판결.

3. 제3순위 및 제4순위 : 담보권(질권, 우선특권 및 물상대위권)에 의하여 담보되는 채권, 지방세 등 지방자치단체의 징수금, 당해세 아닌 관세, 국세와 가산금

가. 조세 상호간의 우선순위

1) 조세는 원칙적으로 교부청구의 선후에 관계없이 동순위로 그 사이에는 우선관계가 없다고 할 것이지만,¹⁴⁴⁾ 1개의 집행목적물에 대하여 체납처분의 일환으로 압류가 행하여졌을 때 그 압류에 관계되는 조세는 국세나 지방세를 막론하고 교부청구한 다른 조세보다 우선하는데(국세기본법 제36조 제1항, 지방세기본법 제101조 제1항), 이를 압류선착주의라고 한다.

2) 이 압류선착주의가 강제집행절차에 의하여 현금화할 때에도 그대로 적용되는냐에 관해 견해의 대립이 있다.

그 중 소극설의 입장에서는, 체납처분의 압류는 사법상의 강제집행절차에 대하여는 배당요구의 효력이 있는 데 그치는 것이고 또 배당에서의 우선순위를 정함에 있어 적용할 다른 규정도 없는 이상, 경매절차에서 조세채권의 우선순위는 압류일과 관계없이 법정기일을 기준으로 하여야 하는 것이며, 압류선착주의는 경매절차에서는 적용이 없다고 보는 견해를 취하고 있으나, 실무는 대체로 적극설의 입장에서, 부동산에 관하여는 현금화단계에까지 경매절차와 체납처분절차의 병존을 허용하고 있으며 경매절차에 있어서도 조세상호간의 통일적 조절이 여전히 필요한 이상 압류선착주의의 적용을 배제할 이유는 없고, 이때 압류의 효력은 등기 후의 체납액에도 미친다는 견해를 나타내고 있다.

판례¹⁴⁵⁾ 또한 “국세기본법 제36조 제1항과 지방세법 제34조 제1항이 채택하고 있는 이른바 압류선착주의(押留先着主義)의 취지는 다른 조세채권자보다 조세채무자의 자산 상태에 주의를 기울이고 조세 징수에 열의를 가지고 있는 징수권자에게 우선권을 부여하고자 하는 것이고, 이러한 압류선착주의의 입법 취지와 압류재산이 금전채권인 경우에 제3채무자가 그의 선택에 의하여 체납처분청에 지급하는지 집행법원에 집행공탁을 하는지에 따라 조세의 징수액이 달라지는 것은 부당하다는 점을 고려하여 보면, 압류선착주의는 조세가 체납처분절차를 통하여 징수되는 경우뿐만 아니라 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것)에 의한 강제집행절차

144) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 513.

145) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001다83777 판결

를 통하여 징수되는 경우에도 적용되어야 한다.”라고 판시하여 적극설과 동일한 취지이다. 다만 이 경우에도 조세채권 상호간의 우열을 가릴 때에만 압류선착주의가 적용된다고 보는 것이 통설이다.

나. 담보권실행 등의 우선순위

1) 질권 등 담보권에 의하여 담보되는 채권 상호간에는 질권 등의 설정 선후에 의하여 우선순위가 정해진다(민법 제333조).

2) 그리고 질권과 저당권 등 담보권에 의한 물상대위의 우선순위에 관해서는 학설의 대립이 있으나, 판례¹⁴⁶⁾가 물상대위에 의한 압류의 의미를 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데에 있다고 보고 있으므로 저당권의 공시가 물상대위권의 공시가 되어 저당권설정등기와 질권의 대항요건을 갖춘 시점에 의해 결정된다는 견해가 타당할 것이다.¹⁴⁷⁾

또한 담보권의 설정만 한 채 압류를 하지 않은 담보권자는 배당을 받을 채권자가 될 수 없고,¹⁴⁸⁾ 따라서 배당의 순위를 문제 삼을 여지도 없을 것이다.

그리하여 예컨대, 1번 저당권자 甲, 2번 근저당권자 乙, 3번 저당권자 丙이 있고, 丙, 乙의 순으로 물상대위에 기해 당해 물건의 임료채권을 압류한 후 甲이 당해 물건에 대하여 저당권의 실행을 위해 부동산경매절차를 신청하였는데, 위 물상대위에

146) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결; 그 외에 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다25728 판결; 대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688 판결; 대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다4272 판결; 대법원 2000. 6. 23. 선고 98다31899 판결; 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결 등 [판결요지]민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사집행법 제273조[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조]에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사집행법 제247조 제1항[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제580조 제1항]에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고, 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다.

147) 近藤基 編(주40), 157-158.

148) 위 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결 등 참조

기해 압류된 임료가 공탁되고 그에 대하여 채권배당절차를 행하는 경우, 그 채권배당 절차에서 배당을 받을 채권자는 乙과 丙이고, 또한 乙은 丙에게 우선하게 된다. 또 甲은 임료채권의 압류를 하고 있지 않기 때문에 배당을 받을 채권자로 되지 않는다. 다만 甲이 신청한 부동산경매절차에서 당해 물건이 매각된 경우라면, 甲·乙·丙은 현실적으로 배당이 있는가 어떤가는 별개의 문제이고, 세 사람 모두 배당을 받을 채권자가 된다.

3) 다음으로 질권과 저당권 등에 의한 물상대위가 경합한 경우에는, 위에서 본 것처럼 질권의 대항요건이 구비된 시기와 저당권 등의 설정등기일의 선후를 가지고 결정하게 된다.¹⁴⁹⁾

다만 실무상 질권과 저당권 등의 우선관계가 문제로 되는 사안은 거의 없다.

4) 나아가 저당권 등에 의한 물상대위와 일반채권이 경합한 경우에는, 저당권 등의 설정등기일과 일반채권에 의한 채권압류명령의 제3채무자에 대한 송달일의 전후에 의해 결정하는 것이 타당할 것이다.¹⁵⁰⁾

따라서 일반채권에 의한 채권압류명령이 제3채무자에게 송달된 후, 저당권의 설정을 받아 물상대위에 기초하여 동일채권을 압류해도 저당권자는 일반채권자에게 열후(劣後)하게 되는 것이지만(단, 배당에 있어서는 상대효설에 따라 평등배당할 것임), 실무상 이와 같은 사례는 거의 없다.

다. 조세와 담보권의 실행 등과의 우선순위

담보권에 의하여 담보되는 채권과 당해세가 아닌 관세, 국세와 가산금, 지방세와 가산금 채권은 그 성립시기의 선후에 의하여 우선순위가 결정된다.

즉 질권 등의 설정시기와 국세(국세기본법 제35조 제1항 제3호), 지방세(지방세 기본법 제99조 제1항 제3호)의 법정기일(자진신고납세의 경우 신고일, 수시부과과세의 경우 납세고지서 발송일, 원천징수세의 경우 납세의무 확정일 등)의 선후를 비교하여 먼저 성립된 것이 우선하게 된다.

그리고 질권 등 담보권에 기한 물상대위의 우선순위에 관해서는 앞서 본대로 저당권설정등기와 질권의 대항요건을 갖춘 시점에 의해 결정된다고 보아야 할 것이므로 조세와 질권 등 담보권에 기한 물상대위와의 우열에 대하여도 조세의 성립시기와 저당권의 설정등기시기 또는 질권의 대항요건을 갖춘 시점의 선후에 의해 결정된다고

149) 近藤基 編(주40), 158-159.

150) 近藤基 編(주40), 159.; 日最判 平成 10(1998). 3. 26.(判時 1638, 74) 참조

보아야 할 것이다.¹⁵¹⁾

4. 제5순위 : 근로기준법 제38조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항의 채권을 제외한 근로관계채권

앞서 보았듯이, 제1순위인 임금 등 채권(최종 3월분의 임금등 채권)을 제외한 근로관계채권은 질권 등에 의하여 담보된 채권에는 후순위이나 조세등 채권(제2순위인 당해세를 포함한다)에는 우선하고, 다만 담보권에 우선하는 조세 등에는 우선하지 못하므로(근로기준법 제38조 제1항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항), 질권과 조세채권의 우열을 따져 질권이 우선하는 경우에는 질권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권, 조세 등 채권의 순위가 되고, 조세 등 채권이 질권에 우선하는 때에는 조세 등 채권, 질권에 의하여 담보된 채권, 근로관계채권의 순위로 우선 변제된다.

조세채권 중 당해세가 있는 경우에는 당해세는 항상 질권등에 우선하므로 위 예에 의하여 당해세(제2순위), 질권 등으로 담보된 채권(제3순위), 근로관계채권(제4순위), 기타의 조세 등 채권(제5순위)의 순위가 되거나, 당해세(제2순위), 그 밖의 조세 등 채권(제3순위), 질권 등에 의하여 담보된 채권(제4순위), 근로관계채권(제5순위)의 순위가 될 것이다.

배당에 참가한 채권 중 조세 등 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 담보권에 의하여 담보된 채권의 후순위이고, 담보권에 의하여 담보된 채권이 없는 경우에는 근로관계채권은 항상 당해세를 포함한 조세 등 채권에 우선하게 된다.

5. 제6순위 : 국세 및 지방세의 다음 순위로 징수하게 되는 보험료, 공과금 등

가. 의의

앞서 본 조세·가산금 및 체납처분비 이외의 채권이면서 국세징수법상의 체납처분의 예에 의하여 징수할 수 있는 채권을 통상 공과금이라고 부르는데(국세기본법 제2조 제8호, 지방세기본법 제99조 제1항 참조), 여기에는 징수순위가 일반채권보다 앞서는 것과 그렇지 아니한 것이 있고, 전자 중에도 납부기한에 따라 담보권과의 우선순위가 달라지는 것과 그렇지 아니한 것이 있는데, 어느 것이나 이들 징수금이 미납된 경우 국세징수법상의 체납처분의 예에 의한 압류·참가압류 및 교부청구가 가능하고, 압류의 배당요구적 효력, 배당요구의 종기까지 교부청구(배당요구)의 요부, 그 방

151) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65396 판결 참조

법 및 교부청구하지 아니한 경우의 효과는 조세의 경우와 같다.

나. 구 국민의료보험법상의 의료보험료, 국민건강보험법상의 건강보험료 및 국민연금법상의 연금보험료, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률상의 산재보험료 등의 경우

구 국민의료보험법(1999.2.8. 법률 제5854호로 제정된 국민건강보험법 부칙 제2조로 폐지된 것)상의 의료보험료와 구 국민의료보험법 및 구 의료보험법을 대체한 국민건강보험법상의 건강보험료(동법 제85조), 그리고 국민연금법상의 연금보험료(동법 제98조), 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률상의 산재보험료(동법 제30조 단서)¹⁵²⁾ 등은 그 납부기한 전에 설정된 질권 등에 대하여는 우선하지 못하나, 그 납부기한 이후에 설정된 질권 등과 기타 일반채권에 대하여는 우선하여 배당하여야 한다.

다만 위 보험료 등이 납부기한 후에 설정된 질권 등보다 우선한다고 하여도 조세보다 우선하는 것은 아니므로 위 보험료의 납부기한 후에 설정된 질권보다 후순위의 조세가 있을 경우에는 질권보다 우선하는 보험료채권과 질권 및 질권보다 후순위의 조세채권 사이에 순환관계가 성립할 것이다.

다. 구 의료보험법에 의한 의료보험료, 구 국민연금법에 의한 연금보험료의 경우

1) 담보권 등과의 우선순위

가) 구 의료보험법(1999.2.8. 법률 제5854호로 제정된 국민건강보험법 부칙 제2조로 폐지된 것) 제56조 제3항, 제58조는 위 법에 의하여 징수하여야 할 보험료 및 징수금의 징수순위에 관하여 국세 및 지방세의 다음으로 하도록 규정하는 한편, 징수절차는 국세채납처분의 예에 의하도록 규정하고 있을 뿐이고, 달리 국세우선에 관한

152) 구 산업재해보상보험법(2003. 12. 31. 법률 제7049호로 개정되기 전의 것) 제74조, 제76조는 그 법에 의해 징수하여 할 보험료의 징수순위에 관하여 국세 및 지방세의 다음으로 하도록 하고, 징수절차는 국세채납처분의 예에 의하도록 규정할 뿐이어서 국세우선에 관한 국세기본법 제35조 제1항 제3호 등을 준용할 수 있는 근거가 없었다. 그런데 산업재해보상보험법상의 보험료 등 징수에 관하여 별도의 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률이 2003. 12. 31. 제정되자 동법 제30조가 “보험료, 이 법에 의한 그 밖의 징수금은 국세 및 지방세를 제외한 다른 채권에 우선하여 징수한다. 다만 보험료 등의 납부기한 전에 전세권·질권 또는 저당권의 설정을 등기 또는 등록한 사실이 증명되는 재산을 매각하여 그 매각대금 중에서 보험료 등을 징수하는 경우에 그 전세권·질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권에 대하여는 그러하지 아니하다.”라고 규정하였고, 이에 따라 산재보험료와 담보권 등과의 우선순위에 대하여는 산재보험료의 납부기한과 담보권 등의 등기 또는 등록일의 선후에 의해 이를 정할 수 있게 되었다.

국세기본법 제35조 제1항 제3호 등을 준용할 수 있는 근거가 없다.

나) 현재 이들 공과금채권과 담보권에 의하여 담보되는 채권의 우선순위에 관하여는, ① 공과금채권의 발생시기와 담보권 등의 설정등기 선후에 의하여 결정할 것이라는 견해와 ② 담보권에 의하여 담보되는 채권이 항상 우선한다는 견해가 있다.

다) 한편, 이에 대하여 대법원 1988. 9. 27. 선고 87다카428 판결은, 의료보험료와 저당권에 의하여 담보되는 채권의 우선순위에 관하여 의료보험료의 징수절차에 국세기본법 제35조 또는 지방세기본법 제99조의 규정을 준용하게 되면 저당권의 설정시기와 의료보험료 등의 지급기한 여하에 따라서는 의료보험 등의 우선순위가 국세, 지방세에 우선하는 결과가 되는 수도 있게 되어 의료보험법 제56조에 반하게 된다고 하여 위 ①설에 따라 우선순위를 결정할 것이 아니라는 취지로 판시한 바 있다.

라) 실무는 위 판결 이후 위 ②설에 따라, 위 보험료 등의 채권은 그 납부기한이 저당권 설정시보다 선후인지 여부는 고려하지 않고, 조세와 저당권자 다음 순위로 배당하고 일반채권자와의 관계에서만 우선하여 배당하고 있는 것으로 보인다. 따라서 채권배당의 경우 위 보험료 등의 채권과 저당권부 채권을 압류한 채권자 사이의 우선관계는 후자가 우선하는 것으로 배당이 되어야 할 것이다.

2) 구 국민연금법에 의한 보험료의 징수순위

구 국민연금법(2000. 12. 23. 법률 제6286호로 개정되기 전의 것) 제81조는 “연금보험료 기타 이 법에 의한 징수금의 징수의 순위는 의료보험법에 의한 보험료와 동순위로 한다.”고 규정하고 있었는데, 구 국민연금법이 시행되고 있는 사이에 의료보험법이 폐지되고 국민건강보험법이 시행되게 되었고, 한편 2000. 7. 1.부터 시행된 국민건강보험법 부칙 제13조는, 다른 법령에서 종전의 의료보험법을 인용하고 있는 경우에 국민건강보험법 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 국민건강보험법 또는 국민건강보험법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다고 규정하고 있다.

따라서 구 국민연금법 제81조의 연금보험료 등의 징수순위에 관하여 이를 의료보험법에 의한 보험료와 동순위로 한다는 규정은 의료보험법이 국민건강보험법으로 대체된 이후에는 국민건강보험법에 의한 보험료와 동순위로 한다는 규정으로 변경되었고, 그에 따라 구 국민연금법에 의한 연금보험료 등의 징수순위는 종전의 의료보험법 제58조 대신 국민건강보험법 제85조가 적용된다 할 것이다(위 구 국민연금법 제81조는 2000. 12. 23. 법률 제6286호로 개정되면서 그 규정내용을, “연금보험료 기

타 이 법에 의한 징수금의 징수의 순위는 국민건강보험법에 의한 보험료와 동순위로 한다.”라고 명시하였다).

라. 과태료와 국유재산법(제73조 제2항)상의 사용료 등 채권

위 각 채권도 그 징수는 국세징수법에 의한 체납처분의 징수절차에 의하나, 징수순위에 관한 특별한 규정을 두고 있지 않으므로 원칙적으로 일반채권과 동순위로 배당받게 된다. 따라서 조세에 관한 우선징수의 원칙(국세기본법 제35조 제1항, 지방세기본법 제99조 제1항)이나 압류선착주의(국세기본법 제36조 제1항, 지방세기본법 제101조 제1항)는 그 적용이 없고, 다만 일반 채권과 동일한 순위로 배당받을 뿐이다.

과태료 중 감사의 집행명령에 의하여 집행하는 것에 대하여는 민사집행법 제60조, 비송사건절차법 제249조, 형사소송법 제477조 등에서 따로 규정하고 있고, 여기서는 행정관청이 일단 부과한 것을 그 상대방이 다투지 아니함으로써 그대로 확정되어 버린 과태료를 말하는 것이며 그 집행에 관하여는 개별법에서 대부분 국세 또는 지방세체납처분의 예에 의하여 징수하도록 규정하고 있다(예: 도로교통법 시행규칙 제147조 등).

6. 제7순위 : 일반채권자의 채권

우선권 없는 일반채권은 우선권이 있는 모든 채권에 열후(劣後)한다. 따라서 배당순위로서는 조세공과금, 물상대위권을 행사한 담보권 등에 열후하여 최후순위로 된다. 이것은 어느 집행권원이 있어도 동일하다.

이 일반채권 상호간에 있어서는 우열의 관계가 없으므로 평등주의 원칙이 적용되고, 따라서 각 청구채권액의 비율에 응하여 평등하게 배당을 받게 된다.